

الأستاذ الدكتور

عبد الله مبروك النجار

العميد الأول لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر
أستاذ ورئيس قسم القانون الخاص بجامعة الأزهر
عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
محام بالنقض ومحكم دولي

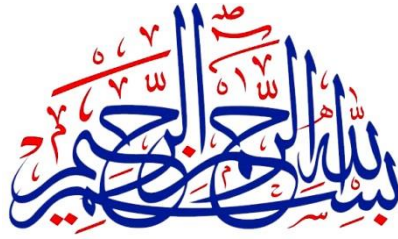
المبادئ العامة للحقوق

الطبعة الثانية

٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ م

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف





﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ
الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرِفُونَ ﴾

صِدْقُ اللَّهِ الْعَظِيمِ

(يونس ، الآية ٣٢)

تقديم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه، ومن سار على منوال شريعته واتبع منهاج دينه إلى يوم الدين.. وبعد:

فقد كانت دراسة موضوع الحقوق - ولا تزال - ذات أهمية قصوى في حياة الأمم والأفراد، وذلك لما تؤدي إليه تلك الدراسة من ضبط معالمه، وتحديد جوانبه، وإبراز نطاقه حتى يتسنى لكل من ينشد الحق ويحصل عليه أن يستعمله في الحدود التي لا يساء فيها استعماله، ولا يترتب عليها ضرر لغيره، وقد اضطرت دراسة النظرية العامة للحق منذ عقود طويلة على نمط تقليدي لم يخرج كثيراً عن المسار المرسوم له من قبل فقهاءنا الأماجد الذين عبدوا طريق دراسته والبحث فيه، وكانوا رواداً في تلك الدراسات التي حازوا بها قصب السبق، وأصبحوا بها علينا أهل إحسان وفضل، فقد تعلمنا مما كتبوا، وتكونت أفكارنا في هذا الموضوع مما خلفه أولئك السابقون الكرام، جزاهم الله عما قدموا للفقهاء خير الجزاء، وجعل ما كتبوه في صحائف حسناتهم أمام ربهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

بيد أن بقاء الأمور على ما هي عليه ليس من المألوف في الحياة، لا سيما في أمور البحث العلمي القائمة على الاجتهاد والنظر،

فإن العقول متفاوتة، والأنظار متجعدة، والنوازل متغيرة، وظروف البحث مختلف من وقت لآخر، ومن مكان إلى غيره، وسبحان من يغير ولا يتغير، ولا شك أن البحث في الموضوعات التشريعية والقانونية ومنها موضوع "الحقوق"، من ضمن تلك المسائل التي يعتريها التغيير مثلها في ذلك كمثل غيرها من أمور الحياة المتجددة والمتغيرة، وربما كانت هي أكثر استجابة للتغيير والتحدث من غيرها، لما يتسم به الحق من شمول واستغراق لجميع الأشياء والمواقف التي يمكن أن يكون للإنسان مصلحة في تقرير حقه عليها واستثنائه بها، وهو في كل موطن يوجد فيه بحاجة إلى تأصيل يحدد نوعه ويبين طبيعته ويضبط آثاره حتى لا تتصادم الحقوق ويبطل الغرض التشريعي من تقريرها.

ومن ملامح ثبات دراسة الحقوق عند إطار معين ما تواتر عليه البحث من التوقف في تلك الدراسة عند التصنيف التقليدي للحقوق، وهو الذي يقتصر على الحقوق التبادلية التي ينشأ الحق فيها محملاً بالالتزام لحظة وجوده، حتى قلَّ أن يوجد حق لا يقابله واجب، بل إنه لا يوجد حق من الحقوق المقررة للعباد إلا ويكون متضمناً في وجهه الآخر لالتزام يمثل حقاً للطرف الآخر، فصار الحق والالتزام وجهين لعملة واحدة حتى ترسخ في الأذهان أن مدى البحث في أنواع الحقوق قد توقف عند هذا التقسيم التقليدي العتيق.

وقد تغيرت أنماط التعامل في الحياة، وتبدلت معها أخلاق الناس حتى صار الحرص على الكسب، وتعجل الحصول عليه أثراً

لإنحدار السلوك وإنعدام الرغبة في العطاء، ورفض تأجيل الأخذ لأمد يلتقط المدينون فيه أنفاسهم، أو يشعرون فيه بتعاطف أصحاب الحقوق معهم، وكادت دراسة الحق أن تكون خادمة لتلك العجلة المادية التي لا تقبل التأجيل ولا تنتظر لما يعطيه الدائن إلا بمقدار ما يأخذه في مقابله حالاً وليس مალأ.

ومع ذلك التغير الذي أظهر مدى خطورة اقتصار أنواع الحقوق على تلك الأنماط التبادلية التي توجب في سلوك المتعاملين تلك الرغبة الجامحة في استعمال ثمرة التعامل وتعجل الكسب السريع بأسلوب (خذ وهات) حتى اختزلها البعض عند (خذ واجرى) أو (خذ وأهرب) وأصبحنا نعاني من تلك الروح المادية الموغلة في الجفاء والقوة، والبعد عما سنه الشارع الحكيم في التعامل من رحمة وتعاطف وتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان.

وقد حدث ذلك التطور في مجال التعامل، مع وجود الحق التداولي معلناً عن نفسه في أنواع كثيرة منه، دون أن يفكر أحد في تفعيل دوره بطريقة جادة يمكن أن تكون عاملاً مساعداً للخروج من وهدة تلك القسوة المادية التي أمسكت بتلابيب التعامل في حياتنا فهو يقوم على البذل العاجل دون تحسب لتلازم العطاء مع البذل، أو انتظار ذلك العائد بعد فترة طويلة من الزمان.

وفكرة الحق التداولي لا تنتظر إلى المقابل العاجل، وإنما تركز على العطاء الفوري ابتغاء الصالح العام ورعاية من هم بحاجة ماسة وعاجلة لهذا العطاء.

ولقد أردت بهذه الدراسة الجديدة أن أتناول موضوع دراسة الحقوق بطريقة تظهر معالم الحق التداولي وتؤدي إلى تفعيل دوره في تخفيف قسوة التعامل وتعليم الناس أن يعملوا لمستقبلهم ومستقبل أهليهم وبلادهم بقدر ما يعملون لأنفسه في حاضرهم، واعتقد أن مثل تلك الثقافة لم تم ترسيخها بمثل هذا تناول الجديد لدراسة الموضوع وما قد يليه من دراسات تزيده عمقاً وتأصيلاً نكون قد حققنا نجاحاً باهراً في وقت أصبح النجاح فيه عزيزاً والأمال فيه مختقة، واخترت لها اسماً يبرز إطار ذلك تناول الجديد للحقوق في ظل نظرية جديدة تجمع الجديد والقديم منها، وهو: النظرية الجديدة لدراسة الحقوق (الحق التداولي والحق التبادلي) دراسة مقارنة، راجياً أن تكون وافية بالغرض ومحقة للمقصود، ومعبرة عما أردت أن أقدمه لطلاب الدراسات القانونية بمفهوم يضيف للفقہ الجديد، وبأسلوب يتسم بالوضوح والتجديد. أدعو الله - تبارك وتعالى - أن يجعل هذه الدراسة نافعة في المجال الذي ألفت له، وأن يتقبلها بقبول حسن، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.

دكتور

عبد الله مبروك النجار

خطة الدراسة

وسوف يشتمل هذا الكتاب على بابين رئيسيين:

- الباب الأول: تعريف الحق وبيان أنواع الحقوق
- الباب الثاني: عناصر الحق، ومصادره وإثباته

الباب الأول

التعريف بالحق وبيان

تصنيفات الحقوق

وفيه فصلان:

- الفصل الأول: تعريف الحق وتمييزه عما يختلط به
- الفصل الثاني: تصنيفات الحقوق والمعيار الذي تقوم عليه وأنواعها

الفصل الأول

تعريف الحق وتمييزه

عما يختلط به

المبحث الأول

تعريف الحق في فقه القانون

لفظ الحق في معناه القانوني كثير ما يرد في لغة التخاطب العادية، بين عامة الناس، ويندر أن نجد من يشعر بصعوبة في إدراك مدلوله، وقصد القائل منه، فلو أن شخصاً عادياً تواتر على سمعه أن زيداً من الناس يملك هذا المنزل فإنه لا شك مدرك وبدون أدنى صعوبة، أن لزيد هذا دون غيره أن يستفيد منه بأن يستعمله بنفسه، كما أن له أن يستغله وأن يتصرف فيه، وإذا قيل أن للعامل بمقتضى ثبوت هذا الحق أن يطالب رب العمل به، وإن لم يدفع له مختاراً فله أن يلجأ إلى السلطات المختصة لإجباره على دفع هذا الحق، ومثل هذا يمكن أن يقال في حق الزوجة في النفقة على زوجها، وحق الدولة في جباية الضرائب من مموليها، وغير ذلك من المواطن التي يرد فيها لفظ الحقوق.

ورغم بساطة معنى الكلمة وسهولتها على مسامع الشخص العادى إلا أن فقهاء الشريعة والقانون حين يعرضون لتعريف الحق على نحو يبين ماهيته لا يتفقون على رأى واحد، حتى أن تعريف الحق ليعد من أكثر مسائل الفقه التى ثار بشأنها الخلاف بين الفقهاء، ولعل أساس هذا الاختلاف عند فقهاء القانون مرده - كما يرى الأستاذ الدكتور منصور مصطفى منصور - بحق - إلى ما يتمتع به أى تعريف من خصائص مميزة، الأمر الذي يؤدى إلى صعوبة وضع تعريف واحد يجمع شتات كل هذه الأنواع^(١).

أسباب تعذر تعريف الحق في مجالاته التبادلية:

وفي نظرنا أن مرد الصعوبة في تعريف الحق يرجع إلى أمرين:

(١) د. منصور مصطفى منصور: المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، ص ٧ وما بعدها، مكتبة عبد الله وهبة ١٩٦٢م، وراجع في نفس المعنى: د. نعمان محمد جمعة: دروس في المدخل للعلوم القانونية، ص ٢٨١ وما بعدها، دار النهضة العربية ١٩٧٧م، حيث يقرر: أن كلمة الحق ليست هي الحالة الوحيدة، بل أن هناك العديد من الكلمات التى تثير نفس الصعوبة، وعلى سبيل المثال؛ فإن كلمة خطأ، معناها في اللغة الدارجة واضح، لكن أمرها يدق إذا انتقلنا إلى لغة القانون وخاصة في مجال المسؤولية المدنية، حيث يلتزم من تسبب بخطئه في الإضرار بالغير أن يعوض هذا الغير، ولا غرابة في ذلك، فهناك فارق بين الشئ المادي الذي ندركه بالحس وبين الشئ المعنوي الذي ندركه بعقولنا وبمخيلتنا، حيث يكون التعريف في الحالة الأولى سهلاً، ولا يحتمل خلافاً، لأن الأشياء المادية محددة من حيث كيانها وصفاتها، أما الأشياء المعنوية فإنها تعتمد في تعريفها على مخيلة صاحب التعريف، والخيال في مجال التعريف ليس منضبطاً لأنه لا يتطابق مع تفكير سائر الناس، كما أن تصور الماهية فيه يختلف من إنسان لآخر.

أولهما: اختلاف الروابط التي يتضمنها الحق، حيث لا يوجد الحق مطلقاً من كل قيد، وإنما - غالباً - ما يوجد الحق وهو مرتبط بواجب، حتى قيل: إن كل حق يقابله واجب، ولا يوجد حق مطلق إلا الله - سبحانه وتعالى-، فهو صاحب الحق المطلق، حيث لا يجب عليه سبحانه شيء، وإذا كان مناط الواجب هو الالتزام به، فإنه لا توجد قوة لدى الخلق يمكن أن تفرض على الخالق - سبحانه - ما يرون أنه واجب عليه - حاشا لله - ولهذا كانت عبادته واجبة على الخلق، دون توقف على ما يقابلها من دخول الجنة أو تحصيل الثواب على تلك العبادة، فإن الله - تعالى- إن أثاب بفضلته، وإن عاقب فبعده، الكون جميعاً قبضته، والخلق كلهم رهن قدرته، هو القاهر فوق عباده وهو اللطيف الخبير، ومن ثم كان حق الله مطلقاً مما يجب مقابلاً لهذا الحق، ويلحق بحق الله تعالى في تميز الحق، وتفردته على الواجب المرتبط به فئة من الحقوق التي قررها الله - تعالى- لبعض عباده، ومن تلك الحقوق:

(١) حق الوالدين في البر:

لقد قرر الله - تعالى- للوالدين على أولادهم حقاً في البر والطاعة يوجب عليهم أن يقوموا بحقوقهم دون مراعاة لأي اعتبار آخر يمكن أن يمثل مقابلاً لهذا البر، وذلك كالمحبة أو الإنفاق، أو بذل المال، أو ما إلى ذلك مما يمثل داعياً من دواعي حب الأبناء لأبائهم، فأوجب عليه البر حتى ولو لم يكن لهؤلاء الآباء قدرة على تحقيق متطلبات أبنائهم، ومما يدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَأِنْ جَاهَدَاكَ

عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (١)، وقد روى عن أسماء - رضى الله عنها - قالت: قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتيته قائلة: قدمت على أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلى أمك" (٢)، وفي هذيه الدليلين ما يفيد أن بر الوالدين ووصلهما من الواجبات المقررة لهما على الأبناء حتى ولو لم يكونا مؤمنين بالله، بل حتى ولو كانا مشركين وجاهدا الولد على أن يكون مشركاً مثلهما، فإنهما في تلك الحالة التى بلغ الذنب فيها مبلغاً لا يصل إليه ذنب آخر، حيث لا يوجد بعد الكفر ذنب، لا سيما ذلك الكفر النشط، الذي يحاول جر الولد وإغراقه في براثن الكفر والشرك معهما، ولو كان بر الوالدين مرتبطاً بواجب عليهما لما أوجب الله - تعالى - وصلهما وبرهما في حال الكفر.

ومما يدل على ذلك أن الله - سبحانه - ربط برهما بالإيمان به، وشكرهما بشكره، فقال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} (٣).

(١) سورة لقمان - من الآية ١٥.

(٢) النووى، رياض الصالحين، ص ١٥٦، طبعة المكتب الإسلامي بدمشق.

(٣) سورة الإسراء - الآية ٢٣.

وقال تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} ^(١)، وهذا الربط بين حق الوالدين في البر وحق الله - تعالى - في العبادة والشرط لفضله ونعمائه، يدل على أن حقهما في البر ملحق بهذا الحق، بل جعل عقوقهما مقارناً للشرك به في توصيف الجرم وتصنيفه ضمن أكبر الكبائر، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "الكبائر: الإشراف بالله وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس" ^(٢)، وقد روى عن أبي بكرة نفع بن الحارث - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا انبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها: ثلاثاً، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراف بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته ييسكت" ^(٣)، وتمنى السكوت هنا ليس مقصوداً به النفرة مما يقوله النبي - صلى الله عليه وسلم - بل الرهبة من هول ما يقوله، وشدته على النفوس حتى يتمنى السامع أن يعتق نفسه من سماعه تخففاً من هوله وتدبراً لوقعه.

ومن تلك الأدلة الشرعية وغيرها يبدو أن حق الوالدين في البر ملحق بحق الله - تعالى - في الإطلاق من القيود المرتبطة به، وأنه لا يسقط لأي سبب من الأسباب المتعلقة بحبس المقابل أو الانتفاع عن اتصاله لمن يتطلع إليه.

(١) سورة لقمان - من الآية ١٤.

(٢) النووي، المرجع السابق، ص ١٦١.

(٣) المرجع نفسه.

(٢) حقوق معدومي الأهلية وفاقيديها:

وهناك بعض الحقوق المقررة لعدد من المستحقين دون أن يكون لها مقابل في ذمتهم، إما لأنهم فقدوا أهلية التصرف بالموت أو المرض المعجز، أو الجنون والعتة، أو الصغر أو الفقر والحاجة، فهذه الطوائف وأمثالها من ذوي الضعف والمسكنة والحاجة تجب لهم حقوق مطلقة دون أن يقع في ذمتهم مقابل يرتبط بتلك الحقوق، لأنهم ليسوا أهلاً للالتزام، فالطفل تجب له كافة الحقوق المادية والأدبية المقررة له على من أناط بهم الشارع أداء تلك الحقوق مع عجزه عن المقابل، وكذلك الميت له حق في التجهيز والدفن مع افتقاده لأهلية بذل المقابل إذا لم يكن له مال يجهز منه، ومثله الشيخ الفاني والمريض العاجز عن طلب العلاج أو الذي لا يجد ثمن الدواء، فهؤلاء وغيرهم ممن فقدوا أهلية التصرف أو أصابهم العجز الشديد تتقرر لهم الحقوق اللازمة لحفظ أبدانهم أو كرامتهم دون أن يلزموا بالمقابل، لأن الذي قرر تلك الحقوق هو الله، وهو - سبحانه - الذي يثيب عليها، ومن ثم كانت حقوق تلك الفئات حقوقاً مطلقة عن المقابل، وملحقة بحق الله - تعالى - من تلك الجهة.

لقد رفع الله حقوق العجزة والمستضعفين إلى مرتبة حقه المقرر له على عباده في أن يؤمنوا به ويعبدوه، ولا يشركوا معه في العبادة شيئاً وذلك حتى لا يقصر الناس في القيام بتلك الحقوق استهانة بضعف أصحابها، وافتقاد الرادع الذي يدفعهم إلى احترامها.

وفي غير مجال تلك الحقوق المطلقة، تكون كافة الحقوق
تبادلية تقوم على المعارضة المادية التي تخضع لمبدأ (الغرب بالغنم)،
أو الأدبية التي ينشدها الواهبون أو المتبرعون من تصرفاتهم.

معنى ارتباط الحق بالواجب في آن واحد معاً، أن النظرة إليه
سوف تكون مختلفة من جهة ما يستفيد صاحب الحق فيه، أو يغرم
بسببه، فمن يقع الحق لصالحه كالدائن، أو من يتجه عنصر (الدائنة)
في الحق لصالحه، لو طلب منع وضع تعريف للحق، فإنه لا بد أن
يحيطه بجملة من القيود التي تعلو من شأنه وارفح من وزنه، وتحقق
له أكبر قدر من الضمانات التي يمكن بها الحصول عليه، ولو أن من
عليه الحق، أو من يتجه له عنصر المديونية فيه قد طلب منه أن
يعرف الحق من جهته، لخلع عليه من الأوصاف المغايرة لصاحب
حق الدائنية، والتي تهون منه، وتجعل محله شيئاً تافهاً بسيطاً، وأنه
سوف يرمى به لمن يطالب به من أقرب فرصة، وذلك من شأنه أن
يؤدى إلى اختلاف عبارات كل طرف ونظرته في تعريف الحق.

ثانيهما: اختلاف المناخ الفكرى الذي تنشأ في ظل القواعد
القانونية المنظمة لتبادل الحقوق واستعمالها، ومن المعلوم أن لكل دولة
نظامها الفكرى والسياسى التابع من فلسفتها في تنظيم إدارة الحكم
والعلاقة بين الحاكمين والمحكومين فيها، ومن الدول التي تعتنق
- مثلاً - المذهب الفردي الذي يعلى من شأن الفرد، ويجعله محور
اهتمام القانون ورعايته، وأن ذلك الاهتمام وتلك الرعاية، هما المدخل
الصحيح للتقدم الاجتماعى الذي سوف يأتلف في مجمله من أفراد

أحرار يملكون القدرة على أن يعبروا عن آرائهم، وهم في مأمن من عدم الحاق الأذى بهم، وأن المجتمع الحر لا يمكن أن يقوم إلا على أكتاف مجموعة من الأفراد الأخيار الذين يتمتعون بحقوق المواطنة وحقوق الإنسان، وحقوق المساواة في الحقوق والواجبات بما يجعل حريتهم في التعبير عن إرادتهم خالصة من الذل والامتهان، أو العبودية والإهمال.

وبعض المذاهب الفكرية، كالمذهب الجماعي، أو الاشتراكي، لا يعطى للأفراد كل هذا القدر من الحقوق، بل يعتبره قطعة ضئيلة في آلة، وأن حقوق المجتمع يجب أن تتقدم على حقوق الأفراد، وحسب الفرد في تلك الأنظمة الفكرية الشائنة لحقوقه، أن يحصل على القدر الضروري لإقامة حياته دون زيادة، أو رفاهية، ويكفيه في ذلك القدر المحدد لكل فرد من الطعام والشراب والسكن والملبس، ربما لا يختلف كثيراً من شخص لآخر، وبين هذين النظامين (الفردى والجماعى) توجد أنظمة متوسطة تأخذ من كل نظام بطرف، ويتفاوت مقدار الحق المقرر فيها لكل من الأفراد والمجتمع بحسب ما ترمى إليه غايات تلك النظم.

ولو أن تعريف الحق صدر من عباءة المذهب الفردى، فإنه بدون شك سوف يكتسب عدداً من الخصائص التى تعلو قدره وترفع قيمته وتشير إلى أنه المدخل الأساسى لتقدم المجتمع ورفاهيته وقوته على المستوى الدولى، وذلك بخلاف المذهب الجماعى الذى سيمضى على عكس ما ينتهى إليه المذهب الفردى في تعريف الحق، وسيظهر من تعريف فقهاء هذا المذهب له ما يشير إلى ما يستحقه الفرد لإقامة

بنية حياته، وما يلزم لتلك الحياة من الضرورات التي تقيّمها، والتي لا يجوز أن يرتفع حق الأفراد فيها إلى مضاف حقوق المجتمع، فإن الفرد السعيد إنما يكون كذلك بقوة الدولة التي يعيشها فيها، حتى ولو كان جائعاً عرياناً، لا يتمتع من حظوظ نفسه بما هو مكفول للحيوان في المجتمعات الأخرى، ومن ثم يختلف النظر للحق في كل مذهب فكري، ونظام سياسى، وكان اختلاف تلك المذاهب، وهذه الأنظمة من الأسباب المؤدية إلى الاختلاف في تعريف الحق.

وإذا كانت التعريفات التي وردت بالنسبة "للحق" من الكثرة والتعدد بحيث يكون من الصعب حصرها، إلا أن الباحثين في هذا الصدد قد جرى عرفهم على تأصيل تلك التعريفات على النحو الذي يمكن من خلاله أن يتيسر تصور فكرتها، من خلال نظريات أو مذاهب، وينبغي للتعرف بالحق في فقه القانون استجلاء ذلك.

فمن المعروف فقهاً أن تعريفات الحق متعددة متباينة، فهناك التعريف الشخصى الذي يرى أن للحق سلطة إرادية يعطيها القانون لصاحب الحق، وهناك في المقابل التعريف الموضوعى الذي يعرف الحق بأنه مصلحة يحيمها القانون، وهناك التعريفات المختلطة التي تجمع بين التعريفين السابقين، كما أن هناك تعريف الفقيه البلجيكي الأستاذ "دابان" في كتابه عن الحق، ويجدر بمن يريد أن يعطى تصوراً صادقاً لماهية الحق أن يشير إلى تلك الاتجاهات في تعريفه، لأن كلاً منها يركز على زاوية من زوايا الحق، ومن ثم فإن جوهر الحق

لا تكتمل ملامحه ولا تبرز معالمه إلا من خلال إلقاء نظرة على كل من هذه التعريفات.

أولاً: التعريف الشخصي للحق (نظرة الإرادة):

الحق وفقاً لهذا الاتجاه يتمثل في قدرة أو سلطة إرادية يخولها القانون لشخص معين^(١)، وقد قال بهذه النظرية عدد من الفقهاء الألمان المشهود لهم بالتفوق في فقه القانون الخاص، وهم ويند شايد وسافيني وجيرك، وأول ما يلفت النظر في تعريف الحق بأنه قدرة إرادية أمران:

أولهما: أن مضمون القدرة الإرادية الواردة في التعريف قد أثارت فضولاً حول المراد بها، وما إذا كان يعنى أن إرادة صاحب الحق ذات قوة بمعنى أنها تقوم بذاتها، أى أنها سبب كاف لإنتاج الأثر القانوني؟ أم أن المراد أن الحق الذي يسنه القانون يتميز بأنه قدرة إرادية؟ ولعل مما أثار هذا التساؤل أن الأستاذ "سالى" يرى أن للحق علاقة فردية محضة يستمد سببه الأصيل ومصدره الأول من حرية إرادة الفرد، بينما يقرر هو في موضع آخر ومعه كثير من أنصار هذا الاتجاه، أن الحق مهما كان قدرة إرادية، فهو دائماً قدرة في حدود القانون لأن

(١) راجع في عرض هذا الاتجاه: د. شفيق شحاته، محاضرات في النظرية العامة للحق، ص ٨ وما بعدها، طبعة ١٩٤٩م، د. شمس الدين الوكيل: محاضرات في النظرية العامة للحق، ص ٨، طبعة ١٩٥٤م، د. إسماعيل غانم: محاضرات في النظرية العامة للحق، ص ١، طبعة ١٩٥٨م.

القانون هو الذي يمنح هذه القدرة للشخص، ومن ثم كان مضمون تلك القدرة الإرادية الواردة في التعريف مثيراً لهذا التساؤل^(١).

ثانيهما: أن هذه القدرة الإرادية لا يمنحها الشخص لنفسه، وإنما يمنحها له القانون من خلال ضوابط معينة تحدد إطار استعمال الحق وحدوده، وذلك كما في حق الملكية مثلاً، فإن القانون هو الذي يضع وسائل نشأته وأسباب انتقاله وطرق حمايته، فإذا ما أراد الشخص أن ينشئ حق ملكية سلك هذا الطريق الذي رسمه القانون، وكذلك الأمر إذا ما أراد الشخص أن ينقل حقه أو ينزل عنه أو أن يحميه عند الاعتداء عليه، وعليه فإن ما يفيد هذا التعريف أن القدرة الإرادية لا تعنى القدرة الذاتية للشخص بغض النظر عن موقف القانون، ومن ثم فإنه لا يعنى أن حصول الحق يترتب على مجرد الإرادة، وإنما يعنى أن الإرادة إذا تطابقت مع جوهر القانون يكون الإنسان صاحب حق^(٢).

وبمقتضى هذا التعريف يكون الحق: "سلطة أو قدرة يعتبر بها القانون لإرادة فرد معين في أن يجرى عملاً معيناً"، فحق الملكية مثلاً هو سلطة إرادية للشخص بمقتضاها يستطيع أن يستعمل الشيء ويستغله ويتصرف فيه، وحق الدائنين هو قدرة الفرد على أن يقتضي من آخر أمراً أو عملاً أو شيئاً معيناً كمبلغ من المال مثلاً^(٣).

ما يؤخذ على نظرية الإرادة:

(١) د. منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، هامش ١.

(٢) في هذا المعنى: Dabn, op.cit, p. ٥٧.

(٣) د. عبد المنعم البدر، المرجع والمكان السابقان.

وقد لاقى التعريف الذي قرره الإرادة نقداً شديداً في الفقه الحديث، على أساس أنها ربطت بين الحق والإرادة ربطاً غير صحيح، كما أنها خلطت بين قيام الحق واستعماله ومن ثم يكون الخلط واقعاً في أمرين:

أولهما: الربط بين الحق والإرادة: لقد ربطت هذه النظرية بين الحق والإرادة على نحو خاطئ، ولو كان هذا الربط صحيحاً لما أمكن وجود الحق دون إرادة مع أن الواقع يكذب ذلك، إذ أن كثيراً من الحقوق ينشأ بغض النظر عن توافر الإرادة، ذلك أن توافر الإرادة يعنى أمرين، الأول منهما: أن صاحب الإرادة يهدف إلى النتيجة التي تحققت، والثانى: أن يعتد القانون بذلك، فلو أن نتيجة معينة قد تحققت دون علم صاحب الحق لما أمكن القول أنه قد أراد تحقيقها، ولو أنه رغب في تحقيقها ولكن لم تكن له قدرة قانوناً في ذلك لما أمكن القول بأنه قد أراد تحقيقاً أيضاً، فليس كل قصد أو رغبة يعتبر إرادة في نظر القانون، بل إنها لا تعتبر في نظر القانون حتى يتوافر لدى صاحب الحق الإدراك أو التمييز، فالطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره لا يكون لديه تمييز ومثله المجنون، فإذا رغب هذا الطفل أو هذا المجنون في شيء فإن رغبته لا تكون إرادة في نظر القانون إذ ليست له القدرة القانونية على أن يريد، ومن ثم فإنه إذا ما نشأت حقوق لشخص دون أن يعلم أو إذا كانت للصبي غير المميز أو للمجنون حقوق، فإن تعريف الحق بأنه قدرة إرادية يصبح غير صحيح، إذا أن مثل هذه الحقوق كثيراً ما تنشأ دون إرادة من صاحبها، وذلك كما في الميراث والوصية، وكذلك الأمر بالنسبة للصغير غير المميز والمجنون

فإنه تنشأ للشخص بمجرد الولادة وبصرف النظر عن إرادته وربما نشأت له وهو جنين قبل ولادته، أو ليس للصبي والمجنون والجنين حق في الحياة؟ ولو كان الحق متوقفاً على الإرادة لما كان لهما حق الحياة، بل إن هناك حقوقاً تثبت للأشخاص المعنوية، مع أنها ليست لها إرادة^(١).

ثانيهما: الربط بين وجود الحق واستعماله:

إن هذه النظرية قد خلطت بين وجود الحق وبين استعماله، ذلك أن الصورة التي قد تلزم فيها الإرادة هي صورة استعمال الحق، فلو أن شخصاً كان يملك منزلاً ثم أصيب بجنون، لا شك أن حقه يبقى على المنزل ولا ينتهي بالجنون كما سبق القول، لكنه إذا رغب في بيع المنزل فلن يتمكن من ذلك لأنه ليست له إرادة معتبرة قانوناً، فهذا يجب توافر الإرادة لاستعمال الحق عن طريق التصرف فيه، ومن ثم يتضح أن هناك فرقاً بين ثبوت الحق وبين استعماله^(٢)، وحتى بالنسبة لاستعمال الحق، فليست الإرادة بلازمة في كل صور الاستعمال، ففي المثال المتقدم يستطيع المجنون أن يسكن في منزله رغم أنه ليست له إرادة وتكون سكناه - كأحدى صور استعمال الحق - ممكنة ومتصورة قانوناً، ومن ثم

(١) د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص ١ وما بعدها، د. عبد المنعم البدر، المرجع

السابق، ص ٤٤١، د. منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، ص ٩.

(٢) د. أحمد سلامة، المرجع نفسه، ص ٢٤، وقارن: د. جميل الشرقاوى، المرجع السابق،

ص ٢١١، حيث يرى أن الإرادة وإن كانت غير لازمة لكسب الحق إلا أنها لازمة

لممارسته ووضع موضع التنفيذ كما أن هناك صوراً لا يلزم لا توافر الإرادة كسكنى الدار

وركوب السيارة من صبي لا إرادة له.

تكون تلك النظرية حين ربطت بين الإرادة والحق إنما تكون قد خلطت بين وجود الحق وبين استعماله، بل وبين بعض صور استعماله فقط، وبهذا يكون تعريف الحق بأنه قدرة إدارية غير مقبول^(١).
ثانياً: التعريف الموضوعي للحق (نظرية المصلحة):

وتعريف الحق وفقاً لهذا الاتجاه تحكمه نظرية المصلحة^(٢)، وبمقتضاها يعرف الحق بأنه: "مصلحة يحميها القانون"، وقد سميت النظرية التي تحكم هذا الاتجاه بنظرية المصلحة، وبالنظرية الموضوعية على أساس أن أنصارها يعرفون الحق بالنظر إلى موضوعه، وذلك في مقابل تسميه نظرية الإرادة بالنظرية الشخصية حيث تعرف الحق وفقاً لمقتضاها بالنظر إلى شخص صاحبه، ومن زاوية إرادته.

فالمصلحة هي العنصر الجوهرى في الحق وهي غايته وقد تزعم هذا الاتجاه الفيلسوف الألماني (إهرج)، ويبدو من خلال النظر في تعريف الحق وفقاً لموضوعه أنه قد تقادى الإحالة إلى أى دور للإرادة والمصلحة التي يتضمنها حق الملكية حيث تتمثل في قيمة مالية، كما يمكن أن تكون المصلحة معنوية كالحق في الشرف والحرية وغيرهما^(٣).

ووفقاً لتعريف (إهرنج) للحق بأنه مصلحة يحميها القانون، نجد أن الحق يتكون في نظره من عنصرين، أحدهما العنصر الموضوعي،

(١) Marty (G) et Raynaud (P): Droit civil T, I, p. ٢٤١ , No. ١٣٠.

(٢) منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، ص ١١.

(٣) د. حمدى عبد الرحمن، فكرة الحق، ص ١٣، د. فتحى عبد الرحيم عبد الله، المرجع

السابق، ص ٩، د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص ٢٥.

أو المادى، ويتمثل في الغاية العملية التى يحققها الحق لصاحبه، وهذه الغاية هي مصلحة أو مزية أو مغنم معين، أما العنصر الثانى فهو عنصر شكلى، يتمثل في حماية القانون من خلال الدعوى القضائية، فكل حق له غاية معينة يحققها لصاحبه، وهذه الغاية إذا نظرنا إليها في ذاتها وجدناها قيمة مادية أو أدبية وهذه المصلحة المادية أو الأدبية التى يهدف الحق إلى تحقيقها هي في الواقع جوهره، فإذا أضفنا لذلك حماية القانون من خلال الدعوى يتم وجود الحق^(١).

نقد النظرية الموضوعية:

وقد استهدفت النظرية الموضوعية في تعريف الحق بدورها للنقد، ولم يكتب لها الذبوع في الوسط الفقهي، حيث اعترض عليها من وجهين:

أولهما: تعريف الحق بغايته وهي المصلحة:

أن تعريف الحق بالمصلحة، ليس تعريفاً له، وإنما هو تعريف لهدفه أو للغاية منه^(٢)، ولا يمكن منطقياً أن تعطى الشيء نفس التعريف الذي نعطيه لهدفه، فمثلاً لا يستطيع أن أعرف ملكيتي لمنزل بالفائدة التى تعود على من تملك المنزل^(٣)، فهذه الفائدة لن تتحقق إلا بعد قيام الملكية، ومن ثم يبقى السؤال قائماً بلا إجابة، وما هي

(١) راجع في تحليل تعريف الفقيه أهرنج للحق.

(٢) د. احمد سلامة: المرجع السابق، ص ٢٦ ودابان: المرجع السابق، ص ٦٩ وما بعدها.

(٣) دابان: المرجع والمكان السابقين.

ملكيّتي التي يعود منها النفع علىّ؟، فيصير التساؤل إلى دور وتسلسل لا ينتهي.

ثانيهما: الخلط بين المصلحة القانونية والمصلحة الواقعية:

إن هذه النظرية قد جعلت للحق عنصرين: عنصر جوهري وهو المصلحة، وعنصر شكلي وهو الحماية القانونية، واعتبار المصلحة في تعريف الحق، منقوص من ناحية ان هناك مصالح معينة لا ترتفع إلى مرتبة الحق، وإنما تكون حالة واقعية^(١).

ومن أمثلة ذلك ما لو تعاقد شخص يسكن الدور العلوى مع شخص آخر على أن يقوم هذا الأخير بفرش السلم وإضاءته حتى الدور الذي يسكن فيه، فإن سكان الأدوار السفلى يستفيدون من هذا التعاقد، وتكون لهم مصلحة في استمرار الفرش - فهل يؤدي ذلك على فرض امتناع الملتزم عن الفرش والإنارة - أن يطالبوه بإعادتها؟ بالطبع لا!، وكما لو بنى شخص ثرى قصرًا في نهاية القرية وعبد له طريقًا إليه، فإن كل من يسكنون قبل قصره يستفيدون منه، وتكون لهم مصلحة في بقاءه، فإذا أزال المالك هذا الطريق لانتقاله إلى مكان آخر، أو لتغير نشاطه، هل يطالبه المستفيدون بإعادته؟، الحق أنهم ليس لهم ذلك، فالمصلحة هنا مشروعة لكنها لا تمثل حقًا لأنها غير مشمولة بحماية القانون^(٢).

(١) د. احمد سلامة، المرجع السابق، ص ٢٧.

(٢) د. حسن كيرة، المرجع السابق، ص ٥٥٧.

وإذا كانت هذه النظرية قد قدرت أن الحماية ركن جوهري في قيام الحق، حتى ولو كانت ركناً شكلياً، فإنها تكون قد أخطأت أيضاً، لأن الحماية لا يضيفها القانون إلا على حقوق قد قامت بالفعل وتم نشوؤها، فالحماية أثر لقيام الحق، وليست ركناً يسهم في قيامه فهي صفة بعدية، ولا يمكن اعتبار أمر لاحق على قيام شيء معين جزءاً مكوناً لهذا الشيء، وإلا لوقعنا في حلقة مفرغة، فهذا الشيء لن يتكون إلا بتوافر هذا الأمر، وهذا الأمر لن يتوافر إلا بتكون هذا الشيء، ومن ثم كانت تلك النظرية غير صالحة لإعطاء مفهوم صادق للحق.

أساس النظرية الموضوعية في التشريع الإسلامي:

وفكرة النظرية الموضوعية في الحق، أو نظرية المصلحة التي تحمس لها الفقيه (إهرنج) مأخوذة من الفقه الإسلامي، ومقتبسة منه، وإن كان القائلون بها لم ينسبوا الفضل لأهله، ولم يقولوا إن أساسها مأخوذ من التشريع الإسلامي، لا سيما وأن الأمر يتعلق بواقعة مادية غير منكورة فهناك تشابه، أو قل تطابق في البناء الفكري للنظرية بين التشريع الإسلامي، والفقه الجرمانى، والأول سابق والثانى لاحق، وقد انتهت النظم التشريعية لحماية حقوق الابتكار على وجه الخصوص، وحقوق الملكية الفكرية على وجه العموم، ومنذ بدايات التفكير الدولي في تأصيل وسائل تلك الحماية عن طريق اتفاقية (بيرن) في ٩ سبتمبر ١٨٨٦م، وما تلاها من اتفاقيات دولية وعربية وتشريعات محلية ونموذجية، قد وضعت الأصول لحماية تلك الحقوق، وبيان الفرق بين المبتكر صاحب الحق المحمى، والمنتحل الذي سطا عليه،

حين قررت أن الانتحال لحقوق الغير الابتكارية إنما تقع حين يكون هناك مصنفان متشابهان أحدهما سابق والثاني لاحق، فيكون اللاحق منتحلاً للسابق.

بيد أن هذا التشابه ربما يكون قد وقع قبل تقرير أدوات تلك الحماية، فلم يخضع للتأثيم القاضي بأنه لا جريمة إلا بنص، وفي ظل فهم إنساني كلن ينظر على الأفكار كالكأ المباح، ولم يكن يرى باساً من نقلها عبر الأجيال والاستفادة منها عن طريق النقل الكامل أو الجزئي، أو أن ذلك كان هو لمفهوم الدارج للاقتباس عندهم، والذي عدلته الاتفاقات الدولية والتشريعات التي صدرت فيما بعد، وإن كان ذلك لا يتنافى مع وضع الضوابط وتحديد الأصول حتى يعرف كل ذي حق حقه، وينال كل ذي قدر منزلته.

وأساس تلك النظرية مستفاد من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ولى يتيماً له مال فليتجر فيه، ولا يتركه تأكله الصدقة"^(١)، فقد أفاد هذا الحديث أن الزكاة واجبة في مال الصغير، مع أن ذلك الصغير غير مكلف، وربما كان غير مميز، ولا تكليف بدون تمييز، كما أنه لا مساءلة بدون بلوغ، وبناء على ذلك أوجب الفقهاء ضمان المتلفات في ماله ويخرجه عنه وليه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال أخرجته عنه وليه من ماله ثم يأخذه منه عندما يحدث له مال على غرار نظرة الميسرة، وفكرة وجوب الضمان

(١) رواه الشافعي والترمذي والدارقطني، التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول - صلى

الله عليه وسلم - للشيخ منصور ناصف، ج٢، ص٢٢، مطبعة جريدة الأهر.

والتكليفات المالية في مال الصغير وهو غير مكلف لا معنى لها سوى أن التكليف أساسه موضوعي مادي، وليس شخصياً يقوم على الذات المدركة، والقادرة على استيعاب الخطأ وتلافى فعله، ولا تخرج النظرية الموضوعية في الحق عن هذا المعنى.

وهي ليست نظرية معيبة، ولا مفرطة في المساءلة، لأنها تحفظ حقوق المضارين، ولا تسمح بأن يضيع مال أحد هدرًا دون جبر أو تعويض، كما أن الخطأ يجب تحمل تبعته من أولى الناس به، إذا تعذر إسناد الخطأ له لعدم تمييزه، ومن ثم فإن إعمال قانون الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على تلك النظرية، يرجح جانب المصلحة منها على المفسدة، وإذا كان ثمة قصور في إرادة الضامن فإن إرادة وليه تحل محل إرادته، وهي إرادة محبة له، وصادقة في المحافظة على ماله وحقوقه، ولن تكون متهمة في هذا المجال.

ثالثاً: تعريف الحق بأنه قدرة ومصلحة (النظرية المختلطة):

ذهب البعض في تعريف الحق إلى الجمع بين عنصري الإرادة والمصلحة، وهم يسمون لذلك أصحاب المذهب المختلط كما سميت النظرية التي تعبر عن جوهر هذا التعريف للحق بالنظرية المختلطة لذلك، ولأنها تجمع بين النظرتين السابقتين، وبمقتضاها فإن الحق ليس إرادة فقط، وليس مصلحة فقط، وإنما هو جماع الإرادة والمصلحة^(١)، وأصحاب تلك النظرية في تعريف الحق اختلفوا فيما بينهم حول أى

(١) Dabin: Op. cit., pp. ٧٢, ets.

من العنصرين يطغى على الآخر، مع اتفاقهم على ضرورة الجمع بين عنصر الإرادة والمصلحة، فمنهم من جعل اعتبار الإرادة هو الغالب، فقال: إن الحق قدرة إرادية أعطيت لشخص في سبيل تحقيق مصلحة، ومنهم من جعل اعتبار المصلحة هو الغالب فقال: إن الحق مصلحة محمية تسهر على تحقيقها والزود عنها قدرة إرادية^(١).

ويرى الفقه أن هذا الاختلاف ليس بذي قيمة، إذ المهم أن هذا الاتجاه يقوم على الجمع بين الإرادة والمصلحة محققاً بذلك التوازن والتوفيق بين الاتجاهين الشخصي والموضوعي في تعريف الحق^(٢).

الانتقادات الموجهة للنظرية المختلطة:

ويبدو - كما هو واضح - أن النظرية المختلطة تقوم على أنقاض النظرتين المتقدمين الشخصية والموضوعية، ولكن كما يقول الأستاذ الدكتور أحمد سلامة: من قال بأن الأنقاض وحدها تصلح لتشييد بناء سليم؟، ومن ثم فإن تلك النظرية التي حاولت أن تقوم على الأنقاض يجب أن ترفض، لأن الحق ليس إرادة وليس مصلحة، وبالأولى ليس خليطاً منهما، ولهذا لم يبذل الفقه جهداً في رفضها^(٣).

(١) د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص ٢٨، د. عبد المنعم البدر، المرجع السابق، ص ٤٤٤.

(٢) د. نزيه محمد الصادق المهدي - المدخل لدراسة القانون، ج ٢، نظرية الحق، ص ٢٤، دار النهضة العربية.

(٣) د. أحمد سلامة، المرجع نفسه، ص ٢٨، د. نزيه المهدي، الرجوع والمكان السابقان، د. عبد المنعم البدر، المرجع والمكان السابقان.

رابعاً: تعريف الأستاذ دابان للحق:

وقد قام الفقيه البلجيكي الأستاذ "جان دابان"^(١) في مؤلفه عن الحق Le Droit Subjectif والمنشور سنة ١٩٥٢م بشرح النظريات التي قبلت في تعريف الحق ثم تناولها بالنقد والتحليل في محاولة للوصول إلى تعريف محدد وصادق للحق، وقد انتهى من خلال دراسته إلى تعريف الحق بأنه: استئثار بقيمة معينة يمنحه القانون لشخص ويحميه.

وبالنظر في تعريف الأستاذ (دابان) للحق نجد أنه يمكن تحليله إلى عنصرين هما الاستئثار والتسلط، وهذان العنصران عنده بمثابة وجهين لعملة واحدة، من ثم فإن عبارة الاستئثار والتسلط في نظره تكاد تكون كلمة مركبة يسمى بها الحق^(٢).

تعريف دابان للحق بين الصبغة الشخصية والموضوعية:

وقد ذهب دابان في مؤلفه الرئيسي عن الحق، والذي قام بنشره سنة ١٩٥٢م إلى انتقاد المذهب الشخصي البحث للحق بأنه يرتبط بالمذهب الفردي المطلق وبمبدأ سلطان الإرادة وبالأثار المطلقة للحق،

(١) الأستاذ جان دابان، استاذ بجامعة لوفان البلجيكية، وهو صاحب المؤلف المشهور الذي خصص لدراسة الحق، ويُعد هذا المؤلف من أهم الأبحاث القانونية في موضوع الحق وكان له أكبر الأثر في كتابات الشراح في كل من فرنسا ومصر، وإن كان لم يصل فيه إلى تعريف محدد للحق يمكن أن يلقي رضا من الجميع.

(٢) دابان، المرجع والمكان السابقان.

وأن علاج هذا الاطلاق يكون عن طريق إضفاء الصبغة الموضوعية على الحق، والتي من شأنها تحقيق هذا الاطلاق والتقييد من الآثار المطلقة لمبدأ سلطان الإرادة، وعلى أساس ان النزعة الشخصية تعكس الاطلاق، بينما النزعة الموضوعية تبرر التقييد^(١).

ولكن الأستاذ دابان عاد في مقال جديد له منشور في مجلة فلسفة القانون سنة ١٩٦٤م، تحت عنوان: "الحق والنزعة الشخصية" ليقرر أن نظريته في إدخال المفهوم الموضوعي في طبيعة الحق، ليس من شأنه تحويله كلية إلى عنصر موضوعي خالص، بل على العكس من ذلك فإنها ترمى إلى تدعيم المذهب الشخصي في الحق بعد تعديله وتقييده بما يجعله يتقادم الانتقالات الموجهة إلى صورته المتطرفة^(٢).

ولعل هذا التعديل الذي أدخله الأستاذ دابان على أفكاره هو ما جعل بعض الفقهاء المعاصرين يرون أن نظريته تقوم على توازن متعادل بين المذهب الشخصي والموضوعي، وتشتمل على تأثير متبادل لكل من العنصرين الموضوعي والشخصي في الحق، وأن هذا التأثير تظهر معه - في نفس الوقت - أهمية وضرة العنصر الشخصي، ومن ثم تكون نظرية دابان في تعريف الحق على دعامتين:

(١) المرجع نفسه، ص ١٨ وما بعدها.

(٢) دابان، الحق والنزعة الشخصية القانونية، منشور بمجلة فلسفة القانون سنة ١٩٦٤م، ص ٢٩، ومشار إليه في د. نزيه المهدي - المرجع السابق، ص ٢٤ وما بعدها، هامش ٥٥.

الدعامة الأولى: هي الاستثناء والتسلط:

وتتمثل تلك الدعامة في تصوير دابان للحق على أساس أنه استثناء وتسلط^(١)، وبالتالي فإن تلك الدعامة تنشط بدورها إلى عنصرين ؛ أولهما: موضوعي، وثانيهما: شخصي.

أما العنصر الأول، فإنه عنصر موضوعي في الحق يتمثل في اختصاص الشخص بمال معين وقيمة معينة، اختصاصاً يعكس أهمية موضوع الحق، دون أن يرتبط بالإرادة بحيث يكون من الممكن أن يثبت لفاقد الإرادة، كالصبي غير المميز بمعنى أن عنصر الاستثناء ليس أساسه الإرادة ولا المصلحة، وإنما الشيء موضوع الحق، وعليه يكون هذا الاستثناء مستقلاً من ناحية أولى عن المصلحة، فالحق يوجد إذا وجد الاستثناء، فهو جوهر الحق وشيء داخلي فيه، أما المصلحة فإنها ليست جوهر الحق، بل هي هدفه، ومن ناحية ثانية: يتميز الاستثناء عن الإرادة ولا يرتبط بها، لأنه قد يثبت لشخص لا تتوفر لديه الإرادة كعدم الأهلية ولا دخل للإرادة في اكتساب الحق بدليل أن الاستثناء - كعنصر في الحق - قد يثبت لبعض الأشخاص، دون دخل للإرادة مثل الغائب التي تثبت له الحقوق رغم غيابه.

وأما العنصر الشخصي، وهو التسلط، فإنه يعنى سلطة الشخص أو قدرته على التصرف في الشيء محل الاستثناء، طالما أنه يخصه، فالتسلط على الشيء من لوازم استثناء صاحبه به.

(١) تعبير الاستثناء مترجم عن الاصطلاح الفرنسي Appartenance وهو أحياناً يترجم بمعنى اختصاص، وكلمة نسبة أقرب إلى التعبير الدقيق، راجع: د. منصور مصطفى منصور، المرجع نفسه، ص ١٦، هامش (١).

ويلاحظ أن الأستاذ دابان لم يفصل بين عنصري الاستتار والتسلط أو العنصرين الموضوعي والشخصي في تصوير الحق، بل جعل عنصر التسلط لا يفصل عن الأول، بل يتبعه ويكمّله، ولا يمكن أن يكون لغير صاحب الحق، ولما كان الحق في نظره استثنائاً وتسلطاً، وتكون الإرادة غير لازمة لوجود الحق، ومن ثم فإنه قد يثبت للقاصر وعديم الأهلية، وإنما تكون الإرادة ضرورية لمباشرة الحق باسم القاصر، مثل قيام الولى بإلزام التصرفات القانونية باسم القاصر، ولحسابه^(١).

الدعامة الثانية: تتمثل في التبادل:

لما كان الحق بهذا المفهوم النسبي الجديد لم يعد قائماً على سلطان الإرادة أو الاستقلال أو الحرية المطلقة على نحو ما كان معروفاً في التصور الشخصي البحث، وإنما أصبح قائماً على فكرة التقابل بين الحقوق المختلفة لدى الأشخاص بما يستتبع نشأة التزامات متبادلة بينهما لضمان احترام كل شخص لحقوق الآخرين بما يمثل مجرد التقييد من الطبيعة الشخصية البحتة لهذا الحق، ويحقق لها النسبية والتوازن^(٢)، بين صاحب الحق والغير، على نحو يضمن احترام الحق وعدم التعدي عليه، وبما يمكن صاحب الحق من اقتضاء هذا الاحترام استناداً إلى الحماية القانونية المقررة لهذا الحق^(٣).

(١) DabinL Op, cit., p. ٨٨.

(٢) في هذا المعنى: د. نزيه المهدي، المرجع السابق، ص ٢٦.

(٣) د. منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، ص ١٨.

وبعد هذا التحليل انتهى الأستاذ دابان إلى تعريف الحق بأنه: "ميزة يمنحها القانون لشخص ويضمنها بوسائله وبمقتضاها يتصرف في قيمة^(١) منسوبة إليه، باعتبارها له أو مستحقة له.

وقد أخذ بتعريف الأستاذ دابان للحق، مع شيء من التغيير كثير من الفقهاء المحدثين في مصر، فذهب البعض إلى تعريف الحق بأنه: استئثار شخص بقيم أو أشياء معينة يخول له التسلط والاقتضاء ويهدف إلى تحقيق مصلحة يحميها القانون، لأنها ذات قيمة اجتماعية^(٢)، أو هو استئثار شخص بقيمة معينة استثنائاً يحميه القانون عن طريق التسلط والاقتضاء بغية تحقيق مصلحة لهذا الشخص يراها المجتمع جديرة بالحماية^(٣)، أو هو: تلك الرابطة التي بمقتضاها يخول القانون شخصاً من الأشخاص - على سبيل الإنفراد والاستئثار - التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر^(٤)، أو هو: استئثار بشيء أو بقيمة استثنائاً يحميه القانون^(٥).

(١) يلاحظ أن الأستاذ دابان يستعمل أحياناً كلمة قيمة Valeur ويستعمل أيضاً لفظ Bien، ولا يقصد به معناه الفني في لغة القانون أي (المال)، وإنما يقصد كل ما له قيمة سواء كانت القيمة مالية أو أدبية، راجع: د. منصور مصطفى منصور، المرجع نفسه، ص ١٦، هامش (١).

(٢) د. شمس الوكيل، المرجع السابق، ص ١١، حيث أخذ في تحليل التعريف على نحو ما فعل الأستاذ دابان.

(٣) د. إسماعيل غانم، المرجع السابق، ص ١٧.

(٤) د. حسين كيره، المرجع السابق، ص ٥٦٧.

(٥) د. توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص ٣٣.

كما عرفه البعض بأنه: "استثثار يقره القانون" مع التنبيه إلى أنه يقصد بالاستثثار المعنى الذي أورده الأستاذ دابان، فهو اختصاص بقيمة معينة سواء كان اختصاصاً لا يقتضي تدخلاً من أحد، أو كان اختصاصاً يقتضي مثل هذا التدخل، مع الإشارة إلى أن الحماية لا تعتبر عنصراً من عناصر الحق^(١).

تقدير نظرية الأستاذ دابان:

ورغم أن تعريف الأستاذ دابان للحق كان له أثر بالغ في الفقه إلا أنه لم يسلم هو الآخر من النقد، وكان مما أخذ عليه من ملاحظات يتمثل فيما يلي:

أولاً: فيما يتعلق بعنصر الاستثثار، فقد جعله الأستاذ دابان مجرد عنصر من عدة عناصر قد تصل إلى أربعة، يتكون من مجموعها مضمون الحق، ويجعل اختصاص شخص بقيمة أو مال معين دون سائر الناس هو بعض معنى الحق، مع أنه يعنى كل معنى الحق، بل مرادف لمعناه، ذلك أن معنى الحق يتمثل في استثثار شخص بقيمة أو مال دون سائر الناس^(٢).

ثانياً: لقد عرف الأستاذ دابان الحق بأن ميزة دون أن يرد في تعريفه السابق، ما يبين معنى الميزة ودون أن يشرح مقصده منها بمناسبة التعريف مما يسمح له بمعنيين هما القدرة والمصلحة، ومن ثم فإن

(١) د. أحمد سلامة، المرجع نفسه، ص ٣٤ وما بعدها.

(٢) د. جميل الشرقاوى، المرجع السابق، ص ٢١٨.

علينا أن نختار لها في تعريفه أحد هذين المعنيين، وبالرجوع إلى باقى عبارات التعريف، وعلى الخصوص قوله: إن هذه الميزة تجعل للشخص أن يتصرف في المال أو القيمة، يظهر أن الميزة مهنها في تعريفه: السلطة أو القدرة، ومن ثم يبدو أنه يأخذ بتعريف الحق يجمع بين القدرة والمصلحة، وعليه فإنه يكون قد وقع أسيراً للمذهب المختلط والمنتقد^(١).

ثالثاً: أن التعريف الذي قدمه الأستاذ دابان، ينطوى على فصل بين واجب احترام الناس للحق والتزامهم به، وبين الوسيلة التى يقع بها اقتضاء هذا الواجب إذا وقع إخلال به، أى يفصل بين القدرة على الاقتضاء وبين الحماية القانونية التى تجعل لصاحب الحق استخدام وسائلها من الدعاوى والدفع وغيرها، والتى يقع بها هذا الاقتضاء وهو فصل غير منطقي وعديم الفائدة^(٢).

وقد انتهى الأستاذ جميل الشرقاوى إلى اقتراح تعريف للحق حاصله: أنه قدرة لشخص من الأشخاص على أن يقوم بعمل معين، يمنحها القانون ويحميها تحقيقاً لمصلحة يقرها^(٣).

(١) في هذا المعنى: د. جميل الشرقاوى، المرجع السابق، ص ٢١٩.

(٢) لمرجع نفسه، ص ٢١٨، وانظر هامش (١) حيث يقول: ولا يفوتنا بسبب اعتبار دابان الحماية عنصراً في الحق أن نذكر أنه أخذ من قبل على الفقيه إهرنج، وهو يعدد نقد تعريفه للحق، أنه قد اعتبر الحماية ركناً في الحق ثم عاد في تحليله للحق واعتبرها عنصراً فكأنه قد أوقع نفسه فيما أخذه على الفقيه إهرنج.

(٣) المرجع نفسه، ص ٢٢٠.

التعريف الراجح في نظرنا:

والتعريف الراجح لدينا، هو ما انتهى إلى إقتراحه الأستاذ الدكتور جميل الشرقاوى، لولا أن تركيب عباراته يشوبها بعض الاستطراد وعدم الترتيب، وعن التزامنا بالعناصر التى يقوم عليها هذا التعريف، فإننا يمكن ان نصوغه على النحو التالى:

أولاً: أن الحق قدرة يمنحها القانون ويحدد نظامها حتى لا تتعارض الحقوق المختلفة ويساء استعمالها، كما أن القانون هو الذي يحمى تلك القدرة، وهو الذي يضمن لها أسباب الحماية التى تمنع التعدى عليها.

ثانياً: إن هذه القدرة تثبت لشخص معين من جهة أنه صاحب الحق، أو أنه هو الذي يستأثر بجانب الدائنية فيه، وقد يكون هذا الحق تداولياً وقد يكون تبادلياً، فهي ليست قدرة نظرية، وليست فكرة خيالية وإنما تثبت لشخص محدد هو الذي يستعملها، وهو الذي يسأل عنها ويخاطب بشأنها.

ثالثاً: أن هذه القدرة هدفها تحقيق مصلحة يستفيد منها هذا الشخص وتعتبر بالنسبة له غاية يسعى لتحقيقها، وعليه فلو أن تلك القدرة أدت إلى الضرر أو إلحاق الأذى بشخصه أو ماله فإنها لا تكون حقاً، بل تكون عبئاً والتزاماً.

المبحث الثانى

تمييز الحق عما يختلط به في القانون

وإذا كنا قد اخترنا تعريف الحق بأنه: قدرة يمنحها القانون ويحددها ويحميها لشخص معين تحصيلاً لمصلحة مشروعة، فإنه بهذا المعنى قد يختلط بعدد من المسائل التى قد تشتبه معه أو تختلط به، وذلك مثل المصلحة، والسلطة، والمكنة والحالة الشخصية، والأمل والرخصة، ونسير إلى ما يميز الحق عن هذه المصطلحات:

أولاً: الحق والمصلحة:

المصلحة هي الغرض العملى من الحق والغاية المرجوة منه، وأنها ليست الحق في ذاته، حقيقة فإن كل حق ينطوى على مصلحة، ولكن ليست كل مصلحة توجد ضمن حق، فهناك مصالح يحميها القانون، دون أن يعطى صاحب المصلحة الوسيلة إلى تحقيق هذه الحماية حيث لا تقوم بها الدولة، وذلك مثل حماية الدولة للنظام العام، فإن من شأن حمايته حماية مصالح خاصة للأفراد، كما لو قرضت الدولة ضريبة على نوع معين من الواردات بقصد زيادة إيراداتها فيترتب على ذلك حماية المنتج المحلى^(١)، وكذلك حماية الأمن العام، يؤدي إلى تهيئة المناخ للأفراد حتى يستثمروا أموالهم، ويزيدوا دخولهم، ويحققوا مصالحهم.

(١) د. عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص ١٩، د. نعمان جمعة، المصدر السابق، ص ٣١٣.

ثانياً: الحق والسلطة:

والسلطة عنصر أصيل من الحق، ذلك أن الحق لا بد أن ينطوى على سلطة، ولا يمكن أن يوجد حق بدون سلطة ولكن قد توجد سلطة لشخص لا يكون له حق كسلطة الوصى أو النائب^(١)، والسلطة لا بد لمباشرتها من إرادة لدى من يباشرها، أما الحق فلا يشترط لاكتسابه وجود الإرادة عند صاحبه، فعدم الأهلية يصلح لاكتساب الحقوق، ولكنه لا يستطيع أن يباشر السلطات التي تنشأ من هذه الحقوق وإنما يباشرها عنه وليه أو وصيه.

ثالثاً: الحق والمكنة:

المكنة هي الميزة التي ينطوى عليها الحق وليس هي الحق في ذاته، ففي حق الملكية يكون للمالك الانتفاع مباشرة بالشيء المملوك له، وفي الحق الشخصي يكون للدائن مكنة مطالبة المدين بالدين. ويتفرع على ذلك أنه إذا صح أن أقول: أن لي حق ملكية على كتابي فلا يصح أن أقول: أن لي الحق في أن أغير هذا الكتاب أو أن أرهقه أو أن أبيعته أو أن أمزقه، فتلك مجرد مكنات تعتبر وسائل لاستعمال الحق، وليست هي حق الملكية.

ثم أن الحق ذو طابع مستقبل فهم ينشأ من العلاقة القانونية ثم يستقل بعد ذلك عنها، ويكون له كيان قائم مستقل بذاته عن العلاقة

(١) د. نعمان جمعة، المرجع السابق، ص ٣١٦، مع أن ممارسة سلطاته وولايته على الموصى عليه، أو مع النائب تعد - في حد ذاتها - حقاً.

التي استمد منها كيانه، فعقد البيع ينشئ للمشتري حقاً عينياً هو حق الملكية، وبمجرد أن ينشأ هذا لحق، يكون له وجوده المستقل عن عقد البيع.

أما المكنة فلا تنشأ من العلاقة القانونية، وإنما تنشأ من الحق وتبقى ما بقي من الحق وتتقضى بإنقضائه، فهي تابعة له وليس لها وجود مستقل عنه، فلا تسقط وحدها بالتقادم، بل تسقط تبعاً لسقوط الحق ويكون استعمالها لصاحب الحق وحده ما لم تتفصل عن الحق بفعل صاحبه كما لو نزل المالك عن مكنة الانتفاع بملكه لغيره على سبيل الإيجار أو عارية الاستعمال.

رابعاً: الحق والحالة الشخصية:

الحالة الشخصية هي صفة قانونية دائمة بحسب الأصل تتوافر في الشخص، وينشأ له منها حقوق، بل وواجبات في بعض الأحيان، فهي ليست حقاً وإنما هي مصدر لحق، مثل أن يكون الشخص زوجاً، فهذه حالة شخصية يتفرع عنها أن يكون له حق الطاعة على زوجته، أو يكون الشخص أباً فهذه حالة شخصية يترتب عليها وجوب الإنفاق على ولده، أو يكون الشخص وارثاً، فيترتب على تلك الحالة الشخصية حق الإرث، فهذه كلها صفات قانونية، تمثل حالات شخصية وليست حقوقاً.

خامساً: الحق والأمل:

إن الأمل عبارة عن حق ناقص، فهو حق في دور التكوين، أو هو جرثومة حق ينقصه أحد عناصر وجوده، ومن أمثلة الأمل:

(١) أن يعلق الطرفان تصرفاً من التصرفات على تحقق واقعة مستقبلية غير محققة الوقوع، كأن يوصى شخص بكتبه لزيد إذا حصل هذا الأخير على الليسانس قبل أن يبلغ سن الرشد فالموصى له تحت شرط يعتبر صاحب أمل وليس صاحب حق.

(٢) كذلك واضح اليد على عقار بنية التملك ليس له على هذا العقار قبل اكتمال مدة التقادم، إلا مجرد الأمل وتكون حماية القانون لهذه الآمال بأن يسمح لأصحابها أن يتخذوا إجراءات تحفظية، ففي حالة الوصية المعلقة على شرط يجوز للموصى له أن يطلب إلى الوارث أن يقدم إليه ضماناً يكفل له الحصول على الشيء الموصى بهد عند تحقق الشرط، وعندئذ فلا يخلو الأمر إما أن يمتنع تحقق العنصر الناقص فيزول الأمل، وإما أن يتحقق فيكتمل الحق^(١).

سادساً: الحق والرخصة:

الرخصة هي الخيار الممنوح لشخص معين، والذي بمقتضاه يسمح له القانون بأن يعدل من مركزه القانوني وفقاً لمصلحته وفي

(١) د. عبد الحي حجازي، المرجع نفسه، ص ٢٢.

حدود هذه المصلحة، فهي نوع من إمكانية الاختيار مستمد من القانون بأن يغير مركزه القانوني.

ويتضح من هذا التعريف أن الرخصة لا تطابق كل حالة يكون فيها خيار بين أمرين، فلا بد وأن يكون الخيار مصدره القانون وأن تكون ممارسته بقصد إنشاء أو تعديل مركز قانوني، ومثال ذلك الرخصة الممنوحة للموصى له بأن يقبل الوصية أو يرفضها، والرخصة الممنوحة للشريك في المال الشائع بأن يطلب القسمة أو لا يطلبها.

فالرخصة تقترب من الحق أن كلاً منهما يستمدان وجودهما من القانون، وفي كون وجودهما وممارستهما يخضعان لعقود وشروط وضعها القانون، كما تختلف الرخصة عن الحق من حيث إن مجالها يكون في مرحلة إنشاء المراكز القانونية، وليس في مرحلة آثار هذه المراكز.

ويلاحظ أن الرخصة تختلف عن الحرية في أن الأخيرة وإن كانت تعطى لصاحبها اختياراً بين البدائل، إلا أن البدائل في الرخصة محدودة، وفي الحرية مجال الاختيار مفتوح بغير حدود ولا قيود وبغير إمكانية التوقع مقدماً^(١).

(١) د. نعمان جمعة، المرجع نفسه، ص ٣١٣ وما بعدها.

الفصل الثانى

تصنيف الحقوق والمعيار

الذي تقوم عليه

جرى الفقه التقليدي على أن تصنيف الحقوق المختلفة كان - ولا يزال - محل جدل كبير في الفقه واختلاف بين وجهات نظر الفقهاء فيه، وهذا الاختلاف منشؤه اختلاف الأساس الذي أقام كل فقيه عليه تصنيفه، والذي يستند بصفة خاصة على وصف كل حق على دون اعتبار للوحدة الموضوعية بينها، ولهذا فإنه - غالباً - ما يقع الخلط عند كثير من الفقهاء وهم بصدد الحقوق المختلفة، بين أنواع الحقوق وأوصافها، مع أن تصنيف الحقوق إلى حقوق مالية، وحقوق غير مالية أصبح مسلماً به في الفقه، وبمقتضاه ذهب البعض إلى أن ما ذكر فوق ذلك في كتب الشراح مجرد أوصاف لهذين النوعين، دون أن يرقى لأن يكون أنواعاً قائماً بذاتها، ومن ثم فإنه هذا التصنيف يعتبر عند أصحاب هذا الاتجاه حرياً باعتباره والسير على منواله^(١).

وأساس اختلاف وجهات النظر في شأن تقسيم الحقوق، هو اختلاف الزاوية التي استمدت منها كل وجهة المعيار الذي تبنى عليه تقسيمها، ومن ثم فقد اختلفت تصنيفات الحقوق تبعاً لذلك^(٢).

(١) د. نعمان محمد جمعة، المرجع السابق، ص ٣١٩، حيث يقرر أن التصنيف الأساسي للحقوق، هو حقوق مالية وحقوق غير مالية، وذلك لما له من أهمية قانونية، ومن ثم اختاره أساساً للدراسة، وفي نفس المعنى: د. عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص ٢٤.

(٢) راجع في ذلك: Dabin: Op.cit,p. ١٠٠, ets, Marity et Raynaud. والدكتور أحمد سلامة، المرجع نفسه، ص ٤٥، د. حسن كيرة، المرجع نفسه، ص ٥٧١ وما بعدها؛ وقد ذهب رأى إلى أن الحقوق تنقسم إلى حقوق مطلقة، وحقوق نسبية والأولى هي التي

وقد ذهب كثير من الفقهاء الذين استلقت أنظارهم أهمية تلك المسألة إلى أنه من الأوفق أن يؤخذ في الاعتبار نوع القيمة التي يخولها الحق، وقسموا الحقوق على أساسها، إذ أن نوع القيمة يقدم معياراً واضحاً للتقسيم، فضلاً عن أنه معيار معترف به في الفقه منذ القديم، وهذه القيمة قد تكون مالية، وقد تكون غير مالية، فيقال تبعاً لذلك: إن الحق مالي أو غير مالي، ومعنى أن القيمة مالية، أنها يمكن أن تقدر بالمال، ومعنى أنها غير مالية أنها لا يمكن تقديرها بالمال، أو أنها يمكن أن تقدر بالمال، لكن القانون الذي اعترف بها وأقرها لا يسمح بالتصرف فيها، وذلك مثل الحقوق السياسية أو الحقوق الشخصية مثلاً، على أن أساس تقدير الحق بالمال يتمثل في إمكانية الاعتياض عنه^(١).

فإن قيل أن من الحقوق غير المالية ما يستتبع آثاراً مالية، وذلك مثل حق البنوة يستتبع الإرث، وحق النجاح يستتبع آثاراً مالية تنجم عنه، فإن رد مثل هذا الاعتراض يتمثل في تلافي الخلط بين الحق في ذاته، وبين النتائج التي تترتب عليه، والتي قد تسفر عن حقوق مالية مع كونه حقاً غير مالي، فحق البنوة وحق الإرث حقان منفصلان، ولا يقدح في كونهما كذلك أن الثانى يكون نتيجة للأول، لكننا إذا اتبعنا معيار الاعتياض لاتضح لنا حقيقة الحق فيهما،

يحتج بها في مواجهة شخص معين أو أشخاص معينين (كحق الدائنة)، بينما ذهب رأى إلى تقسيم الحقوق إلى حقوق فردية، وهي متى تثبت للشخص اعتباره فرداً، وحقوق جماعية، وهي التي تثبت لشخص اعتباره عضواً في جماعة.

(١) د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص ٤٦.

حيث لا يجوز لي أن اعتاض عنه، ومن ثم يكون الحق فيهما غير مالى، وبالتالي يكون هذا المعيار هو معيار النظر إلى القيمة التى يخولها الحق بصرف النظر عن الأوصاف التى تعتريه.

وبالنظر إلى نوع القيم التى يخولها الحق يرى أصحاب هذا الاتجاه: أن بعض تلك الحقوق يخول قيماً مالية، وبعضها يخول قيماً غير مالية، وبعضها الآخر يخول قيماً ذات طبيعة مزدوجة مالية وغير مالية وساروا في دراسة أنواع الحقوق وفقاً لذلك التقسيم الذى التقى عليه جمهور الفقهاء، ولا يكاد باحث يعثر لغيرهم على خروج عما قالوه.

التفرقة بين الحقوق التداولية والحقوق التبادلية:

وفي نظرنا أن التصنيف السابق لا يعتبر عن حقيقة الواقع الذى يشير إلى أن هناك بعض الخصائص التى تتسم بها طائفة أخرى من الحقوق، وتصلح بها أن تكون نوعاً متميزاً بذاته ومختلفاً عن كافة تلك الأنواع التى انتهى إليها الفقه التقليدي، بل إن تلك الخصائص تجعل من هذه الحقوق كياناً مستقلاً وقائماً بذاته يقف عند الند لتلك الحقوق المعروفة، ويمثل الغصن الثانى للصل الذى تتبع منه، وإذا صح أنا ما وصل إليه الفقه التقليدي من أنواع تلك الحقوق لا يخرج عن طبيعته التبادلية التى تجعل كل حق مقروناً بواجب، وأنه حيث يوجد عنصر الدائنية في الحق، فإن عنصر المديونية لابد أن يكون موجوداً على الوجه الآخر لذلك الحق، حتى قيل: إنه لا يوجد حق

بدون واجب أو مديونية إلا حق الله سبحانه، وما يلحق بهذا الحق المتميز من حقوق الضعفاء والفقراء والمرضى والمحتاجين، ومن قبل تلك الحقوق حقوق الوالدين، فإنه يوجد في مقابل تلك المجموعة مجموعة أخرى من الحقوق، يمكن تسميتها بالحقوق التداولية، التي لا يرتبط العنصران فيها على نحو متزامن، وإنما يتراخى فيها المقابل إلى أجل مسمى قد يمتد إلى نهاية عمر الإنسان، أو حين يشارف تلك النهاية، ومع أن تلك المجموعة من الحقوق ذات طبيعة متميزة، وتحتوي أنواعاً متعددة منها إلا أن أحداً من الفقهاء لم يعرها اهتماماً، وربما كانت تلك الدراسة هي أول الغيث في دراسة تلك الحقوق وإبراز أهميتها في الحياة.

ولهذا فإننا سوف نتجه في بيان تصنيف الحقوق إلى قسمين أساسيين هما: الحقوق التداولية، والحقوق التبادلية، وذلك على أن نعالج كل قسم في بحث على حده.

المبحث الأول

الحقوق التداولية

إذا كانت فكرة الحقوق التقليدية تقوم على التبادل الذي يقترن الحق فيه بالواجب ولا توجد الدائنية إلا إذا اقترنت بها المديونية، فإن الحقوق التداولية تقوم على العطاء الذي يقدم عنصر المديونية فيها على عنصر الدائنية، ولا يوجد هذان المركزان المتضادان في وقت واحد معاً، وإنما يتراخى عنصر الأخذ أمداً طويلاً من الزمان، حتى يبدو وكأن عنصر العطاء وحده هو المكون لهذه المجموعة من الحقوق.

في الحقوق التبادلية تمثل المراكز المتضادة لأطراف الرابطة القانونية، باعتبارها سبباً للحق أو مصدراً له، وسيلة من وسائل الضغط المتبادل بين الطرفين حتى ينفذ كل منهما التزامه، فحق البائع في استيفاء الثمن يقابله واجب المشتري في بذله، وحق المشتري في قبض المبيع يقابله حق البائع في قبض الثمن، ولهذا توجد الحقوق في صورة تبادلية، ففي الإيجار يقابل حق المؤجر في قبض الأجرة حق المستأجر في استيفاء المنفعة، وحق الزوج يقابله حق المجتمع، وحق الحاكم يقابله حق المحكوم، وقل مثل ذلك في كافة أنواع الحقوق التي تشتمل مصالح أطرافها فيها موقف الند للند، والطالب للمطلوب والدائن للمدين، ولهذا يرد عليها الفسخ والحبس، والدفع بعدم التنفيذ، حيث تعد تلك الأدوات القانونية وسائل قررها القانون للطرفين حتى يلزم كل منهما صاحبه في تنفيذ ما التزم به.

أما في الحقوق التداولية، فإن مبناها على البذل العجل والأخذ الآجل، والدفع المقدم والقبض المؤخر، ولهذا يبدو فيها جانب الإيثار واضحاً، كما يظهر فيها معنى التكافل الذي يراعى في اعتباره حاجة المحتاج، وظروف العاجز، وينظر إلى واقع الحياة من جهة أن القوى يجب عليه أن يتحمل الضعيف، وأن القادر يجب عليه أن يتحمل العاجز، ومن ثم كانت تلك الطائفة من الحقوق تجسداً للاعتبارات الإنسانية في التعامل، وأداة لتخفيف حدة الصراع على المادة وتهذيب نزعة الاستعجال في تحصيلها.

لقد سبق تعريق الحق بما يبرز فيه أنه مصلحة مقررة للإنسان، ويكون بمقدوره أن يحصل عليها بسيف القوة وسلطان القانون، وهذه المصلحة لا تسلم من ملازمة مصلحة أخرى منافسة لها، بحيث يتوقف استحقاق أحدهما على استحقاق الأخرى إعمالاً لمبدأ التزم بين الحق والواجب أو الدائنية والمديونية، وإذا كان ذلك التلازم هو السمة الغالبة لمجموعة الحقوق التي انتهى الفقه إلى تصنيفها، فإن ذلك التلازم ينفك في الحق التداولي، حيث يبدأ ذلك الحق بالمديونية وينتهي للدائنية فيما بعد، وعندما تتوافر في الدائن شروط ذلك الاستحقاق، ومن ثم تستحق المصلحة في الحق التداولي مآلاً، وليس حالاً، فهو يبدأ من حيث انتهى الحق التبادلي، وعلى ضوء ذلك التمهيد فإن الحق التداولي وإن كان مع الحق التبادلي في مضمون المصلحة، وأنها قد تكون مصلحة مادية أو أدبية مقررة بحكم القانون وحمايته، إلا أنها تستحق على سبيل التداول، أي تستحقها الأجيال المتعاقبة جيلاً بعد جيل وأمة بعد أمة.

والتداول لغة: من دال، أي انتقل من حال إلى حال، ومنه التداول، مثل: تداولت الأيدي الشيء، أي أخذته هذه مرة، وهذه مرة، ودواليك، أي: تداول بعد تداول على سبيل التعاقب والتوالي^(١)، وفي التنزيل الحكيم يقول الله تعالى: {وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}^(٢)، أي يصرفها الله بينهم فيجعل القوة فيها لقوم مرة، ولغيرهم مرة أخرى^(٣).

(١) المعجم الوجيز، ص ٢٣٩.

(٢) سورة الحشر - من الآية ٧.

(٣) لقاموس القويم للقرآن الحكيم، المرجع السابق، ج ١، ص ٢٣٧.

ووصف الحق بالتداول: يعنى أن المصلحة فيه مستحقة على سبيل التوالى والتعاقب بين الأجيال، ومن يفقدونها مرة سوف يجدونها مرة أخرى، وعلى هذا يمكن تعريف الحق التداولى بأنه: "مصلحة يقررها التشريع مآلاً لشخص يبذل مقابلها حالاً"، فالدائن في الحق التداولى لا يقتضي حقه وقت تقديم الالتزام المقابل له، ولكنه يقتضيه مآلاً، وبعد مدة قد تستغرق كل عمره أو قرب نهايته، وحين تتوافر فيه شروط استحقاق ذلك الحق، كما أن دفع المقابل قد يكون على سبيل الحقيقة، وقد تكون دفعاً حكيماً في حال عجزه أو عدم قدرته على بذل هذا المقابل، وذلك كما فى حقوق المعاشات والرعاية الاجتماعية للعاجزين عن الكسب وأمثال ذلك.

المبحث الثانى

الحقوق المالية

وهي تنقسم إلى قسمين - وفقاً لما جرى عليه التقسيم التقليدى لها - الحقوق غير المالية والحقوق المالية، ونخصص لبيان كل منها مطلباً.

المطلب الأول

الحقوق غير المالية

الحقوق غير المالية تتمثل في الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان، وحقوق الأسرة.

أولاً: الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان (حقوق الشخصية):

وحقوق الشخصية يعتبر من الاصطلاحات الشائعة والخلابة، لكنه رغم شيوعه ورنينه لا يعبر بوضوح عن الحقوق التى تدخل في

مدلوله، لأننا لو نظرنا بتدقيق لوجدنا أن كل أنواع الحقوق مسخرة لخدمة الشخص سواء أكانت حقوقاً مالية أم غير مالية، بل أن الغاية من وجود القانون هي "كفالة حياة منظمة للفرد عن طريق تنظيم الحقوق"، ولكن بعض هذه الحقوق قد يكون ذا صلة وثيقة للشخص، وبعضها قد لا يكون كذلك، ومعنى الاتصال الوثيق للحق بشخص الإنسان، أن يثبت الحق لكل فرد في المجتمع لمجرد أنه إنسان بصرف النظر عن أى اعتبار آخر، وهذا هو المراد من اصطلاح حقوق الشخصية^(١)، رغم اختلاف إطلاق التسميات على تلك الطائفة من الحقوق، كالحقوق الطبيعية، أو الحقوق العامة أو حقوق الإنسان، فإنها تتوخى غاية واحدة تمثل في ضمان حماية الشخصية وإزدهارها، وقد درجت بعض التشريعات، ومعها بعض الفقه إلى تحديد قائمة تضم تلك الحقوق على غرار ما فعل القانون السويسري، لكان القانون المدني المصري لم يساير تلك التشريعات - وقد أحسن صنعاً - حين اكتفى بإضفاء حمايته عليها، عندما نص في المادة (٥٠) منه على أن: "لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر، لاتفاق غالبية الفقه على عدم جدوى وضع قائمة تضم تلك الحقوق^(٢)، واستقراره على ردها إلى مجموعات ترتبط فيما بينها بوحدة الغرض وهو اتصالها الوثيق بشخص الإنسان وضرورتها

(١) د. أحمد سلامة - المرجع نفسه - ص ٤٨.

(٢) المرجع نفسه، ص ٤٩، وراجع: د. عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص ٢٦.

لحمايته، وهذه المجموعات يمكن ردها إلى مجموعات ثلاث^(١)، تهدف الأولى منها إلى حماية كيان الشخص، وتهدف الثانية إلى تمييزه عن الأولى، وتكفل الثالثة له مزاوله نشاطه والتعبير عن أفكاره.

(١) الحقوق التي تتعلق بحماية كيان الإنسان:

ومما يدخل ضمن حقوق المجموعة الأولى، وهي التي تهدف إلى حماية كيان الشخص، الحقوق التي تحمي الكيان المادي حق الشخص في الحياة وحقه في سلامة جسده، وفي عدم انتهاك حرمة بعد الموت، وحقه في التصرف المادي والقانوني. وكذلك يدخل ضمن تلك المجموعة: الحقوق التي تحمي الكيان الأدبي، كالحق في الشرف والاعتبار، وكل ما يتعلق بالمقومات المعنوية للشخص.

(٢) حق الإنسان في تمييز ذاته:

ويدخل تحت تلك المجموعة من الحقوق التي تهدف إلى تمييز الشخص في ذاته وتحديد عن غيره، الحق في الاسم والحق في الشكل، والحق في السرية، ومن المؤكد أن القانون يحمي حق الإنسان في اسمه مهما كانت طبيعته^(٢)، وأما الحق في الشكل فإنه يتمثل في حق الإنسان أن يمنع نشر صورته أو تقليد سحنته، وأما الحق في السرية فهو ينطوي على عدم إذاعة صفات الشخص المادية والمعنوية التي لا يريد لغيره أن

(١) د. أحمد سلامة، المرجع نفسه، ص ٥٠.

(٢) مجموعة الأعمال التحضيرية، ج١، ص ٣٦٣.

يعلمها، ومن هذا المنطلق فقد كفل القانون سرية المخابرات، ونظر
إذاعة ما يصل إلى علم الشخص عن طريق مهنته^(١).

(٣) حق الإنسان في التعبير عن أفكاره:

ويدخل في نطاق تلك المجموعة التي تتعلق بحق الإنسان في
مزاولة نشاطه والتعبير عن أفكاره، حرية الغدو والرواح وحرية التفكير
وحرية التعبير، وحرية الاعتقاد وحرية العمل وحق الشخص على نتاج
ذهنه من الأعمال التي تكون من ابتكار الإنسان وإنتاجه.

ولا شك أن احترام الشخصية الإنسانية والتسليم للإنسان بحرياته
العامة يقتضي أن يعترف له على إنتاجه الذهني من أفكار وأخيله،
بالحقوق التي تسمح لصاحبها أن يكون مهيمناً عليها، فتنسب إليه
وبحق له نشرها أو منعها من النشر أو تعديلها على الصورة التي
تتراءى له، كما تجعل له أن يتحكم في ثمارها واستغلالها فيستأثر
بالفوائد المالية التي قد تنتج من هذا الاستغلال، هذه الحقوق التي تنشأ
للفرد على هذا الإنتاج الذهني هي التي تسمى بالحقوق الذهنية
أو المعنوية ومنها الحق الأدبي للمؤلف^(٢).

خصائص حقوق الشخصية:

ولحقوق الشخصية خصائص تتميز بها ويتحدد مفهومها من

خلالها، وهذه الخصائص هي:

(١) د. أحمد سلامة، المرجع والمكان السابقان.

(٢) د. جميل الشرقاوى، المرجع نفسه، ص ٢٥١.

(١) إنها حقوق مطلقة:

ومعنى أنها حقوق مطلقة أن الالتزام بها يقع على عاتق الكافة قبل صاحب الحق، لأن حق الفرد يقابل واجب سلبى عام مؤداه أن يتمتع الكافة عن الاعتداء على هذا الحق.

(٢) أنها حقوق لا تقوم بالمال:

ومعنى أنها لا تقوم بالمال، أنها لا تجرى عليها المعاوضة أصلاً، ومن ثم فإنها لا يمكن أن تقاس بالمقياس الذي تقاس به الأموال وهي النقود.

وليس معنى ذلك أن الاعتداء على هذه الحقوق لا يستحق عنه تعويض نقدي، لأن الاعتداء على هذه الحقوق قد يترتب عليه ضرر مالى مباشر، كما في حالة الاعتداء على حق المؤلف، أو غير مباشر كما في الاعتداء على الكيان الجسدى للشخص، في هذه الحالات لا جدال في وجوب التزام بإصلاح الضرر، حتى في الضرر الأدبى الذي يصيب النفس من ألم وحزن، فإن يستأهل التعويض الذي يقدر غالباً بالتقريب من منطلق أن التعادل الحسابى الكامل بين الضرر والتعويض ليس ممكناً حتى في الأضرار المادية المباشرة^(١).

(٣) عدم قابليتها للتصرف فيها أو للانتقال للورثة:

ومما يترتب على عدم تقوم حقوق الشخصية بالمال أنها لا يمكن التصرف فيها أو انتقالها إلى الورثة، ومع ذلك فإنه يجوز

(١) د. عبد الحى حجازى، المرجع نفسه، ص ٤٥ وما بعدها.

لأعضاء أسرة المتوفى الذي اعتدى على اسمه أو أحد حقوق شخصيته أن يرفعوا ضد المعتدى دعوى بصفتهم الشخصية وذلك بسبب اغتصاب الغير، لحق من حقوق شخصيته كاسمه مثلاً، وهم حين يرفعون تلك الدعوى، لا يرفعونها باعتبارهم ورثة، وإنما باعتبار أنهم أصحاب حقوق خاصة بهم بصفة شخصية، ومن هذا القبيل الحقوق المبنية على التشفى والتي تتعدى المرة فيها المضرور إلى ورثته، كما في حالات القذف، والتعدى على الشرف والسمعة.

(٤) عدم قابليتها للسقوط بالتقادم:

كما تنشأ عن عدم مالية تلك الحقوق أنها لا تسقط بالتقادم وحتى حق الإنسان على اسمه فإنه لا يسقط كذلك بعدم استعماله مدة طويلة، لأنه من الحقوق الشخصية وهي لا تسقط بالتقادم.

ثانياً: حقوق الأسرة:

وهي تلك الحقوق التى تثبت للإنسان باعتباره عضواً في أسرة معينة^(١)، وتنشأ هذه الحقوق من الزواج أو من القرابة، ومن ثم فإنها تثبت لكل من الزوجين قبل الآخر أو للأقارب بعضهم على بعض. وتنظم هذه الحقوق في مصر أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين، أما بالنسبة لغير المسلمين من الميحيين، فإن حقوق الأسرة عندهم تحكمها الشريعة المسيحية، واليهود تحكمهم الشريعة اليهودية، ويبلغ عدد الشرائع التى تنظم أحكام الأسرة بالنسبة لغير المسلمين في

(١) د. أحمد سلامة، المرجع نفسه، ص ٥٧ وما بعدها.

مصر عموماً خمس عشرة شريعة، اثنتا عشرة للمسيحيين، واثنان لليهود، أما المسلمون فتحكمهم مبادئ قانون الأحوال الشخصية المستمد مباشرة من الشريعة الإسلامية، ومن ثم لم تعد القاعدة القانونية التي تنظم هذه الحقوق واحدة، بل تختلف بحسب ديانة وملة وطائفة الشخص، وهو موضع يجدر بالمشرع أن يقضى عليه فيضع قواعد موحدة بالنسبة للجميع، ولن تضيق الشريعة بتوحيد تلك القواعد، لأنها تصلح لحكم تصرفات المجتمع وحفظ أفرادها على اختلاف معتقداتهم وتباين ديانتهم.

ويجرى الآن وقت إعداد الكتاب للطبع صياغة قانون موحد لحكم مسائل الأحوال الشخصية عند غير المسلمين والمسيحيين في مصر تحتكم إلى جميع الطوائف والملل المسيحية المختلفة، ونأمل أن يتم هذا القانون حتى يتحقق مقصد تشريعي يريد القانون أن يصل إليه وهو توحيد المراكز القانونية في مسائل الأحوال الشخصية بقدر المستطاع.

المطلب الثاني

أنواع الحقوق المالية

والحقوق المالية هي التي تهدف بحسب أصلها إلى تحقيق مصالح تقوم بالمال، وهي على عكس حقوق الشخصية يمكن التصرف فيها، كما يمكن أن تنتقل إلى الورثة، ويمكن النزول عنها، كما يمكن أن تسقط بالتقادم وقد جرى التشريع والفقهاء منذ زمان بعيد

على تقسيم تلك الحقوق إلى قسمين هي الحقوق العينية والحقوق الشخصية.

أولاً: الحقوق العينية:

الحق العيني هو ذلك الحق الذي يرد على شيء مادي فيختص به الشخص ويتسلط عليه، فالحق العيني يخول صاحبه سلطة التسلط على الشيء مباشرة، وهو يلقى على الكافة واجباً عاماً يتمثل في احترام حق الغير، وعدم التعرض لصاحب الحق في تمتعه بحقه، وأنا السلطات التي يمنحها الحق العيني، والتي تسمى بمضمون الحق العيني، فإنها تختلف باختلاف أنواعه، وما إذا كان الحق العيني أصلياً أو تبعياً.

(أ) الحقوق العينية الأصلية:

وحق الملكية هو أهم تلك الحقوق، وهو الحق الذي بمقتضاه يحتكر الشخص سائر السلطات على شيء معين، حيث يعطى صاحب سلطات كاملة على الشيء حتى إنه ليختلط أحياناً في التعبير الدارج بمحله، فيقال: سيارتي، ومنزلي، ولا يقال: حق الملكية الذي لي على هذه السيارة أو المنزل، ولمالك الشيء في حدود القانون أن يستعمل الشيء ويستغله ويتصرف فيه^(١).

والى جانب حق الملكية وهو أهم الحقوق العينية الأصلية نجد حقوقاً أخرى تنصب على أشياء مملوكة للغير، وبمقتضاها يستأثر

(١) د. شمس الدين الوكيل، المرجع نفسه، ص ١٤٢ وما بعدها.

صاحبها أو يختص بتسلط جزئي على الشيء إذ هو لا يحتكر سائر السلطات كما هو الحال بالنسبة للملكية، بل له فقط سلطات محدودة، وذلك مثل حق الانتفاع الذي يخول للشخص أن يستعمل وأن يستغل شيئاً مملوكاً للغير دون أن يكون له حق التصرف فيه، وينتهي هذا الحق بانتهاء مدته أو بوفاء المنتفع، إذ أن هذا الحق لا يورث وينتهي بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة (المادة ٩٣٣) مدني^(١).

والى جانب ذلك هناك حق الحكر وهو نوع من الإجازة الطويلة الأجل ولكنه يعتبر من الحقوق العينية لأنه يقصد به الانتفاع بأرض الغير لمدة طويلة قد تمتد إلى ستين سنة (مادة ٩٩٩) مدني، وهذا الحق مأخوذ من الشريعة الإسلامية وحكمته التشجيع على استصلاح الأرض من خلال استثمارها مدة تعوض ما أنفق عليها في إصلاحها. كما يدخل في نطاق تلك الحقوق حق الارتفاق، أو الخدمات العقارية، وهو حق يخول لصاحبه أن يحد من منفعة عقار مملوك لشخص آخر لفائدة عقار يملكه، فهو تكليف يقرر لمنفعة عقار على عقار آخر، وذلك كحق المرور وحق المظل، وحق الشرب وحق المسيل أو المجرى، فالارتفاق يرد على منفعة محدودة ومعينة في عقار الغير، بينما حق الانتفاع يصيب العقار كله.

(ب) الحقوق العينية التبعية:

(١) المرجع السابق، ص ١٤٣، د. محمد على عمران، الحقوق العينية الأصلية، ص ١٠ وما بعدها، دار النهضة العربية ١٩٧٩م.

وإذا كانت الحقوق العينية الأصلية تنشأ بصفة مستقلة وتعطى لصاحبها سلطة مباشرة على الشيء، فإن الحقوق العينية التبعية لا تنشأ بصفة مستقلة وإنما تنشأ ضماناً للوفاء بحق من الحقوق الشخصية، حين لا يجد الدائن الضمان الشخصي المتمثل في الكفالة كافياً، وتتتبع الحقوق العينية التبعية بحسب مصادرها إلى الرهن الرسمي، والرهن الحيازي وحق الاختصاص، وحقوق الامتياز^(١).

ثانياً: الحقوق الشخصية:

الحقوق الشخصية جمع للحق الشخصي الذي يترجم عن قيام رابطة بين شخصين بمقتضاها يجب على أحدهما أداء معيناً قبل الآخر، أو يكون لأحدهما أن يطلب من الآخر هذا الأداء، وبعبارة أخرى يكون أحدهما دائناً بأداء معين، ويكون الآخر ملتزماً أو مدنياً بهذا الأداء، ولذلك يكلف على الحق الشخصي أيضاً، حق الدائنية، كما يعرف أيضاً بالالتزام، والإطلاق الأول ينظر إلى مركز الدائن، بينما الثاني يأخذ في الاعتبار مركز المدين، ولما كان الحق الشخصي لا يتصور دون وجود دائن ومدين، فإن كل هذه التسميات تغدو صحيحة، والمشرع المصري قد جعل الحق الشخصي مرادفاً للالتزام، حين عنون للقسم الأول من القانون المدني بعنوان: الالتزامات أو الحقوق الشخصية، وتتمثل الحقوق الشخصية فيما يلي:

(١) الالتزام بالعمل:

(١) د. محمد على عمران، المرجع السابق، ص ١٣.

ومضمونه أن يقوم المدين بعمل إيجابي معين، فإذا التزم عامل بالعمل في مصنع كان التزامه هذا التزاماً بعمل هو القيام بما عهد به إليه، وإذا استأجر شخص منزلاً كان المؤجر ملزماً بعمل هو تسليم المنزل إلى المستأجر وهكذا.

(٢) الالتزام بإعطاء:

ومضمونه نقل حق عيني، وذلك كما في الالتزام بنقل ملكية العقار المباع أو هبته، أو إنشاؤه كما في حالة إنشاء الرهن السمي من المدين الراهن.

(٣) الالتزام بالامتناع عن عمل:

ومضمونه أن يمتنع المدين عن فعل شيء كان يحل له أن يفعله لولا وجود هذا الالتزام، وذلك كمن يشتري أرضاً من شركة وتكون قد اشترطت في العقد ألا يبنى على الأرض عمارة سكنية أو مصنعاً. هذه الأنواع الثلاثة للالتزام أو للأداء - إن شئت الدقة - عبارة عن قوالب يمكن أن تصب فيها صور لا تنتهي من الأداءات، ومن هنا سلطان الإرادة يجوز للأفراد أن ينشئوا ما يتفقون عليه من هذه الحقوق، ولا يحد من حريتهم إلا قيد النظام العام والآداب.

المطلب الثالث

الحقوق المختلطة (حقوق الملكية الفكرية)

ويقصد بالحقوق المختلطة تلك التى تضمن عديداً من المزايا بعضها يمكن تقويمه نقداً وبعضها الآخر لا يمكن تقويمه، ومثال ذلك: الحقوق الذهنية، وهي مجموعة الحقوق التى تقع على أشياء ذات طبيعة معنوية، أو هي الحقوق التى يكون محلها إنتاج ذهني يستمد قيمته مما فيه من ابتكار^(١)، كحق الكاتب على الأفكار التى يتضمنها الكتاب أو المقال الذي يكتبه في أى مجال من مجالات الفكر، كالآداب والعلوم والفنون، وكالحقوق المختلطة ومنها حق المؤلف، والأسماء والعلامات والبيانات التجارية وغيرها، وهذه الحقوق لها جانبان: هما: الجانب المالي، والجانب الأدبي، كما أنه لها وسائل حماية ونبين ذلك في فرعين:

الفرع الأول

جوانب حقوق الملكية الفكرية

وهي - كما قلنا - لها جانبان:
أولهما: الجانب المالي:

(١) د. أحمد سلامة، المرجع والمكان السابقان، د. نعمان جمعة، المرجع السابق، ص ٣٧٥

وما بعدها.

وهو يتمثل في حق المؤلف أو صاحب الحق وحده يجنى ثمار مؤلفه من خلال تقديره لملاءمة عمله لتقديمه للجمهور عن طريق الاستغلال المباشر، وباعتبار أن المؤلف يمكن أن يشبع حاجات الأشخاص الآخرين تكون له قيمة مالية يمكن للمؤلف استثمارها من خلال مؤلفه.

ثانيهما: الحق الأدبي:

وهو جماع السلطات التي تهدف إلى حماية شخصية المؤلف في مظهرها الفكري، فله وحده حق تقرير نشر المصنف وتعيين طريقة النشر، وله الحق في أن ينسب مصنفه إليه وحده ولا يجوز له التنازل عنه للغير^(١)، وإن تنازل عنه يكون تصرفه باطلاً بطلاناً مطلقاً، وله وحده إدخال أى تعديل أو تحوير في مصنفه، وله أخيراً حق سحب مصنفه من التداول بعد نشره، وهذه العناصر تكون في مجموعها مضمون الحق الأدبي للمؤلف.

الفرع الثاني

حماية حقوق المؤلف

لقد كفل المشرع حماية حق المؤلف، وذلك عن طريق توقيع الجزاءات المدنية والجزاءات الجنائية، على كل من يعتدى على حق المؤلف، وهناك إجراءات تحفظية يمكن اتخاذها في هذا الشأن لمنع

(١) المادة ١٤٣ (ثانياً) من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، الكتاب الثالث.

الاعتداء على حق المؤلف، أو لوقف استمراره - وضماناً لفاعلية
الجزاءات المنصوص عليها في القانون.

أولاً: الجزاء المدني والجزاء الجنائي:

(١) وقد قرر القانون جزاء مدنياً يتمثل في وقف الاعتداء على حق
المؤلف وإزالة الآثار المترتبة على التعدي، كذكر اسم المؤلف
إذا كان التعدي بحذفه، ويمكن للمحكمة أن تقضى بتدمير
المصنف إذا كان التعدي فادحاً وخطيراً كأن يكون تزويراً على
المؤلف ينال من مكانته العلمية أو الأدبية بما يصعب معه
إعادته إلى حالته الأولى^(١).

ويجوز اللجوء إلى الإكراه المالي لتصحيح الضرر، ويكون
للمؤلف الحق - بصفة عامة - في الحصول على تعويض يجبر
ضرره وفقاً للقواعد للمسؤولية المدنية.

(٢) وهناك جزاء جنائي وضعه المشرع لجريمة التقليد، وهي الحبس
والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة
آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتقوم الجريمة وفقاً لما
نصت عليه المادة (١٨١) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
إذا حدث التعدي على أي حق مادي أو أدبي من حقوق المؤلف
أو الحقوق المجاورة المقررة في هذا القانون أو بيع أو تأجير

(١) كانت المادة ٤٥ من قانون حماية المؤلف الملغى تنص على الإلتلاف، مع أن أمر
الالتلاف جوازى للقاضى، د. أحمد سلامة، نظرية الحق ١٩٧٤م، ص ٣٢١.

المصنف المقلد أو المعروض للبيع^(١)، أو نشر المصنفات المحمية عبر أجهزة الحاسوب أو شبكة المعلومات أو الاتصالات أو غيرها بدون إذن كتابي مسبق وتتعدد العقوبات بتعدد المصنفات المعتدى عليها.

وتشدد العقوبة في حالة العود إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كما تقترن تلك العقوبة بعقوبة تبعية مثل غلق المؤسسة التي استغلها المقلدون مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد ونشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه (م ١٨١ سابعاً).

ثانياً: الإجراءات التحفظية:

وهناك إجراءات تحفظية يمكن اللجوء إليها لحماية حق المؤلف إلى أن يتم الفصل فيما يدعيه المؤلف من تعدد وقع على حق من حقوقه ومن ثم لا يترك القانون المؤلف دون حماية طوال الفترة التي يستغرقها نظر النزاع، وقد نصت على تلك الإجراءات التحفظية (المادة ١٧٩ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية)، والتي تسمح لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك بالنسبة لكل مصنف ينشر

(١) د. أبو اليزيد المبت: الحق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية، ص ١٤٩، إسكندرية

١٩٦٨م، وقرآن د. مختار القاضي: حق المؤلف، ص ١٠٠.

- أو عرض دون إذن كتابي من المؤلف، أو ممن يخلفه أو عند الاعتداء على أى حق من حقوق المؤلف أن يأمر بما يلي:
- (١) وقف نشر المصنف أو عرضه أو نسخه أو صناعته.
 - (٢) منع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً.
 - (٣) توقيع الحجز على المصنف الأصيل أو على نسخة إذا عملت منه نسخ كالحروف المجموعة المعدة لطبع نسخ من كتاب، أو التسجيلات الصوتية، أو القوالب المصبوبة المعدة لعمل نماذج من التمثال، وغيرها من المصنفات المشمولة بالحماية.
 - (٤) إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
 - (٥) توقيع الحجز على الإيراد الناتج من النشر أو العرض بعد حصره بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الأمر^(١).

(١) وراجع في هذا الموضوع بصفة خاصة، كتابنا: الحماية المقررة لحقوق المؤلفين الأدبية في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون، الطبعة الأولى ١٩٩١م، ص ١٤٧ وما بعدها، والمادة ١٧٩/١، ٢، ٣، ٤، ٥ من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢م.

الباب الثانى

عناصر فكرة الحق

فكرة الحق تقوم على عناصر رئيسية، وهذه العناصر تتمثل في نظر بعض الفقهاء أركاناً لفكرة الحق، وفي نظرنا أن ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل الاختلاف اللفظى، فالعنصر والركن كلاهما يدخل في مكونات الشيء، وفكرة الحق لها عناصر تقوم عليها وهي: أشخاص الحق، الذين يثبت لهم، وموضوع الحق، ومصادره، وإثباته، وسوف نتناول هذه المواضيع من خلال فصلين:

الفصل الأول: صاحب الحق الطبيعى والافتراضى.

الفصل الثانى: موضوع الحق ومصادره وإثباته.

الفصل الأول

صاحب الحق

صاحب الحق هو كل شخص يثبت له الحق، ويكون له أن يستأثر بشيء معين أو بقيمة معينة، ويعرف صاحب الحق عند البعض بشخص الحق، وصاحب الحق يعرف بالدائن الذي يقابله المدين، أو من يلتزم باحترام الحق، وصاحب الحق قد يكون شخصاً طبيعياً وقد يكون شخصاً معنوياً أو اعتبارياً، ونخصص لبيان كل واحد منهما مبحثاً.

المبحث الأول

الشخص الطبيعي

والشخص الطبيعي: هو الإنسان، ولئن كانت الحقوق يمكن أن تثبت لجميع الأشخاص أياً كان طبيعتها إلا أن هناك عدداً من الحقوق يقصد من تقريرها الحفاظ على قيم معينة يتميز بها الشخص الطبيعي وهو الإنسان، ولذلك يتمتع بها الإنسان وحده إلا أن المادة (١/٥٣) مدني قد نصت على أن: "الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية".

ووجود هذه الحقوق يقتضي أن يكون صاحب الحق موجوداً
ويتطلب أيضاً بيان هوية الشخص، وأهليته، ونخصص لكل موضوع
من هذه الموضوعات الثلاثة مطلباً:

المطلب الأول

وجود الشخص الطبيعي

وجود الشخص الطبيعي له بداية ونهاية، وما بين البداية
والنهاية يمثل فترة وجود الشخص الطبيعي، ومع ذلك فإن حياة الحمل
المستكن، نظراً لأنها ذا طبيعة خاصة، فقد اعتد القانون بوجود تلك
الحياة التي يتهياً للانفصال والاستقلال بذاته عن حياة أمه، فأثبت له
أهلية قانونية تسمى بأهلية الوجوب، وبمقتضاها يكون الجنين صالحاً
لاكتساب الحقوق دون التحمل بالالتزامات، ونلقى الضوء على بداية
الشخصية وانتهائها.

أولاً: بداية الشخص الطبيعي:

تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، كما تنتهي تلك
الشخصية بموته، وقد نصت على ذلك المادة (٢٩ مدني) في فقرتها
الأولى، فالأصل أن تبدأ حياة الإنسان بتمام ولادته حياً، والاستثناء ان
تبدأ من وقت الحمل المستكن^(١)، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة
(٢٩) المشار عليها على أن حقوق الحمل المستكن يحددها القانون،
والنص كما يبدو من قراءته يشترط ولادة المولود حياً، حيث لا تثبت

(١) د. جلال العدوي، المراكز القانونية، ص ١١٠، مؤسسة الثقافة الجامعية ١٩٨٨ م.

الحقوق عادة إلا للحي، ولأنه لو نزل ميتاً لا يكون له من تلك الحقوق القانونية حظ.

ولادة الطفل حياً:

ولئن كان بدء الشخصية يتحقق - كما يقرر النص - بودلاته حياً، فإن الولادة واقعة مادية ربما لا تثير خلافاً حول معناها، وهي تتم بأمرين:

أولهما: انفصال المولود عن أمه:

يجب أن ينفصل المولود عن أمه تماماً فلا يبقى جزء من بدنه عالقاً ببدنها، بحيث يستقل بكيانه المادي عن كيائها، وينفرد بوجوده عن وجودها، فإذا لم يتم الانفصال التام بأن بقي جزء من الطفل داخل الرحم، فإن ذلك يعنى عدم تمام ولادته^(١)، لأنه لم ينفصل عن أمه تماماً، وقد أخذ المشرع بذلك وعدل به عما كان عليه العمل قبل صدور القانون المدني حيث كان يكتفى بخروج معظم جسم المولود حياً، دون حاجة إلى ضرورة خروجه كله، وما أخذ به القانون المدني الجديد أفضل، لأنه يسهل حسم المنازعات، فإن إثبات الخروج الكلي أيسر من إثبات خروج معظم الجسم^(٢).

ثانيهما: أن ينفصل عن أمه حياً:

ويشترط أن يكون انفصال المولود عن أمه حياً، ومن ثم لا تثبت الشخصية القانونية لمن ينفصل عن أمه كالسقط، وسواء

(١) د. نعمان جمعة: المدخل للعلوم القانونية ١٩٧٧، ص ٣١٤.

(٢) د. فتحي عبد الرحمن: المرجع السابق.

كانت الوفاة سابقة على الولادة أو وقتها، وتعرف الحياة بطبيعتها، ويستدل عليها بما يفيد وجودها، كالنبض والحركة والبكاء، وفي حالة الشك يستعان برأى أهل الخبرة من الأطباء^(١)، والقانون الفرنسي يشترط تمام الولادة وحياة المولود، وقابليته للحياة باستكمالها لجميع الأعضاء الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وهو في هذا أشد من القانون المصري في منح الشخصية للمولود، حيث يكتفى قانوننا بمجرد تمام الولادة حياً حتى ولو لم يكن المولود قابلاً للحياة^(٢)، والقابلية للحياة عنصر موضوعي يقدره الأطباء ومعياره ليس وفاة الشخص بعد الولادة بمدة قصيرة، وإنما ولادته ولديه من المقومات الحيوية والعضوية ما يسمح له باستمرار الحياة.

إثبات الميلاد:

وتقضى المادة (٣٠ مدني) بأنه:

- (١) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
 - (٢) فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز إثباته بأية طريقة أخرى.
- ما تقضى المادة (٣١ مدني) بأن: "دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص"^(٣).

(١) د. جميل الشرقاوى، ص ٢٦٢ وما بعدها.

(٢) هذا القانون الخاص هو القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن الأحوال المدنية.

هذا القانون الخاص، وهو القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن الأحوال المدنية.

وتبدو أهمية إثبات واقعة الميلاد في أنه اعتباراً من تاريخها يكون الشخص صالحاً لتلقى الحقوق، وابتداء من هذا التاريخ يحسب عمره، وبالتالي يرجع إليه لمعرفة ما إذا كان الشخص بالغاً سن الرشد أو وصل إلى سن التجنيد الإجباري، أو سن المساءلة الجنائية^(١)، وكذلك معرفة مدى صلاحية الشخص للزواج وخاصة الفتاة، حيث لا يجوز عقد قرانها قبل بلوغها ثمانية عشر عاماً وفقاً للتعديل الأخير. ويقضى هذا القانون في المواد من (١٥ - ٢٥) بأن القيد يتم في مكاتب السجل المدني في جهة الولادة بناء على تبليغ يقوم به والد الطفل في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ الميلاد فإذا لم يكن أب الطفل حاضراً التزم بالتبليغ والدته بشرط إثبات علاقة الزوجية، ثم أقاربه الحاضرون لولادة قرابة نسب أو مصاهرة، البالغون حتى الدرجة الثانية، ثم مديرو المؤسسات والمستشفيات ودور الولادة، والسجون، والمحاجر الصحية وغيرها عن الولادات التي تقع فيها. ويعطى لم يبلغ عن الميلاد مستخرجاً من السجلات يتضمن صورة من القيد الذي أجرى في السجل وهذا المستخرج هو الذي يقدم عادة إثبات واقعة الميلاد، بل وإن واقعة الميلاد واقعة مادية يمكن إقامة الدليل عليها بجميع الطرق^(٢)، ويسأل عن عدم التبليغ في

(١) د. نعمان جمعة، ص ٣٩٦ وما بعدها.

(٢) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٥٤٣.

المواعيد المقررة المكلفون به على الترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غيرهم^(١).

الحمل المستكن:

والحمل المستكن هو الجنين المستقر في بطن أمه، ويطلق عليه هذا المسمى منذ بدء الحمل وحتى تمام الولادة، وقد رأينا المادة (٢/٢٩) مدني تنص على أن: "حقوق الحمل المستكن يعينها القانون".
والحقوق التي يشير إليها هذا الاستدراك يمكن حصرها وفق أحكام القانون فيما يلي:

(١) يكون للجنين الحق في ثبوت نسبه إلى أبيه، واكتساب جنسيته بناء على حق الدم الذي يأخذ به المشرع المصري كأصل لكسب الجنسية.

(٢) كما أن للجنين - وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية - الحق في الإرث حيث يوقف له من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى، فإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد اباقي على من يستحقه من الوثة، ويكون له الحق فيما يوصى له به.

(٣) ويكون للجنين الحق فيما يشترط لصالحه في اشتراط لمصلحة الغير (كتأمين الزوج على حياته لمصلحة من سينجبهم من الأولاد)^(٢).

(١) مادة ٣/٢٠ من القانون ١٤٣ لسنة ١٩٩٤.

(٢) د. محمد شكرى سرور، ص ١٤٨.

وبالنظر في هذه الحقوق يستبين أنه لا تحتاج إلى قبول وهذا أمر منطقي مادام أن القبول يفترض الإدراك، وهو معدوم بداهة لدى الجنين، ومن ثم فإنه لا يستطيع أن يكسب الهبة لأنها تحتاج إلى قبول، رغم أنها تعتبر من التصرفات النافعة له نفعاً تاماً، إذ الهبة عقد يحتاج إلى قبول الموهوب له، ذلك ما انتهى إليه القانون^(١)، وإن كان الراجح في فقه الشريعة أن الهبة لا تحتاج إلى قبول فتصبح للجنين في بطن أمه^(٢).

كذلك يتميز كسب الجنين لهذه الحقوق بأنه يقع معلقاً على شرط واقف هو تمام ولادته حيثاً، وإلا فإنه إذا نزل ميتاً فإنه يعابر وكأنه لم يكسب هذه الحقوق في أى وقت كان، ووفقاً لما ورد في هذا الاستدراك يقتصر أمر الجنين على كسب الحقوق المشار إليها دون التحمل بالالتزامات.

وبناء على ذلك يمكن القول أن للجنين شخصية قانونية اعتبارية ترد على خلاف الصل العام الذي بموجبه تبدأ شخصية الإنسان من وقت ولادته حياً.

ووفقاً للرأى الراجح في الفقه الإسلامي، فإنه ليس للجنين وصي ولا ولي، لأنه ليست له ذمة بالمعنى الصحيح، ومن ثم فإنه لا يحتاج إلى ولاية من أحد، ولكن يجوز أن يعين له أمين ليحافظ على ماله،

(١) د. شمس الدين الوكيل، ص ٢٥.

(٢) ذلك ما ذهب إليه أكثر فقهاء الحنفية، راجع: المبسوط للسرخسي، ج ١٢ - ص ٧٥.

ولا يكون لهذا الأمين حكم الوصى، فلا يملك التصرف في أي شيء من ماله، وإن كان قانون الولاية على المال^(١)، في المادتين (٢٨، ٢٩) قد أجاز إقامة وصى على الجنين، كما نص قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ على أنه إذا كانت الوصية للجنين، كان لمن له الولاية على ماله قبل الوصية أورها (مادة ٢٠)، وهذا الوصى إنما هو أمين لحفظ المال إلى حين ولادته، وتعتبر الحقوق المقررة للجنين تطبيقاً لحق التداولى الذى تثبت به الحقوق لأصحابها مجردة من الالتزامات، حيث إن أصحابها ليست لهم أهلية أداء يلتزمون بها.

ثانياً: انتهاء الشخصية:

وإذا كانت شخصية الإنسان تبدأ من وقت تمام ولادته حياً فإنها تنتهي وفقاً للمادة (٢٩) بموته، والوفاة واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الطرق، ونظراً لأهمية ثبوت تاريخها فقد نظم المشرع قيد الوفيات بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤، حيث أوجبت المادة (٣٥) منه على ذوي الشأن التبليغ عن الوفاة بمكتب الصحة في ظرف أربع وعشرين ساعة من حدوثها أو ثبوتها، ويتم إبلاغ قسم السجل المدني من مكتب الصحة بواقعة الوفاة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الأسبوع الصحى الذى وقعت فيه الوفاة^(٢)، وقد رتبّت المادة ٣٦ من القانون ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الوفاة وهم:

(١) أصول وفروع أو أزواج المتوفى.

(١) رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢م.

(٢) مادة ١٦ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٩٤م.

- (٢) من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين.
- (٣) من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين.
- (٤) الطبيب المكلف بإثبات الوفاة.
- (٥) صاحب المحل أو مديره إذا حدثت الوفاة في المستشفيات أو الملبأ أو الفندق أو المدرسة أو المؤسسة العقارية أو ريان السفينة أو المشرف على الرحلة السياحية ولا يقبل التبليغ من غير هؤلاء.

معنى الوقت:

والراجح عن قدامى الفقهاء، أن الموت ضد الحياة وهو يعنى انتهاء مظاهر الحياة في جميع أعضاء الجسم، بموت المخ وتوقف القلب والرئتين عن العمل، فإذا مات المخ دون الجسم أو مات الجسم رغم بقاء بعض مظاهر الحياة في المخ فإن الموت لا يتحقق في كل تلك الصور^(١).

بيد أن ذلك الرأي بدأ يلقي مناقشة من أصحاب نظرية موت الدماغ، أو موت جذع المخ، الذين يقولون: إن المخ إذا تلف وأصبح من المستحيل بحكم العلم الطبي المتاح أن يعود لعمله مرة ثانية، فإن الشخص يعتبر ميتاً حتى ولو بقيت بعض مظاهر الحياة مثل التنفس وودق القلب ونمو الشعر والإخراج والإفراز وما إلى ذلك مما تعرف به

(١) يعرف بظهور علاماته من استرخاء القدي وأنخساف الصدغ وإعوجاج الأنف وامتداد جلدة الوجه، راجع: الفتاوى الهندية، ج١، ص١٢٣.

الحياة كالحرارة وربما الولادة كما حدث لامرأة ولدت جنينها وهي في حالة موت الدماغ.

وقد قى هذا الاتجاه معارضة شديدة من أصحاب فكرة الموت التام، أو انتفاء كافة مظاهر الحياة، ولم تقف معارضتهم عند حد نقد الرأى مجرداً، بل تناول هذا النقد إلى النوايا والمقاصد التى فسرت كمأرب للحصول على أعضاء الجسم وهي ساخنة، حتى يتسنى نقلها إلى بدن شخص ينتظر تلك الأجهزة أو هذه القطعة الأدمية بفارغ الصبر، ورأوا أن سد ذريعة تلك المطامع في البدن الآدمى على نحو يغرى بانتهاك حرمة وسلب أعضائه، أمر يتعين الأخذ به واللجوء إليه محافظة على حرمة الحياة، وحماية لأبدان الناس وهم يعانون سكرات الموت من أن تمتد إليها يد السارقين أو الراغبين في الشراء السريع.

رأينا في الموضوع:

ونحن نرى أن المعصومية هي أساس حماية البدن، وأن تلك المعصومية لا تثبت إلا لحياة تقوم بذاتها أو ما نسميها (ذاتية الحياة)، فإذا كانت حياة المريض قابلة للشفاء، ويمكن أن تنهض من كبوتها وتستجيب للعلاج وتعود إلى سابق عهدها الذي فطرها الله عليه، هنا تكون الحياة معصومة، ولا يجوز الحكم بموت صاحبها، أما إذا كانت الحياة صناعية تعتمد على الأجهزة، ولا تقوى على النهوض أو البقاء إذا ما نزعَت منها، فإنها لا تكون حياة ذاتية، ولا يتوافر فيها مبدأ

(ذاتية الحياة) الذي هو أساس المعصومية، ومن ثم الحماية، وعليه يجوز نزع الأجهزة واعتبار صاحبها ميتاً بموت دماغه والله اعلم.

الامتداد الافتراضي للشخصية بعد الوفاة:

ويفترض امتداد شخصية المتوفى لما بعد وفاته حتى تصفى تركته ويسدد ما عليه من ديون وذلك إعمالاً للمبدأ المقرر في الفقه الإسلامي والذي يقضى بأنه: "لا تركة إلا بعد سداد الدين، وحكمة هذا الامتداد إقالة الدائنين من مشقة متابعة الورثة بديون مورثهم في ذمتهم الشخصية إذا زادت على مكونات التركة من ناحية، وعدم تحمل الورثة لتلك الديون من ناحية أخرى^(١).

الموت الحكمي:

الموت الحكمي ليس موتاً مادياً يحس ويعرف بفقد الحياة، ولكنه يعتبر موتاً افتراضياً تسري في أحكام الموت مع قيام مظاهر الحياة كاملة، وهذا النوع من الموت يتمثل في: الرق، والموت المدني، والفقد.

(١) أما الرق:

فقد كان منتشراً في الشرائع القديمة، وكان من أسبابه في القانون الروماني عدم الوفاء بالدين والعقد، بأن يتفق شخص مع آخر على استرقاقه، وقد يتقرر عقاباً لجريمة السرقة أو غيرها من الجرائم^(٢).

(١) في هذا المعنى: د. عبد المنعم البدر، ص ٥٤٧، د. محمد أسامة مذكور، ص ٤٩.

(٢) د. مختار القاضي، المرجع السابق، ص ٩١.

وقد كان الرق موجوداً قبل الإسلام، فلما نزل الإسلام منع أسبابه ووسع روافد تحرير الأرقاء، حتى جعل تحرير الرق عملاً يتقرب الناس به إلى ربهم، ودليل ذلك قول الله تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ} ^(١)، كما جعل عتق الرقيق داخلاً في كفارات الظهار واليمين والفطر في رمضان عمداً بالجماع أو الأكل عند جمهور الفقهاء، وهكذا وسع الإسلام من منافذ تحرير الرق، وحرّم الاسترقاق في معظم صورته حتى إنه لم يبق من تلك الصور سوى رق الحروب، وهو أمر لا يُلام فيه الإسلام، لأن الحرب أثر لنوازع النفوس البشرية وهي قائمة إلى يوم الدين ^(٢)، فلم يشأ أن يقضى على تلك الغريزة الفطرية التي تتعلق بها منافع للناس وعسى أن يكرهوا آثارها وهي خير لهم، ولهذا هذب تلك الفطرة، وقلم أظافر الشر فيها. ومن المعروف أن الرقيق ليست له أهلية اكتساب الحقوق المالية، لأنه وما ملكت يده ملك لسيده، فهو ميت حكماً من هذه الناحية، وذلك ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، إلا أنه يعتبر مخاطباً بحقوق الله عز وجل المتعلقة بالعبادات، وإن كان الظاهرية يثبتون له أهلية يكون له بمقتضاها أن يتصدق ويهب ويبيع ^(٣).

(١) سورة البلد - الآيات من ١١ : ١٣

(٢) نيل الأوطار للشوكاني، ج ٨ ص ٣.

(٣) المحلى لابن حزم الظاهري، ج ٨، ص ٣٦٠.

وقد أصدرت فرنسا قانوناً في ١٨/٧/١٩٤٥م متعلقاً بنظام الرق، وقد اعترف هذا القانون للأرقاء بشخصية قانونية محدودة^(١).

(٢) الموت المدني:

وهو نوع من الموت الاعتباري أو الحكمي كان يقضى به على كل من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو التجريد من الحقوق، ولم يكن هذا النوع من الموت معروفاً في الشرائع القديمة بخلاف الرق، وإن كان معروفاً في أوروبا الحديثة حتى القرن التاسع عشر، وآثار هذا الموت منصوص عليها في المادة (٢٥) من قانون نابليون)، ويتمثل في توزيع التركة وطلاق الزوجة وفقد الحقوق السياسية، أما الحقوق المدنية فلا يصح له أن يقاضى، ولا أن يكون ولياً ولا قيمياً، ولا أن يعطى أو يتلقى تبرعاً، وليس له إلا أن يتعاقد بعوض للمحافظة على حياته بالطعام والشراب والملبس وإلى ذلك مما يبقى على حياته، ويعتبر في حكم الميت مدنياً من دخل الدير^(٢).

وقد انتهى الموت المدني في فرنسا سنة ١٨٥٤م، وفي بلجيكا سنة ١٨٣١م، ولم يبق له أثر في معظم بلاد العالم، بعد أن سادت مبادئ حقوق الإنسان.

أما بالنسبة للرهبان فليس ثمة نص يحرمهم شيئاً من حقوقهم المدنية، ومع ذلك فقد صدر حكم يقضى بأن من دخلوا الدير من

(١) د. مختار القاضي، المرجع السابق، ص ٩٢.

(٢) المرجع والمكان السابق.

الرهبان يعدون كأنهم ليسوا موجودين بالنسبة للعالم الدنيوي، وما كان للراهب قبل رسمه، أو نتج مما كان له أو صار بغير سبب الأسقفية كميراث أو وصية، فهو له أن يورث عنه وأما ما له بسبب الأسقفية فهو للدير فلا يرثه أهله^(١).

(٣) المفقود:

والمفقود هو الشخص الذي يغيب عن موطنه وعن أهله بحيث لا يعرف حياته من موته، يقول السرخسي: "المفقود اسم لموجود هو حي باعتبار أول حالة، ولكنه خفي الأثر كالميت باعتبار مآله، وأهله في طلبه يجدون، ولخفاء أثر مستقرة لا يجدون، قد انقطع عليهم خبرة، واستقر عليهم أثره، وبالجد ربما يصلون إلى المراد وربما يتأخر اللقاء إلى يوم التناد"^(٢).

ويختلف المفقود عن الغائب، من جهة أن الآخر هو الذي ترك وطنه راضياً أو مرغماً واستحال عليه إدارة شئونه بنفسه، أو الإشراف على من يديرها نيابة عنه مما ترتب عليه تعطيل مصالحه أو مصالح غيره، يستوي في ذلك أن تكون حياته محققة أو غير محققة^(٣)، فإذا كان المفقود لا يعلم حياته من موته، فإن الغائب يعلم محله.

وفقد الشخص يثير مسألتين:

(١) المرجع نفسه، وراجع: حكم محكمة إسكندرية الكلية بتاريخ ١٩٣٥/٢/٢٢ م.

(٢) المبسوط للسرخسي، ج ١١، ص ٣٤، الطبعة الأولى.

(٣) د. مختار القاضي، ص ٩٢، د. عبد الودود يحيى، المرجع السابق، ص ٢٣٨.

الأولى: تختص بإدارة أمواله وهو غائب، ليقضي ماله ويوفى ما عليه.

الثانية: خاص بتحديد أثر الغياب على شخصيته.

والمجموعة المدنية لم تتضمن تنظيمًا لحالة المفقود، وإنما أحالت بشأنها إلى الشريعة الإسلامية، والقوانين الخاصة، فنصت المادة (٣٢ مدني) على أنه: "يسرى في شأنه المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية".

وقد تضمنت القوانين: ٢٥ لسنة ١٩٢٠ (مادة ٨) والقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ (المادتين ٢١، ٢٢) والقانون ١٤٠ لسنة ٢٠١٧م وقانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ أحكاماً خاصة بالمفقود، وهذه الأحكام يمكن بيانها فيما يلي، بعد بيان ما يجب فعله للاحتياط في إدارة أمواله وحفظها واستيفاء الحقوق المقرر له.

إقامة وكيل عن المفقود قبل الحكم بموته:

إذا غاب إنسان فلم يعرف له مكان، ولا يعلم حياته من موته، كان أول ما يجب فعله هو الاحتياط في إدارة أمواله وحفظها واستيفاء حقوقه، وقد نصت المادة (٧٤ من قانون الولاية على المال) على أن المحكمة تقيم وكيلاً عن المفقود متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه وتضيف المادة (٧٥) أنه: إذا كان قد ترك وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصى وإلا عينت غيره ويظل الوكيل عن المفقود قائماً على أن يعود، أو يتيقن موته أو بالحكم من

المحكمة باعتباره ميتاً وتسري في الوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة بشأن الوصية على القصر، ويسرى على الوكلاء عنهم الأحكام المقررة في شأن الأوصياء (م ٧٨ ولاية على المال).
أحكام المفقود:

ودراسة أحكام المفقود يجب التمييز فيها بين ثلاث حالات:
الأولى: حالة المفقود طوال مدة فقده.
الثانية: الحكم بموت المفقود وأثره.
الثالثة: أثر ظهور المفقود حياً بعد الحكم بموته، ويحسن تخصيص فرع لكل حالة من الحالات الثلاث.

الفرع الأول

الحكم بموت المفقود

لا يمكن اعتبار المفقود حياً طوال الأبد، بل لابد من الحكم بوفاته بعد مدة يغلب على الظن فيها موته، ولكن متى يمكن الحكم بوفاته؟

اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع اختلافاً كبيراً، وقبل صدور المرسوم بقانون (رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩) كان العمل في نطاقه وفقاً لمذهب الإمام أبي حنيفة، ووفقاً لهذا المذهب فإنه لا يحكم بموت المفقود إلا بعد موت آخر أقرانه في السن، وهذا أمر يتعذر التحقق منه، إن لم يكن غير ممكن في معظم الأحوال^(١).

(١) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٥٥١ وما بعدها.

وأحدث القوانين التي نظمت أحكام المفقود هو القانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٧م والتي جاءت نصوصه على النحو الآتي:

المادة الأولى: يُستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (٢١)، وبنص المادة (٢٢) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، النصان الآتيان:

مادة (٢١) - الفقرة الثانية والثالثة (بعد التعديل):

وَيُعْتَبَرُ المفقود ميتاً بعد مضي ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو بعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفُقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفُقد أثناء العمليات الأمنية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتُبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

مادة (٢٢) (بعد التعديل):

عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو وزير الداخلية باعتباره ميتاً على الوجه المبين في المادة (٢١) من هذا القانون، تعتبر الزوجة عدة الوفاة، وتقسّم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، وتترتب عليه كافة الآثار الأخرى.

أما المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ فقد فرّق في الحكم بموت
المفقود بين حالتين:

الحالة الأولى: حالة غلبة الهلاك:

وفيها يحكم بموت المفقود الذي يغلب فيها الهلاك بمضى أربع
سنوات على الأكثر من تاريخ فقدته مثل من خرج راحلاً في مفازة
مهلكة، أو خرج إلى ميدان القتال.

الحالة الثانية: حالة عدم غلبة الهلاك:

ويحكم فيها بموت المفقود بعد مضي أربع سنوات على الأقل.
وهذه الحالة يفوض أمر المدة التي يحكم فيها بموت المفقود إلى
القاضي بعد التحرى عنه بكافة الطرق الممكنة لمعرفة ما إذا كان حياً
أو ميتاً، وذلك في الحالات التي ينقطع فيها خبر المفقود فيما ظاهره
السلامة، كمن خرج في تجارة أو في طلب العلم والسياحة، فهؤلاء
وأمثالهم يفرض القانون أمر تحديد المدة للقاضي، حيث يحكم بموت
المفقود إذا مضت مدة لا يعيش مثله إلى غايتها، والغالب في رأى
الفقهاء اعتبار سن التسعين حداً أقصى لذلك^(١).

الفرع الثانى

حالة المفقود طوال مدة فقدته

والمفقود طوال مدة فقدته يخضع لما تقضى به الأحكام الشرعية
من أن المفقود يعتبر حياً في حق الأحكام التي تضره، وتترتب على

(١) وهذا الرأى قريب مما يراه المذهب الحنبلي وبعض فقهاء المالكية، راجع: فتاوى ابن تيمية،

ثبوت موته ويعتبر ميتاً من حق الأحكام التي تنفعه وتضرر غيره وتترتب على ثبوت حياته^(١).

ويترتب على ذلك:

أن مال المفقود لا يوزع على ورثته، ولا ترفع عنه النفقة الواجبة عليه فيمن يعوله كزوجته وأولاده، ذلك أن تقسيم التركة على الورثة، ورفع النفقة أحكام ترتب على الوفاة، فلا يجوز أن تنطبق على المفقود لاحتمال كونه حياً^(٢).

ومقتضى ذلك أيضاً ألا يفرق بينه وبين زوجته إلا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه (مادة ١٢ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩م)، وذلك خوفاً على نفسها من الفتنة وطلباً لحقها في العفة.

ومن ناحية أخرى، فإن المفقود لا يرث أحداً ممن مات من أقاربه، ولا يستحق بالفعل ما يوصى به له، لأنه يعتبر ميتاً بالنسبة لهذه الأحكام التي يشترط لها التحقق من حياة صاحبها وقت وجوبها. فاعتبار المفقود حياً في الحالات الأولى قصد به إبقاء ما كان على ما كان، أي أنه يصلح علة لبقاء ما كان ثابتاً من الحقوق، ولكن هذا الافتراض لا يصلح سبباً لاكتسابه حقوقاً جديدة.

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٥٥١، د. عبد الودود يحيى، ص ٢٣٣ وما بعدها.

(٢) د. على سيد حسن، ص ٧٦ وما بعدها.

ومن باب الاحتياط فإن أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بأن يوقف للمفقود من التركة بقدر نصيبه الذي يستحقه لو كان حياً، وكذلك يحفظ ما أوصى له^(١) به (مادة ٤٥ من قانون الموارث).

أثر الحكم بموت المفقود:

ومتى حكم بموت المفقود، فإنه يعتبر ميتاً من تاريخ صدور الحكم بالنسبة لماله، أما بالنسبة لمال غيره فإنه يعتبر ميتاً من تاريخ الفقد.

وبناء عليه:

يرد نصيبه الذي حجز له في الإرث إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه وكذلك الوصية ترد إلى ورثه الموصى، وإنسحاب الحكم على الماضي بالنسبة للإرث وغيرهما، وهو رأى أبي حنيفة، ومالك رضى الله عنهما، وبه أخذ قانون الميراث في المادة (٤٥) التى تقضى بأنه: "يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حياً أخذه، وأن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وثت موت مورثه^(٢)".

أما أمواله فتعتبر تركة من يوم الحكم بموته وتقسم هذه التركة بين ورثته الموجودين وقت الحكم، وكذلك تعتد زوجته عدة الوفاة ما لم تكن قد طلقت منه قبل ذلك، ولها بعد انقضاء العدة أن تتزوج بمن تراه مناسباً لها إذا تقدم طالباً يدها (مادة ٢٢ من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩م).

ظهور المفقود بموته حياً:

(١) المرجع والمكان السابقان، ص ٧٦ وما بعدها، د. محمد شكرى سرور، ص ١٥٥.

(٢) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٥٥٣، د. توفيق فرج: المدخل لعلوم القانونية ١٩٨١،

وإذا ظهر المفقود الذي حكم بموته حياً، فإن شخصيته تعود إليه ويترتب على هذا العود آثار لا تضر بالغير حسن النية، سواء أكان ذلك فيما يتعلق بزوجه أم بأمواله.

(١) أما بالنسبة لزوجته:

فإنها إذا كانت لم تتزوج فإنها تظل على ذمته، أما إذا كانت قد تزوجت، فإن في الأمر تفصيلاً، فإذا كان الزوج الثاني قد عقد عليها، ولم يدخل بها، فإنها تعود إلى زوجها الأول، ويقضى بفسخ عقد الثاني حيث ظهر بطلانه، وكذلك الأمر إذا كان الزوج الثاني قد تزجها وهو يعلم بحياة زوجها الأول فإنها ترد إلى الأول لسوء نية الزوج الثاني، أو كان قد عقد عليها في فترة عدتها من المفقود.

أما إذا كان الزوج الثاني حسن النية، أى لا يعلم بحياة المفقود، ودخل بالزوجة، ولم يكن قد عقد عليها خلال العدة من الزوج الأول فإنها تكون له^(١)، وهذا رأى الحنابلة مع خلاف في بعض التفصيلات^(٢).

(٢) أما بالنسبة لأمواله:

في هذه الحالة إذا عاد المفقود فإنه يسترد ما بقى قائماً من أمواله التى قسمت بين ورثته، تحت أيدي هؤلاء الورثة كما يسترد كذلك ما يوجد من استحقاقه في إرث مورثه في أيدي ورثة هذا الأخير، وما يوجد في الوصية في أيدي ورثة الموصي أما ما استهلكه هؤلاء من هذه الأموال، أو ما تصرفوا فيه، فإنهم لا يسألون عنه في

(١) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٥٥١.

(٢) راجع: المغنى، ج٧، ص ٤٩٢ وما بعدها، وفتاوى ابن تيمية، ج٢، ص ٥٧٦.

مواجهة من كان مفقوداً، وقد آلت إليهم بسبب شرعى وهو حكم القاضي^(١).

المطلب الثانى

هوية الشخص الطبيعى

وهوية الشخص القانونية تتحدد ذاتياً باسمه الذي يحمله، كما تتحدد ولائياً بحالته الدولية أو العائلية أو الوطنية التى يتحدد من خلالها جنسية الشخص وقرابته موطنه، ونعرض لهذه الأمور في ثلاثة فروع، نخصص أولها: لحق الشخص الطبيعى في تمييز ذاته باسم يتخذه، وثانيها: لحالته، وثالثها: لموطنه.

الفرع الأول

حق الشخص فى تمييز ذاته الحق فى الاسم

والحق فى اتخاذ اسم يمثل حقاً شخصياً للإنسان فى تمييز ذاته على نحو يتحدد من خلاله كيانه عن كيان غيره من الناس، ويمكن أن يعرف حق تمييز الذات من خلال ما درج عليه الشراح فى بيانهم لاسم الشخص الطبيعى.

ومن الثابت أن لكل شخص الحق فى أن يتميز بشخصه عن الأشخاص الآخرين، ولما كان هذا لا يتم له إلا عن طريق الاسم، كان لكل شخص الحق فى أن يكون له اسم، وكان حق الإنسان فى أن يكون له اسم من الحقوق التى تتصل بشخصه، والتى لا تقدر بمال.

(١) د. محمد شكرى سرور، ص ١٥٦، د. جميل الشرقاوى، المرجع السابق.

إن الاسم هو مظهر الحياة الأدبية والمادية للشخص في كل علاقاته العائلية والاجتماعية، كما أنه علامة الإنسان التي يتميز بها في حياته العامة والخاصة، بل إنه يُعد عنصراً من عناصر الشخصية لا يجوز تشبيهه بالأشياء أو جعله محلاً للتعامل، إنه علاقة رمزية على المواهب الشخصية من ذكاء واستقامة وشرف ومهارة وعلى مركز الشخص باعتباره مواطناً، يكتسب حقوق المواطنة ويتحمل بالتزاماتها. **مضمون حق الإنسان في تمييز ذاته:**

ويتمل حق الإنسان في تمييز ذاته باسمه الذي يميزه والذي يسمى بالاسم المدني، ويتكون اسم الشخص المدني من عنصرين:
أولهما: الاسم الشخصي.
وثانيهما: اللقب.

أما الاسم الشخصي: فإنه هو الذي يعين به به الشخص تعييناً ذاتياً خاصاً، ويكون اختيار الاسم لمن له الولاية على الطفل، فإنه لم يكن له ولي، كان اختيار الاسم واجباً على القائمين على الجهة التي تلقت أول ولادته.

وقد حرصت بعض القوانين الأجنبية على أن يكون الاسم اسم الإنسان بحيث لا يعرض صاحبه للسخرية، أو يشكك في أصله كما حظرت أن يطلق على الشخص أسماء مضحكة أو مخلة بالحياء أو النظام العام أو الشعور الديني أو الوطني، وأن يطلق على من

لا يعرف آباؤهم أسماء تدل على ذلك، وأعطت للنيابة العامة في مثل تلك الأحوال وغيرها، الحق في تغيير هذه الأسماء^(١).

أما في مصر، فقد نصت المادة ٢١ من القانون ١٤٣ لسنة ١٩٩٤، على أنه: "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً، أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية" ومن تلك الأحكام التي لا يجوز مخالفتها أن يكون الاسم حسناً لا يُعير صاحبه أو موجباً لعبادة غير الله سبحانه أو متجاوزاً للأحكام الشرعية في إثبات النسب بأن ينسب مولوداً لغير أبيه، أو والداً لغير ولده، ويجوز تغيير الاسم القبيح إلى اسم حسن اقتداء بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسئولية التسمية تقع على عاتق من يجب عليه التبليغ إلا إذا كان ثمة حرج في ذلك، بأن كان الوالدان من المحارم، أو كان المولود من غير زوج الوالدة، أو كان الزوج غير مسلم، وجاء المولود من غير زوجته الشرعية، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، مادة (٢٧) من القانون ١٤٣ لسنة ١٩٩٤.

أما اللقب، فهو اسم العائلة، ويلاحظ أن القانون المدني المصري الجديد قد فرض على كل شخص أن يتخذ إلى جانب اسمه لقباً يميزه، حيث إن الاسم وحده لا يكفي للتمييز، وهذا نظام جديد أتى

(١) مثال ذلك: القانون الإيطالي الصادر في ١٥ نوفمبر ١٨٦٥م الذي ينظم الحالة المدنية.

به المشرع المصري، ولما كان نظام الألقاب نظاماً مستحدثاً، يكون من المهم إصدار تشريع خاص ينظم كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها^(١).

كما نص القانون على أن لقب الشخص يلحق أولاده، وعلى هذا فالطفل الشرعى يكتسب بمجرد ولادته لقب أبيه، ويحصل هذا الاكتساب وفقاً لحق الدم، لا وفقاً لحق الإرث، لأن الطفل يكتسب اللقب حال حياة والده لا بعد وفاته فحسب، وبناء على ذلك فإن الشخص يتكون كاملاً بصورتين هما: ذكر اسمه واسم أبيه، واسم جده، أو اسمه واسم أبيه ولقبه، ويكون كل واحد من هذين الطريقتين معبراً عن شخصه تعبيراً قانونياً صحيحاً، والقاعدة العامة في قانوننا أن الاسم واللقب لا يقبلان التغيير بمحض إرادة الشخص، خلافاً لما كان عليه الحال في القانون الرومانى، حيث كان للأفراد في هذا الصدد حرية واسعة، ولقد نص القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤م، على الإجراءات التى يجب اتباعها عند تغيير الاسم، فعلى من يريد أن يغير اسمه أو يصحح ما ورد بشأنه في شهادة الميلاد، أن يقدم طلباً بذلك إلى المديرية أو المحافظة التى ولد بدائرتها، ولا يتم تغيير الاسم أو تصحيحه إلا بقرار من وزير الصحة بعد موافقة لجنة خاصة وبعد النشر والإعلان عن طلب التغيير^(٢)، ونظمت المادة ٤٦ من قانون الأحوال المدنية تشكيل اللجنة المختصة بتصحيح قيود الأحوال المدنية من المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة، ومدير الأحوال المدنية

(١) المادة ٣٩ من القانون المدني المصري الجديد.

(٢) المادة ٣٤ من القانون ١٤٣ لسنة ١٩٩٤م.

بالمحافظة، ومدير الشئون الصحية بالمحافظة وحددت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور كيفية عملها واختصاصاتها.

صور التعدي على حق الإنسان في اسمه:

لصاحب الاسم أن يستخدمه في كل مظاهر نشاطه إسوة بأى حق آخر من حقوق الشخصية، ومن ثم يكون له أن يطلب إلى القضاء حماية اسمه ضد من ينازعه فيه بلا مبرر، وضد من ينتحله بدون حق، وقد نصت على ذلك (المادة ٥١ من التقنين المدني الجديد) فقالت: "لكل من نازعه الغير من استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه بدون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر" ويبدو من هذا النص أن التعدي على حق الإنسان في اسمه يكمن في منازعته على هذا الاسم من جانب الغير، وذلك باستعماله في منازعة رسمية بعمل قضائي أو غير قضائي، كإنتحال الاسم مثلاً، وسواء كانت بقول أو بفعل أو امتناع، ولا يحتاج التعدي في تلك الحالات إلى حسن أو سوء نية الغير الذي يتنازع في استعمال الاسم، وإنما يكفي لحصول التعدي أن تكون ثمة منازعة في استعمال الاسم، وكفى، وذلك بغرض وقف أعمال المنازعة على الاسم في الحاضر والمستقبل^(١)، كما يتحقق التعدي على الاسم بإنتحاله من الغير دون حق، وذلك بأن يستعمل الغير نفس الاسم بدون حق، وبالطبع فإنه يخرج من تلك الحالة

(١) د. عبد الحي حجازي، المرجع نفسه، ص ٣١.

استعمال الشخص لاسمه هو مستقيماً من تشابه اسمه مع اسم غيره، بحيث يحدث غموضاً في حقيقة شخصيته أو في انتمائه إلى عائلة معينة، بسبب أن هذا لا يعتبر إنتحالاً لاسم الغير، وإن كان هذا الطريق لا يمنع من وجود المسؤولية لا بسبب إنتحال الاسم، ولكن للتشابه الذي يتمخض في النهاية عن ضرر بصاحب الاسم المتشابه مع غيره، لا سمياً إذا تعدد صاحب الاسم المتشابه إخفاء الحقيقة على الناس، فإنه قد يكون بذلك مرتكباً لجريمة النصب، أو التدليس.

ومن صور التعدي أيضاً أن يقع الإنتحال بقصد إطلاق الاسم على شخص ليس له، حتى ولو كان هذا الشخص غير المنتحل، فإذا استعمل شخص اسم غيره لا لإطلاقه على نفسه، ولكن لإطلاقه على شخصية مضحكة، أو على منتجات صناعية، أو على حيوانات أو لاستعماله في رواية أو جرائد هزلية، بحيث يترتب على ذلك ضرر بسمعة أو شرف صاحب الاسم فإن المسؤولية تقع عليه في تلك الحال، وسبب الحماية هنا ليس إنتحال الاسم، وإنما هو التعدي على الشرف والسمعة، وتسري هذه الأحكام على الاسم الحقيقي، كما تسري على الاسم المستعار^(١).

لا يشترط الضرر لحماية الحق في الاسم:

والحق في الاسم يجب أن يحمى لذاته، ويصرف النظر عن حدوث أو عدم حدوث ضرر عن هذا الاستعمال، إن اشتراط حصول

(١) المرجع والمكان السابقان.

الضرر من استعمال الاسم لإمكان رفع دعوى حمايته ينطوى على إنكار الحماية المقررة لحق الإنسان على اسمه، باعتباره حقاً قائماً بذاته وعنصراً لتمييز الشخص، الأمر الذي يترتب عليه أن يكون على صاحب الاسم أن يظل مكتوف اليدين أمام انتحال الغير لاسمه، وذلك لمجرد أنه لا يستطيع أن يثبت وجود الضرر، وهذا يتعارض مع طبيعة حق الشخصية الذي يعتبر مجرد الاعتداء عليه اعتداء على حق الشخص في تمييز ذاته، وذلك الحق الذي يجب أن يحمى بدون توقف للحماية على حظر احتمالي أو حقيقي، وقد قيل بحق: "إن لصاحب المنزل أن يطرد منه ذلك الغريب الذي أقام بالمنزل وهو خال من أهله حتى ولو لم يترتب على إقامته ضرر، بل حتى إذا ترتب على تلك الإقامة مصلحة للمالك كحراسة المنزل وتهويته".

وقد سار القانون المدني المصري على وفق هذا الاتجاه المقبول، فلم يشترط لحماية الحق في الاسم وجود الضرر، سواء في ذلك حالة المنازعة في استعمال الاسم بلا مبرر، أو حالة إنتحال الغير للاسم بغير حق، فأجاز لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر ولمن إنتحل الغير اسمه دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمل يكون قد لحقه من ضرر^(١).

(١) المادة (٥١) من التقنين المدني الجديد.

يدل على ذلك أن القانون بعد أن أعطى لصاحب الاسم الحق في أن يطلب وقف الاعتداء أعطاه كذلك الحق في أن يطلب التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر، ووجه الاستدلال أنه إذا لم يكن هناك ضرر، فليس له الحق في أن يطلب تعويضاً، لكن لا شك أن له الحق في طلب وقف الاعتداء، سواء أوقع لصاحب الاسم ضرر أم لم يقع، أما اشتراط الضرر فهو لإمكان الحكم بالتعويض لا لوقف الاعتداء، فهذا الأخير جائز طلبه في جميع الأحوال دون توقف على شرط حصول الضرر.

الفرع الثاني

حالة الشخص الطبيعي

وحالة الشخص الطبيعي تتحدد من خلال انتمائه إلى دولة معينة، أو أسرة أو ديم معين أو موطن معين، ونخصص لكل موضوع غصناً:

الغصن الأول

الحالة الدولية للشخص (الجنسية)

حالة الشخص الدولية تستمد وجودها من انتمائه لدولة معينة، ويطلق على تلك الحالة اصطلاحاً: الجنسية، وهذه الجنسية قد تكون أصلية، وقد تكون مكتسبة.
أولاً: الجنسية الأصلية:

وجنسية الشخص الأصلية تتحدد وفقاً لأحد مبدأين، أو وفقاً
لهذين المبدأين معاً:

أما المبدأ الأول: فيتمثل في رابطة الدم، التي تستمد من ولادة
الشخص من أصل يتمتع بجنسية الدولة، فمن يولد لأب يحمل جنسية
دولة معينة يكتسب جنسية أبيه بالولادة حتى ولو تمت على أرض دولة
أخرى.

وأما المبدأ الثانى: فيتمثل في رابطة الإقليم، وتحقق تلك
الرابطة بولادة الشخص على إقليم الدولة^(١)، سواء ولد لأب يحمل
جنسيتها أولاً يحمل جنسيتها.

والجنسية المصرية تثبت أصلاً على أساس ربطة الدم الناشئة
عن ميلاد الشخص من أب مصرى، وهي لا تثبت على أساس رابطة
الإقليم وحدها، إلا إذا ولد الشخص لأبوين مجهولين^(٢) (مادة ٢ من
القانون ٢٦ لسنة ١٩٧٥م والمعدل بالقانون ٢٨ لسنة ٢٠٢٣م).

ثانياً: الجنسية الطارئة:

وهي تلك التى تثبت بصفة طارئة، على خلاف الأصل وذلك
عن طريق التجنس، أى منح الجنسية بقرار من السلطة المختصة وإما
عن طريق زواج الأجنبية من مصرى بشروط معينة، والأجنبية إذا
تزوجت بمصرى يكون لها الحق في كسب الجنسية المصرية، إذا

(١) د. جلال العدوى، ص ١٢١.

(٢) د. جلال العدوى، المرجع السابق.

أعلنت عن رغبتها بذلك لوزير الداخلية، واستمرت الحياة الزوجية سنتين على الأقل بعد إعلان هذه الرغبة، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات المدة المشار إليها حرمان الزوجة من حق الدخول في الجنسية، إذا وجد لذلك القرار سبباً يبرر اتخاذه، وبخاصة ما يتعلق بحماية الأمن العام.

وكذلك لمن أقام في مصر إقامة عادية لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل، أن يكتسب الجنسية المصرية إذا طلبها بشرط أن يكون بالغاً سن الرشد، ملماً باللغة العربية محمود السيرة، سليم العقل والجسم، وله وسيلة مشروعة للكسب، وتخفّض هذه المدة إلى خمس سنوات، إذا كانت الإقامة مسبقة بحصول الأجنبي على إذن من وزير الداخلية بالتوطن في مصر^(١)، كما أن من حق رئيس الجمهورية في مصر دون التقيد بشرط الإقامة، أن يمنح الجنسية لأجنبي أدى للدولة أو للقومية العربية، أو للأمة العربية خدمات جليلة^(٢).

تنازع الجنسيات:

تختلف قوانين الدول وأنظمتها في الأساس التي تقيم عليها تنظيم الجنسية، وقد نتج عن هذا الاختلاف أن يجد بعض الأفراد أنفسهم بلا جنسية، أو تتعدد جنسياتهم، وقد حرصت الدول في

(١) د. محمد شكرى سرور، ص ١٦٩.

(٢) المرجع السابق نفسه، د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٥٧١.

تشريعاتها على أن تتقضى بقدر الإمكان هذه الحالات، أو تعالج آثارها بما يجعل لضحاياها مخرجاً من فقد الجنسية.

والراجع في الفقه: أنه في موضوع تنازع القوانين يطبق على عديمي الجنسية قانون موطنهم بدلاً من قانون الجنسية (بالنسبة لأحوالهم الشخصية مثلاً) أما إذا تعددت جنسية الفرد، فقد نصت المادة (٢٥ مدني) على أنه:

(١) يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسيتهم، أو الذين لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.

(٢) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون المصرى هو الذي يجب تطبيقه^(١).

أهمية الجنسية:

ولتحديد الحالة الدولية للشخص أهمية كبرى وذلك لاختلاف مركز الأجانب عن مركز المواطنين، ليس فقط من حيث تولى الوظائف والمناصب العامة والحقوق السياسية التي تقتصر أصلاً على المواطنين، فليس للأجانبى حق الانتخاب وليس له تولى الوظائف العامة، إلا في حالات استثنائية، كما يحظر القانون على الأجانب

(١) د. عبد المنعم البداروى، ص ٥٧٢ وما بعدها.

تملك السفن المصرية، ولا يسمح لهم إلا بنسبة معين من أسهم الشركات المصرية، وملكية أسهم شركات التأمين والبنوك وللوكالات التجارية، كما يحظر عليهم القانون تملك الأراضى الزراعية إلا في حالات استثنائية^(١)، ومن ثم يبدو أهمية الجنسية في حياة الإنسان.

الفصل الثانى

الحالة العائلية

ويتحدد بناء الحالة العائلية للشخص على أساس صلة القرابة، وهذه القرابة تنقسم إلى قرابة نسب وقرابة مصاهرة.
أولاً: قرابة النسب:

ويقصد بقرابة النسب، صلة الدم التى تربط بين من يجمعهم أصل مشترك، وهذا ما عبرت عنه المادة (٢٤ مدني)، بقولها: "ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك وهذه القرابة قد تكون مباشرة، وقد تكون غير مباشرة أى قرابة حواشي".
(أ) القرابة المباشرة:

وتتمثل في الصلة ما بين الأصول والفروع، فلا يكفى لتحقيق هذه القرابة المباشرة أن يجمع بين الشخصين أصل مشترك، وإنما يلزم أن يكون أحدهما أصلاً للآخر، ويكون هذا الآخر فرعاً له مثل صلة الأبْن بأبيه، وصلة الحفيد بجده أو جدته^(٢).

(١) المرجع السابق، ص ٥٦٨، كما حظر القانون اشتغال الأجانب ببعض المهن كالمحاماة،
وراجع: د. جلال العدوى، ص ١٢٢.

(٢) د. جلال العدوى، ص ١٢٣، د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٥٧٨.

كيفية حساب درجة تلك القرابة:

وقد بينت المادة (٣٧ مدني) كيفية حساب درجة القرابة المباشرة، أى درجة القرابة بين الأصول والفروع بقولها: "يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للصل بخروج هذا الأصل".

فإذا أردنا حساب القرابة بين الجد وابن ابنه، وجدناها درجتين، إذا يحسب ابن الابن بدرجة، ثم الابن بدرجة فيكون المجموع درجتين، أما الجد وهو الأصل فلا يدخل في الحساب، ويمكن الوصول إلى نفس النتيجة عن طريق حساب الفواصل بين الأصول والفروع، فبين ابن الابن، والابن (وهو أبوه) درجة، ثم بين الابن والجد درجة، فيكون المجموع درجتين.

(ب) قرابة الحواشى:

وهي القرابة القائمة بين المتفرعين من سلسلة متعددة لا سلسلة واحدة أو هي القرابة بين أشخاص لم ينزل بعضهم من بعض مباشرة، ولكن يجمعهم أصل مشترك، وقد نصت المادة (٣٥ مدني) على أن: "قرابة الحواشى هي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر".

فهي تفترض وجود كل من القريبين على عمود نسب خاص
ويجتمعان عند الأصل المشترك، وعلى ذلك يعتبر من الحواشي الأخوة
والأخوات، والأصل المشترك بينهما هو الأب والأم^(١).

كيفية حساب درجة تلك القرابة:

وقد بينت المادة (٢٦ مدني) كيفية حساب تلك القرابة بقولها: "و
عند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل
المشترك ثم نزولاً إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك
يعد درجة".

وتطبيقاً لهذا، يكون بين أولاد العم أربع درجات، فابن العم
يحسب درجة، وأبوه درجة، أما الجد وهو الأصل المشترك فلا يحسب،
فيكون المجموع درجتين من جهة، وبالمثل هناك درجتان من الجهة
الأخرى فيكون المجموع أربع درجات، هي درجة القرابة بين أولاد
العمومة، وهي أيضاً كذلك بين أبناء الخالة، كما يكون الأخوة أقارب
من الدرجة الثانية، وقرابة الولد بعمه من الدرجة الثالثة، وكذلك القرابة
بين العمّة والخال والخالة.

ثانياً: قرابة المصاهرة:

وهي العلاقة التي تقوم بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر،
وقد نصت المادة (٢٧ مدني) على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون
في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

(١) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٥٧٩.

فكان الأسرة تشمل - إلى جانب الأقارب عن طريق النسب أو الدم الذي سبق ذكرهم- أقارب الزوج الآخر، أى أصوله وفروعه وحواشيه أيضاً، فالزوج مرتبط بأقاربه هو برابطة النسب، ويتربط بأقارب زوجته برابطة المصاهرة، ولهذا يُعد من أقارب الشخص والد زوجته، رأسياً، وأخوتها وأخوالها، وأعمامها وخالها وخالتها، وفروع هؤلاء جميعاً.

درجة قرابة الزوج بزوجه:

ويلاحظ أن درجة القرابة متلاشية بين الزوج وزوجه، لأن كل واحد منهما في نفس منزلة الشخص الآخر، أو هما معاً نفس واحدة، كما قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (١).

ففي الآية إشارة إلى أن الزوج والزوجة يعتبران نفساً واحدة في درجة القرابة، ومنهما - معاً - تتفرع قرابة الفروع بدرجة متساوية لكل منهما، ومن ثم تكون درجة القرابة بينهما هي درجة (الصف)، ويكون الزوج أقرب لزوجه من أبيها وأُمها، لأن ما بينه وبينها من القرابة وإن كانت درجته أولى وواحدة، إلا أن ما بينه وبين زوجته من القرابة لا درجة له أصلاً، فالدرجات بينهما متلاشية، ومن فضل الله على الناس أنه جعل تلك القرابة المكتسبة بعقد الزواج سبباً لعلاقة بين

(١) سورة النساء - الآية الأولى.

الزوج وزوجته تجعلها أقرب إليه من أبيه وأمه، كما يجعله أقرب إليها من أبيها وأمها، ويكون حق كل منهما على الآخر مقدماً ومقدراً وفقاً لهذا الاعتبار من درجة القربى بينهما.

ويلاحظ أن أقارب الزوج لا يدخلون في أسرة أقارب الزوجة بل يدخلون فقط في أسرة الزوجة هي نفسها، كما أن أقارب الزوجة لا يدخلون في أسرة أقارب الزوج، بل في أسرة الزوج هو نفسه، فقربة المصاهرة لا تربط بين أقارب الزوجين، بل هي ترتبط بين أقارب أحد الزوجين والزوج الآخر، فلا قرابة بين شقيق الزوج ووالد الزوجة أو أمها^(١).

وتحسب درجة القرابة في المصاهرة، كما تحسب في قرابة النسب تماماً، وقد نصت على ذلك المادة (٣٧ مدني) بقولها: "أقارب كل واحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر".

آثار قرابة المصاهرة:

من المقرر أنه ليس هناك توارث بين الأصهار، كما أنه ليس هناك التزام بالنفقة على زوجة الأب إلا إذا كان الأب فقيراً وأساس هذا الالتزام قرابة الأبوي وليس المصاهرة ولذلك فإن الأب إذا مات فإن هذا الالتزام ينقضي، ولكن لعلاقة المصاهرة أثرها من ناحيتين هما:

(١) تحريم الزواج بأقارب الزوجة:

(١) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٥٨٠، د. عبد الحي حجازي، ص ١٢٨.

يحرم على الزوج أن يتزوج بأقارب زوجته وهم أصول الزوجة، فلا يحل للزوج أن يتزوج بأُم الزوجة وإن لم يكن قد دخل بها، لقول الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ^(١)، والبنت المعقود عليها من نساء الزوج فتحرم أمها، ولذلك يقرر الفقهاء: أن العقد على البنات يحرم الأمهات، وأن الدخول بالأمهات يحرم البنات، لقول الله تعالى: {وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ^(٢)، فجعل الدخول بالأم شرطاً لتحريم الربيبة وهي ابنتها التي في حجر زوجها، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان قد دخل بأمها، ولم يجعل ذلك شرطاً في حالة البنت، واقتصر النص على مجرد ذكر أمهات النساء دون اشتراط الدخول بهن، وأن كن بالعقد محلاً لذلك، ومن ثم فلا يحل للزوج أن يتزوج بفروع زوجته التي دخل بها، كما تحرم زوجة الفرع، وتحرم زوجة الأصل.

(٢) وقد تكون المصاهرة مانعاً مؤقتاً من الزواج:

ومن ثم فلا يحل للزوج أن يتزوج بأخت زوجته، أو عمتها أو خالتها أو يجمع بين الأخت وابنة أخيها أو ابنة أختها، وضابط ذلك: أنه لا يجوز شرعاً أن يجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداها ذكراً لما حل لها أن تتزوج بالأخرى.

أهمية الحالة العائلية:

(١) سورة النساء - من الآية ٢٣.

(٢) سورة النساء - نفس المكان الكريم.

ولتحديد حالة الشخص العائلية، وحساب درجة قرابته أهمية من ناحيتين، فمن ناحية تكون الحالة العائلية منوطاً لتقرير بعض الحقوق والسلطات كحق الإرث، وحق النفقة وحق التعويض عن الضرر الأدبي في القضايا التي يورث محلها والتي تقوم على التشفي، بالإضافة إلى أن القرابة قد تكون مانعاً من موانع الزوج، أو موانع سماع القاضي للدعوى إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة^(١)، كما قد يكون لها أثر ضار كما في المنع من تولى بعض الوظائف بسبب ما قد ينسب لأحد ذوي قربي الشخص حتى درجة معينة من الأفعال المشينة أو الأحكام الماسة بالسمعة والمكانة، وهو ظلم يخالف قول الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ^(٢)، ويتعين عدم الاعتداد بذلك عند تقييم الشخص في حالة الوظائف العامة، أو المناصب القيادية.

الفصل الثالث

الحالة الدينية

لا يعتبر الدين في كثير من الدول أحد عناصر الشخصية القانونية، أو عوامل تحديد هوية الشخص، إذ أن القانون يطبق على الجميع، دون تفرقة بينهم على أساس الدين ولكن في بعض الدول وخاصة مصر، يكون لإنتماء الشخص إلى ديانة معينة، أثره بالنسبة

(١) ارجع في تفصيل هذا الموضوع: د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٥٨٢ وما بعدها.

(٢) سورة الإسراء، من الآية ١٥.

لشخصيته القانونية، ومدى ما يثبت له من مكناات أو يتحمل به من التزامات.

ولهذا تؤثر الحالة الدينية على جانب من جوانب شخصيته القانونية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الشخصية، التى تختلف باختلاف حالة الشخص الدينية، ومن ذلك تعدد الزوجات - مثلاً - فإنه مباح بالنسبة لمسلمين بينما يُعد ذا التعدد محرماً بالنسبة لغيرهم، ومن ذلك عدم التوارث بين المسلم وغيره وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أن للمسلم حق الطلاق، وليس ذلك لغير المسلم مع تفصيل يختلف مداه من ملة لأخرى عند غير المسلمين.

والشريعة الإسلامية تطبق على غير المسلمين إذا اختلفوا في الديانة أو الملة أو الطائفة^(١)، ويجرى حالياً إعداد قانون يجمع الطوائف الملية

كلها في إطار قانون واحد ينطبق عليهم أحكام ديانتهم دون اعتبار للاختلاف المقرر حالياً في الديانة أو الطائفة أو الملة حتى نطبق عليهم أحكام الشريعة الإسلامية، ويلاحظ أن هذا التطبيق لم يكن فرضاً لسطوة الشريعة على غير المسلمين، بل كان اللجوء إليها ضرورة تشريعية ملحة لتوحيد المراكز القانونية في المسائل المتحدة وتحقيق العدالة على المستوى الأسرى، وكانوا هم الذين يطلبون الاحتكام إليها للخروج من أزمة أسرية يريدون الإسراع في حلها.

(١) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٥٨٩ وما بعدها، د. جلال العدوى، ص ١٢٥ وما بعدها.

الفرع الثالث

موطن الشخص الطبيعي

يرتبط الشخص داخل إقليم الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو خارجه بمكان معين يطلق عليه: الموطن، حتى يمكن أن يرجع إليه فيه، وتحدد على أساسه الأوضاع القانونية بعلاقاته، إذ الموطن هو المكان الذي يباشر فيه الإنسان أعماله ونشاطه عادة^(١).

أهمية الموطن:

ولموطن الشخص أهميته بالنسبة له ولغيره، وتظهر هذه الأهمية عادة في عدة وجوه منها:

أولاً: أن الإعلانات القضائية أو الأخطارات القانونية توجه إلى الشخص في موطنه، ويعتبر علمه بتلك الإعلانات مفترضاً حتى ولو لم يكن موجوداً في موطنه وقت توجيهها.

ثانياً: يتحدد مكان الوفاء بالالتزامات في بعض الحالات على أساس موطن المدين بالالتزام، وقد نصت المادة (٣٤٧ مدني) على أن: "الالتزامات التي يكون محلها شيئاً غير معين يجب الوفاء بها، في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء".

ثالثاً: يتحدد الاختصاص القضائي في بعض الحالات على أساس موطن الشخص، وقد نصت على ذلك المادة (٤٩ مرافعات)

(١) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٥١٩.

بقولها: "الدعوى الشخصية يكون النظر فيها من اختصاص المحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعي عليه".

رابعاً: في بعض حالات تنازع القوانين: يتحدد القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع قوانين عدة دول في حكم علاقة ذات عنصر أجنبي، على أساس الموطن، وقد نصت على ذلك المادة (١٩ مدني) فقررت أن: "الالتزامات التعاقدية يسرى عليها قانون الدولة، التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتخذ موطن ما لم يتفق على غير ذلك"^(١).

خامساً: كما يقضى القانون التجاري بأن الاختصاص بشهر إفلاس التاجر يكون للمحكمة التي يتبعها موطن التاجر المراد شهر إفلاسه (مادة ١٩٧ تجاري).

سادساً: يستلزم القانون على سبيل الاستثناء مباشرة بعض العقود في الموطن، فعقد الزواج يجب أن يتم توثيقه أمام المأذون الذي يقع في دائرته محل إقامة الزوجة، والطلاق يجب أن يوثق صدوره امام المأذون الذي يقع في دائرته موطن الزوج^(٢).

أنواع الموطن:

وقد يوجد للشخص بجانب موطنه العام الذي يعتد به فيما يتعلق بعلاقاته القانونية - بوجه عام - موطن خاص، ينعقد

(١) د. جلال العدوى، ص ١٢٦ وما بعدها.

(٢) د. عبد المنعم البدر، ص ٥٩٣.

الاختصاص له في بعض هذه العلاقات، ولهذا ينبغي بيان المواطن العام أولاً، ثم تعرج ثانياً لبيان المواطن الخاص.
أولاً: المواطن العام:

والمواطن العام هو الذي يتحدد على أساس الإقامة مع الاستقرار، وهو المواطن الذي يعتد به بالنسبة لكل شئون الشخص كقاعدة عامة، ومعنى ذلك أن من يريد أن يخاطب شخصاً معيناً عليه أن يتوجه إليه في المكان الذي يقيم فيه عادة ولذلك يسمى هذا المواطن بالمواطن العام^(١)، وهذا المواطن ينقسم إلى نوعين: اختياري، والزامي.

(أ) المواطن العام الاختياري:

وفيه يتخير الشخص بنفسه وإرادته المكان الذي يقيم فيه عادة، ولذلك يقال: إن المواطن العام هنا اختياري، فالقانون لا يفرض موطناً أو محل إقامة معين على الشخص، بل إن الدستور ينص في المادة (٥٠) على أنه: "لا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما، ولا يلزم بالإقامة في مكان معين لا في الأحوال المبينة في القانون".

(ب) المواطن العام الإلزامي:

هناك بعض الأشخاص ممن ليس لهم موطن عام اختياري، يتحدد بالمكان الذي يختارونه لإقامتهم بصفة معتادة، وإنما يكون لهم

(١) د. أحمد سلامة، ص ١٦٤.

موطن عام إلزامى يحدده القانون بصفة إلزامية بصرف النظر عن إقامتهم أو عدم إقامتهم فيه بصفة معتادة، وهؤلاء الأشخاص هم عديمو الأهلية وناقصوها والمفقود والغائب وموطن هؤلاء موطن من ينوب عنهم قانوناً (مادة ١/٤٢ مدني)، وحكمه ذلك رعاية مصلحة القصر والمحجوزين بوجه عام، لأنهم لا يباشرون بأنفسهم تصرفاتهم القانونية، وإنما يقوم بتلك التصرفات من ينوب عنهم قانوناً، وليس من ينوب عنهم، لأن الالتجاء إليهم غير مجد لعدم قدرتهم على مباشرة أعمالهم بأنفسهم.

ثانياً: الموطن الخاص:

والى جانب الموطن العام، هناك الموطن الخاص، وقد نصت المواد (٤١، ٢/٤٢، ٤٣) على حالات ثلاثة يكون للشخص فيها موطن خاص بجانب الموطن العام وهي:

(١) موطن الأعمال أو الموطن التجاري أو الحرفى (مادة ٤١).

(٢) موطن القاصر المأذون له بالإدارة (مادة ٢/٤٢).

(٣) الموطن المختار (مادة ٤٣).

وبذلك يبدو أن للموطن الخاص ثلاث حالات^(١):

الأولى: موطن الأعمال أو التجاري أو الحرفى:

(١) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٦٠١، د. جلال العدوى، ص ١٣٠ وما بعدها.

وقد نصت المادة (٤١ مدني) على أنه: "يعتبر الكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة".

ويبدو من هذا النص أن التجار وأصحاب الحرف لهم موطن خاص بالأعمال المتعلقة بتجارتهم أو حرفتهم، أما ما عدا ذلك من أعمالهم فإنهم يخاطبون بشأنه في موطنهم العام ولا يثبت للعمال والموظفين موطن خاص بعلمهم^(١).

الثانية: الموطن الخاص ببعض أعمال ناقصى الأهلية:

ما تنص المادة (٢/٤٢ مدني) على أنه: "يكون للقاصر الذي بلغ ثمانى عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها".

ولئن كان هذا النص لم يذكر سوى القاصر الذي بلغ ثمانى عشر سنة، ومن في حكمه فإن من المسلم به أن حكمه يمتد إلى القاصر الذي لم يبلغ ثمانى عشرة سنة من باب أولى، وذلك بالنسبة للأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها، بحيث يكون له موطن خاص بهذه الأعمال، هو المكان الذي يقيم فيه عادة وذلك بجانب موطنه العام المعتبر قانوناً، وهو موطن نائبه القانوني^(٢).

الثالثة: الموطن المختار:

(١) د. جلال العدوى، ص ١٣١.

(٢) د. عبد المنعم البدرأوى ص ٦٠٢ وما بعدها.

كما يجوز للشخص أن يختار موطناً خاصاً لمباشرة عمل معين من أعماله، أو نشاط محدد من أنشطته كمكتب أحد المحامين مثلاً، وتقضى المادة (٤٣ مدني) أن يكون الوطن المختار ثابتاً بالكتابة. وهذا الموطن يكون محدداً لتنفيذ علم عين أو مباشرة نشاط محدد كموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل أو النشاط بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، وذلك ما لم يشترط صراحة قصر الموطن على أعمال معينة^(١).

كيفية تحديد الموطن:

وقد اختلفت الشرائع في تحديدها للموطن، وذهبت في هذا التحديد مذهبين، الأول: يأخذ بالتصور الواقعي للموطن، والآخر يأخذ بالتصور الحكي.

(أ) التصوير الواقعي للموطن:

وبمقتضاه يتحدد الموطن بالمكان الذي يقيم فيه الإنسان عادة، وبهذا ترتبط فكرة الموطن، وبالإقامة الفعلية، ويتفرع على هذا التصوير نتيجتان:

الأولى: إمكان إنعدام الموطن:

فإذا كانت الإقامة المعتادة المستمرة هي أساس ثبوت الموطن، فإنه يمكن أن يوجد بعض من لا يكون له موطن مثل البدو الرحل

(١) د. جلال العدوي، ص ١٣٢.

الذين لا يقر لهم قرار في موطن معين^(١)، وعدم اختصام هؤلاء وجب أن يكون ذلك في الجهة التي يكونون موجودين فيها عند رفع الدعوى.

الثانية: تعدد الموطن

فالشخص وفقاً لهذا التصوير يمكن ان يكون له أكثر من موطن عام، كما هو الشأن في حالة تعدد الزوجات، وإقامة الزوج مع كل منهما إقامة متعade في منزل مستقل، وتعدد الموطن يسهل للدائنين مخاطبة المدين، فهم يختارون الموطن الأقرب لهم شخصياً^(٢).

(ب) التصوير الحكى للموطن:

وبمقتضى هذا التصوير يتعين الفصل بين الموطن ومحل الإقامة، فالموطن هو المكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسى لأعمال الشخص ومصالحه، لا المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، صحيح قد يكون هذا الموطن هو في نفس الوقت مكان الإقامة العادية، ومع ذلك فإنه لا يختلط به، فمركز النشاط الرئيسى هو الذي يحدد موطن الشخص، كالمصنع بالنسبة لرجل الصناعة، والمتجر بالنسبة للتاجر، وإن أقام أى منهم في مكان آخر.

ويقوم هذا التصوير على أساس أن الموطن فكرة قانونية لا مادية، فهو مركز الحياة القانونية للشخص، إذ فيه يخاطب بالنسبة للأعمال القانونية، وليس أصلح لهذا من مركز أعمال الشخص

(١) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٥٩٢.

(٢) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٥٩١.

ونشاطه الرئيسى، ففيه يستوفى ما له ويقتضى ما عليه، ومن ثم يفترض قطعاً انه موجود في مركز أعماله^(١).

ويترتب على هذا التصوير نتيجتان:

الأولى: أن كل شخص لابد وأن يكون له موطن، لأن الموطن بالنسبة لهذا التصوير هو محل الشخصية القانونية التى لابد أن تتصل بموطن معين، وهذا الموطن يكتسبه الشخص بالولادة وهو موطن أبويه، أو موطن الوصى عليه، فإذا بلغ سن الرشد فموطنه هو المكان الذي يختاره ليكون مركز أعماله وإن لم يفعل كان معنى ذلك أنه متحفظ بموطنه الأصلي الذي اكتسبه بالميلاد.

وبناء على ذلك: يكون للبدو الرحل موطن وإن كان مجهولاً إذ هم يختصمون إلى محكمة الجهة التى يوجدون فيها، فمحل الوجود يقوم مقام الموطن إذا كان مجهولاً.

الثانية: من حيث وحدة الموطن وتعددده، فإنه لا يمكن أن يكون للشخص إلا موطن واحد، ذلك أن مناط الموطن في هذا التصوير هو المركز الرئيسى للأعمال، وهو لا يمكن إلا أن يكون واحداً.

اتجاه القانون المصرى:

والقانون المصرى صريح في الأخذ بالمذهب الواقعى للموطن بما يترتب عليه من نتائج، ويبدو ذلك من نص المادة (٤٠ مدني) التى تقرر أنه:

(١) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٥٩٥.

- (١) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
- (٢) ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن ما.

وقد أخذ القانون المصرى بالاتجاه الواقعى لأنه يمتاز بالبساطة والوضوح، إذ لا افتراض فيه ولا تخيل، كما أنه يربط الموطن بمحل الإقامة العادية للشخص، وتحديد هذا المحل أمر يسهل إثباته على نحو ييسر التعامل ويؤدى إلى سرعة الفصل في المنازعات^(١).

المطلب الثالث

أهلية الشخص الطبيعى

تعرف الأهلية لغة بأنها: صلاحية الشخص لتولى أمر معين، أو هو مستحق له بسبب تأهله، ومنه استأهل الشيء، أى استوجبه واستحقه^(٢)، وفي اصطلاح الفقهاء **تعرف الأهلية بأنها:** "صلاحية للشخص لأن تثبت له حقوق وتتعلق به واجبات، ولأن يباشر بنفسه الأعمال القانونية والفضائية المتعلقة بهذه الحقوق"^(٣).

(١) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٥٩٦، د. جلال العدوى، ص ١٢٩.

(٢) المعجم الوجيز، ص ٢٩، طبعة ٢٠٠٤.

(٣) د. عبد الودود يحيى، ص ٢٦٢، وقارن: د. محمد شكرى شرور، ص ١٨٣، حيث يعرف أهلية الحقوق الوجوب بأنه: "صلاحية الشخص لكسب الحقوق أو التحمل بالالتزامات، وهذا التعميم قد يوهم خطأً بين نوعى الأهلية، لأن أهلية الوجوب تثبت للإنسان بمجرد ولادته، بل أنها تثبت للجنين في بطن أمه على الراجح في الفقه، أما التحمل بالالتزامات، فهذا من

ويبدو من هذا التعريف أن هناك نوعين من الأهلية: أهلية الوجوب، وأهلية الأداء.

(أ) أهلية الوجوب:

تتمثل في صلاحية الشخص لأن تثبت له حقوق، ولأن تقرر عليه واجبات، وأهلية الوجوب بحسب الأصل يتساوى فيها جميع الناس، لأنهم جميعاً متساوون في التمتع بالحقوق واستثناء قد تكون هذه الأهلية مقيدة بالنسبة لبعض الحقوق وذلك كالجنين ليست له إلا أهلية وجوب ناقصة، كما أن الأشخاص قد يختلفون في مدى تمتعهم بالحقوق تبعاً لاختلاف حالتهم السياسية والمدنية، وإذا كان الأصل أن الإنسان بمجرد ولادته تثبت له أهلية اكتساب الحقوق، وتحمل الالتزامات، فإنه لا تثبت له أهلية مباشرة التصرفات القانونية التي تؤدي إلى اكتساب الحقوق وتحمل بالالتزامات، لأن هذه الأخيرة تشكل أهلية الأداء^(١).

(ب) أما أهلية الأداء:

فتتمثل في صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه يعتد به، ويبدو من هذا التعريف أن أهلية الأداء قاصرة على الأعمال القانونية، ولا تمتد إلى سائر الوقائع القانونية، لأن القانون هو الذي يرتب الأثر على فعل الشخص سواء كان فعله يكون خطأ يلزمه

شأن أهلية الأداء التي تثبت لمن يعتد بعبارته، وهي لا تصلح لأن تثبت للصغير، إلا إذا كانت على سبيل التحمل الإلزامي في ماله دون إرادة منه، حيث لا إرادة له.

(١) د. عبد المنعم البدرأوى، المرجع السابق.

بالتعويض (مادة ١٦٣ مدني)، أو فعلاً نافعاً يثبت له بمقتضاه الحق في التعويض على من أضر بفعله (مادة ١٧٤ مدني) والقانون هو الذي يرتب الأثر في كلتا الحالتين^(١).

أما العمل القانون، أو التصرف القانوني، فهو اتجاه إرادة الشخص إلى إحداث أثر قانوني معين، فيتحقق هذا الأثر نتيجة لاتجاه الإرادة إليه، هذا لا يخل بصلاحته لتلقى ما يستجد لصاحبه من حقوق والتزامات مالية^(٢).

ولئن كانت الذمة في فقه القانون تتخذ طابعاً مادياً في شكل مجموعة من الأموال تثبت للإنسان أو عليه، فإنها في الفقه الإسلامي تُعد وصفاً يصير به الشخص أهلاً لما له ولما عليه^(٣)، فهي ذات طابع معنوي يتمثل في القابلية لاكتساب الحقوق والتحمل بالتزامات، كما أن نطاق الذمة في الفقه الإسلامي يتسع ليشمل كافة الحقوق والتزامات المالية وغير المالية، كالصلاة والصيام والحج، وديون العباد، وكذلك الالتزامات المالية ذات الصبغة التعبدية كالزكاة وصدقة الفطر، أما نطاق الذمة في القانون فإنه يتحدد بالحقوق بالتزامات المالية ليس إلا^(٤).

(١) د. عبد الودود يحيى، ص ٢٦٣.

(٢) د. عبد الودود يحيى، ص ٢٥٩.

(٣) التوضيح لصدر الشريعة، ج، ص ١٦١، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار، ج٤، ص ٢٤٦.

(٤) راجع: في تفصيل هذا الموضوع: مصادر الحق في الفقه الإسلامي للدكتور السنهاوري، ج١، ص ٢١ وما بعدها، هامش (١).

التنظيم القانوني للأهلية:

قام المشرع المصري بتنظيم القواعد المتعلقة بالأهلية في المواد من (١٠٩ - ١١٩ مدني) لكن تلك المواد لم تنظم كل المسائل المتعلقة بالأهلية، ولذلك عنى المشرع بتقرير الولاية على المال، بالمرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٣م، والذي استكمل به تنظيم جميع المسائل المتعلقة بالأهلية، ويلاحظ أن ما ورد في القانون المدني من نصوص تتعلق بالأهلية قد ركز على تدرج الأهلية بحسب السن، ومدى تأثيرها بحالة الشخص الفعلية، كما تعرض لبعض عوارض الأهلية، أما قانون الولاية على المال، فقد عنى بتنظيم الولاية على معدوم الأهلية أو ناقصها وحدود سلطة الولي في مباشرة التصرفات القانونية نيابة عنهما، ويمكن إرجاع هذه المسائل ودراساتها في أربعة مطالب يخصص أولها: لبيان مراحل تدرج الأهلية بحسب السن، وثانيها: لبيان عوارض الأهلية، وثالثها: لبيان موانع الأهلية، ورابعها: لبيان أثر الأهلية في التصرفات.

الفرع الأول

مراحل تدرج الأهلية

قسم القانون مراحل تدرج الأهلية في حياة الإنسان بدءاً ونموً واكتمالاً في ثلاث مراحل:

الأولى: مرحلة الصبي غير المميز:

وتبدأ هذه المرحلة منذ ولادة الإنسان، وتنتهي ببلوغه سن السابعة وقد تكلفت بيان هذه المرحلة المادة (٤٥ مدني) بقولها:

(١) لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.

(٢) وكل من لم يبلغ السابعة فاقد التمييز.

وبناء على هذا النص، فإن كل من لم يبلغ السابعة يعتبر معدوم الأهلية وفاقداً للتمييز أياً كانت درجة نضوجه العقلي.

الثانية: مرحلة الصبي المميز:

وتبدأ هذه المرحلة من سن السابعة، وتمتد إلى ما قبل بلوغه سن الحادية والعشرين، وفي هذه المرحلة يكون للصبي أهلية أداء ناقصة، وأن لم تتوفر له التمييز كاملة.

وقد نصت المادة (٤٦ مدني) على أن: "كل من بلغ سن التمييز، ولم يبلغ سن الرشد، وكان سفيهاً أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.

الثالثة: مرحلة البلوغ:

وهي تبدأ ببلوغ شخص سن الحادية والعشرين، وهذه السن هي سن الرشد، فإذا بلغ الشخص إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة يكون كامل الأهلية^(١)، حيث إنه في هذه السن يكون قد اكتملت بالنسبة له

(١) نص المادة (٢/٤٣ مدني أردني) على أن سن الرشد ثمانى عشرة سنة شمسية كاملة، وهذه سن معقولة واتجاه القانون بشأنها سديد.

عناصر التمييز كاملة، ومن ثم يصير كامل الأهلية، طالما كان متمتعاً بكامل قواه العقلية، ولم يطرأ عليه ما يستوجب الحجز عليه، وتظل هذه المرحلة قائمة إلى أن تنتهي بما لا بد منه لكل حي، وهو الموت.

الفرع الثاني

عوارض الأهلية

قد يبلغ الإنسان سن الرشد، وتكتمل أهليته، ثم بعد هذا الاكتمال ينتابه عارض يؤثر في تلك الأهلية بالفقد أو بالنقص، وهو ما يقتضي بيانه في فرعين، نخصص لكل حالة من هاتين الحالتين فرعاً منهما:

الفصل الأول

عوارض فقد الأهلية

فقد الأهلية يفترض يفترض اكتمالها لصاحبها، ثم تأتي تلك العوارض فتفقد الشخص أهلية كانت لديه، فالفقد يفترض الثبات من قبل، كما أن السلب يفترض سبق العطاء، والعوارض التي تفقد الأهلية هي الجنون والعتة.

أما الجنون؛ فإنه يعنى اختلال العقل وزواله تماماً، بما يفقد الشخص الإدراك والتمييز كلية^(١).

(١) د. محمد شكرى سرور، ص ١٩١ وما بعدها.

وأما العته؛ فهو نقصان العقل واختلاله، على نحو أقرب إلى الزوال التام الذي يجعل الشخص قليل الفهم مضطرب الكلام مختل العقل، فاسد التدبير^(١).

ورغم أن المعتوه لم يفقد عقله كلية كالمجنون، إلا أن المشرع المصرى قد سوى بينه وبين المجنون في الحكم، وهو فقد الأهلية، حيث يكون المعتوه فاقد الأهلية كالمجنون وذلك لقرب الاختلال فيهما بحيث يصعب معه التفريق بينهما في حكمه، ولأن المختل وإن كان فيه قدر ضئيل من العقل، إلا أن ما ابتلى به من اضطراب كلامه وفساد تدبيره وغباء فهمه قد أذهب أثره، فاستوت الكفتان عندهما، وقد نصت على هذا الحكم المادة (٤٥) مدني بقولها: "لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون".

كما تسوى المادة (١١٤ مدني) حكم تصرفات كل من المجنون والمعتوه بقولها:

(١) يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.

(٢) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر، فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

(١) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٦٣١.

ويبدو من هذا النص أن تصرفات المجنون والمعتوه تختلف في الحكم قبل صدور قرار الحجر عنها بعد صدوره، أما بعد صدور قرار الحجر فإن تصرفهما يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، أيّاً كان التصرف، بل حتى ولو كان من التصرفات النافعة نفعاً محضاً، وذلك دون إخلال بما هو مقرر له من أهلية التي تقتضي صلاحيته لاكتساب الحقوق.

أما قبل صدور قرار الحجر فإن تصرفهما يقع صحيحاً رغم إنعدام التمييز لديهما، فكأن القانون قد اعتبر كلاً منهما كاملة الأهلية لحين صدور قرار الحجر ضماناً لاستقرار التعامل وحماية للغير الذين يتعاملون مع المجنون والمعتوه بحسن نية، كمن لا يعلم بحالة الجنون أو العته، ولم يكن في استطاعته أن يعلم بها ويكون تصرفهما صحيحاً، إذا كانت حالة الجنون والعته شائعة مشهورة وقد التعاقد، أو كان من تعاقد مع المجنون على علم بها، أو كان في إمكانه أن يعلم بها، وذلك لسوء نيته في هذه الحالة، وسوء النية مردود على صاحبه، وهو في هذه الحالة لن يفاجأ إذا أبطل التصرف^(١).

ورغم أن المعتوه لم يفقد عقله كلية كالمجنون، إلا أن المشرع المصرى قد سوى بينه وبين المجنون في الحكم، وهو فقد الأهلية، حيث يكون المعتوه فاقد الأهلية كالمجنون وذلك لقرب الاختلال فيهما بحيث يصعب معه التفريق بينهما في حكمه، ولأن المختل وإن كان فيه قدر ضئيل من العقل، إلا أن ما ابتلى به من اضطراب كلامه وفساد تدبيره وغباء فهمه قد أذهب أثره، فاستوت الكفتان عندهما، وقد

(١) د. أحمد شرف الدين، ص ١١٨.

نصت على هذا الحكم المادة (٤٥) مدني بقولها: "لا يكون أهلاً لمباشرة حقوق المدنية من كان فاقد التمييز في السن أو عته أو جنون".

كما تسوى المادة (١١٤) مدني بين المجنون والمعتوه في الحكم، وهو بطلان تصرفاتهما على نحو مطلق، كما تسوى المادة (٦٥) من قانون الولاية على المال بين المجنون والمعتوه في الحجز عليهما إذا زالت حالة الجنون أو العته.

تصرفات كل من المجنون والمعتوه:

وقد بينت المادة (١١٤) مدني حكم تصرفات كل من المجنون والمعتوه بقولها:

(١) يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.

(٢) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر، فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

ويبدو من هذا النص ان تصرفات المجنون والمعتوه تختلف في الحكم قبل صدور قرار الحجر عنها بعد صدوره، أما بعد صدور قرار الحجر فإن تصرفهما يقع باطلاً مطلقاً، أيّاً كان التصرف، بل حتى ولو كان منالتصرفات النافعة نفعاً محضاً، وذلك دون إخلال بما هو مقرر له من أهلية الوجوب التي تقتضي صلاحيته لاكتساب الحقوق.

أما قبل صدور قرار الحجر فإن تصرفهما يقع صحيحاً رغم إنعدام التمييز لديهما، فكأن القانون قد اعتبر كلاً منهما كامل الأهلية لحين صدور قرار الحجر ضماناً لاستقرار التعامل وحماية للغير الذين يتعاملون مع المجنون والمعتوه بحسن نية، كمن لا يعلم بحالة الجنون أو العته، ولم يكن في استطاعته أن يعلم بها ويكون تصرفهما صحيحاً، إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة مشهورة وقت التعاقد، أو كان من تعاقد مع المجنون على علم بها، أو كان في إمكانه أن علم بها، وذلك لسوء نيته في هذه الحالة، سوء النية مردود على صاحبه، وهو في هذه الحالة لن يفاجأ إذا أبطل التصرف^(١).

الغصن الثاني

عوارض نقص الأهلية

والمراد بهذه العوارض: ما يعنى الأهلية من الأسباب الت تؤدي إلى نقصها، وليس إلى زوالها، ومن عوارض نقص الأهلية السفه والغفلة.

(١) وأما السفه:

فيعرف بأنه تبذير المال وصرفه في غير مقتضى العقل والشرع، فهو من الخفة التي تحمل صاحبها على التصرف بأسلوب غير سوي^(٢)، ولذلك يمكن تعريفه بأنه: خفة تعتري الإنسان فتحمله على التصرف بالمخالفة لمقتضى العقل والشرع، ومن مقتضى مخالفة

(١) د. احمد شرف الدين، ص ١١٨، ود. توفيق فرج، ص ٢٤٦.

(٢) حكم النقض المصري في ١٩٧٤/٣/٢٧م، المجموعة من ٢٥، ص ٥٩٣.

الشرع ان لا يحكم بسفه الإنسان إذا كان يبذر في القربات والطاعات وجوانب الخير والإحسان وهو ما يراه أبو حنيفة.

(٢) وأما الغفلة:

فتمثل في ضعف الإدراك الذي يجعل من يصاب به لا يهتدى إلى النافع من التصرفات، فيغبن في معاملاته^(١)، والسفه والغفلة من العوارض التي تعتري الإنسان فلا تخل بالعقل من الناحية الطبية، وإنما تنقص عند صاحبهما ملكات نفسية أخرى أخصها: الإرادة، وحسن التقدير^(٢).

وفكرة السفه ليست من قبيل المصطلحات المنضبطة المضمون، وإنما هي فكرة معيارية، يرجع في تقدير وجودها إلى التجارب الاجتماعية، وما يتعارف الناس عليه في حياتهم وهي تبني بوجه عام على إساءة التصرف، الذي يستفاد من بعض ظواهر السلوك، كالإدمان على المقامرة، واتباع الهوى، ومكابرة الفعل ولو كان التصرف مشروعاً كالإسراف في التبرعات^(٣)، وذلك على خلاف ما يراه الإمام أبو حنيفة على نحو ما رأينا. وأما الغفلة فيستدل عليها بإقبال الشخص على التصرفات دون أن يهتدى إلى الرابح منها، أو

(١) حكم النقض المصرى في ٢٥/١٠/١٩٧٢م، المجموعة من ٢٢ رقم ١٩١، ص ١٢١٦.

(٢) د. عبد المنعم البدروى، ص ٦٣٣.

(٣) د. عبد المنعم البدروى - ص ٦٣٤.

قبوله فاحش الغبن في تصرفاته عادة، أو بتأثير الخداع على وجه يهدد ماله بخطر الضياع.

فالسفيه يكون عادة متبصراً بعواقب الفساد، ولكنه يعتمد، أما ذو الغفلة فإن الفساد يصدر منه عن سلامة طوية وحسن نية^(١).

تصرفات السفهيه وذوي الغفلة:

وتصرف السفهيه وذوي الغفلة ينشأ ابتداء مشوباً بعيب القابلية للإبطال، ولهذا يجوز للمحكمة أن تحجز على كل من السفهيه وذوي الغفلة، كما يجوز لها أن ترفع الحجر عنهما، وفقاً لما تقضى به المادة (١١٣ مدني)، والمواد (٦٥/١٨، ١/٤٧ من قانون الولاية على المال).

وقد نصت المادة (١١٥ مدني) على أنه:

(١) إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفهيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبي المميز من احكام.

(٢) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر، فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

ومفاد هذا النص أنه يجب التفرقة في الحكم على تصرفات السفهيه وذوي الغفلة بين حالتين، فهي تختلف قبل صدور قرار الحجر

(١) راجع: المذكرة الإيضاحية لقانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ وحكم النقض

المدني في ١٤/٥/١٩٧٥م، المجموعة س١٦، ص١٥٠٢.

عنها بعد صدور هذا القرار^(١)، وقبل تسجيل قرار الحجر يكون تصرف السفه وذوي الغفلة كتصرف الصبي المميز، ومعنى ذلك أن يكون صحيحاً إذا كان نافعاً محضاً، وباطلاً إذا كان ضاراً ضرراً محضاً، وقابلاً للإبطال إذا كان متردداً بين النفع والضرر.

ومع ذلك يصح تصرف السفه وذوي الغفلة بالوقف أو الوصية إذا ادانته المحكمة في ذلك (مادة ١١٢ مدني) والمادة (٥) من قانون الوصية) وذلك رغم أنها من التصرفات الضارة ضرراً محضاً كما تكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسليم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمها القانون (مادة ٦٧ من قانون الولاية على المال).

وغنى عن البيان أن تصرف السفه وذوي الغفلة صحيح قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا تم نتيجة غش وتواطؤ، ولا يكفي هنا أن تكون حالة السفه والغفلة قائمة، أو شائعة، أو يكون المتعاقد على علم بها، ولكن لابد من التواطؤ فيها بين السفه أو ذوي الغفلة ومن صدر له التصرف، وذلك بأن يعتمد الأولان - مثلاً - إلى تبديد مالهما خشية توقيع الحجر عليهما، فيتصرفان لمن تواطأ معهما^(٢)، وهنا يكون بطلان التصرف أو إبطاله

(١) والعبرة بصدور الحكم، وليس بقياماً موجب الحجر، الطعن رقم ١٩٠٩ - ص ٥١ ق - جلسة ١٩٩٢/٢/٢٣ م.

(٢) د. عبد المنعم البدر، ص ٦٣٦.

رداً لقصدهما السيء هذا، إعمالاً للمبدأ الشرعى القاضي بأن يعامل المرء بنقيض قصده السيء.

الفرع الثالث

موانع الأهلية

والموانع جمع مانع، وهو ما يعتري الإنسان فيمنع اكتسابه الأهلية بعد بلوغه السن الذي يكتسبها فيه عادة فيبلغ عديم الأهلية فاقد الرشد، أو يعتريه منها ما يسلب وجودها بعد ثبوتها فيه، كمن يعتريه المانع بعد ثبوتها له.

وموانع الأهلية في القانون ثلاثة: مانع طبيعى، وهو إصابة الشخص بعاهة مزدوجة، أو ضعف جسماني شديد، ومانع مادي وهو الغيبة، ومانع قانوني وهو الحكم بعقوبة، وهذه الموانع قد تعتري الشخص بالرغم من اكتمال أهليته لوجود ظروف تنعنه من مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، ومن ثم يتدخل القانون فيقرر تعيين شخص آخر يتولى عنه إبرام تلك التصرفات ونشير إليه.

أولاً: العاهة والعجز الجسماني:

قد يصيب الإنسان عاهة أو عجز في جسمه يجعلانه في حالة لا يستطيع معها أن يباشر التصرفات القانونية بمفرده ولهذا كان من الواجب أن يعين له مساعد يعاونه في البصيره بحقيقة الأمور، إذا استدعت حالته ذلك^(١).

(١) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٦٣٧.

وقد نصت على تلك المساعدة القضائية المادة (١١٧/١ مدني) بقولها: "إذا كان الشخص اصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة ان تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك".

وقد أضافت المادة (٢/٧٠) من قانون الولاية على المال، إلى هذه الحالة: العجز الجسماني الشديد حيث يجوز للمحكمة أن تعين لمن أصابه ذلك العجز مساعداً قضائياً، والعجز الجسماني، كالشلل النصفى، والضعف الشديد، وضعف السمع والبصر ضعفاً شديداً لا يبلغ مبلغ الصم أو العمى أو ما إلى ذلك^(١).

والمساعد القضائي معاون لمن تقررت له المساعدة فهو ليس بمثابة قضائي، فلا ينفرد دونه بالتصرف، وإلا فإن تصرفه لا ينفذ في حقه، وذلك بخلاف الولى أو الوصى أو القيم، فإنه ينفرد بالتصرف نيابة عن الأصل، ويقوم فيه مقامه^(٢).

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (١١٧ مدني) على أنه: "يكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدرت من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً، بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة".

(١) المذكرة الإيضاحية لقانون الولاية على المال، فقرة ١٠٥.

(٢) د. محمد شكرى سرور، ص ١٩٧.

ومفاد ذلك النص؛ أن التصرف إذا صدر قبل التسجيل، فإنه يكون صحيحاً رعاية لمصلحة الغير حسن النية الذي يتعامل مع الشخص الخاضع للمساعدة القضائية.

ثانياً: الغيبة:

والغائب شخص كامل الأهلية، لكنه رغم اكتمال أهليته لا يقدر على إدارة شؤونه بنفسه، ومن ثم فإنه إن لم يكن قد ترك وكيلاً، فإن المحكمة تقيم كيلاً عنه متى انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه، وإن كان قد ترك وكيلاً بنفسه فإن المحكمة ينبغي عليها أن تحكم بتثبيته متى توافرت الشروط التي يشترط توافرها في الوصى وإلا عينت غيره^(١).

وغنى عن البيان؛ أن الغائب هو من غاب عن بلده سنة فأكثر (مادة ٧٤ من القانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بشأن الولاية على المال، ويختلف عن المفقود في أن الأخير هو الغائب الذي لا يعلم حياته من موته وقد سبق بيان ذلك.

ثالثاً: المحكوم عليه بعقود جنائية:

وفقد الأهلية في تلك الحالة ليس لسبب ذاتي في المحكوم عليه يتعلق بالتمييز، وإنما هي عقوبة تبعية يفرضها القانون على من يحكم عليه بعقوبة جنائية^(٢)، وقد نصت على ذلك المادة (٢٥ عقوبات)

(١) مادة ٧٥ من القانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال.

(٢) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٦٤٤.

بقولها: "كل من حكم عليه بعقوبة جنائية لا يجوز له أن يتولى إدارة أمواله مدة اعتقاله ويعين قائماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته بناء على طلب النيابة العمومية أو أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة هذا الإذن يكون باطلاً بقوة القانون، وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته، أو الإفراج عنه، يقدم له القيم حساباً عن إدارته، والبطلان المقرر جزاء التصرفات المحكوم عليه في أمواله بدون إذن المحكمة، هو بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام (مادة ٢٥ عقوبات) فموافقة المحكمة شرط لانعقاد تصرفات المحكوم عليه^(١).

الفرع الرابع

أثر الأهلية في التصرفات

لبيان أثر الأهلية في التصرفات يجدر لنا أن نذكر بأن التصرفات القانونية التي يمارسها الشخص تنقسم إلى ثلاثة أنواع: تصرفات نافعة محضاً، وتصرفات دائرة بين النفع والضرر.

(١) أما التصرفات النافعة نفعاً محضاً:

فهي التي يترتب عليها إثراء الشخص دون أن يبذل مقابلاً لذلك فهي تدخل في ذمته مالياً دون أن يتحمل أى التزام، وذلك كقبوله الهبة، فإنه تصرف يثرى الموهوب له من ورائه دون مقابل، فيكون هذا

(١) المرجع نفسه.

من التصرفات، حيث تقرر لأصحابها مصالح دون ان يقع على عاتقهم التزام برد ما يقابلها في الوقت الذي تستحق فيه هذه المصالح.

(٢) وأما التصرفات الضارة ضرراً محضاً:

فهي تلك التي يترتب عليها افتقار الشخص دون مقابل لهذا الافتقار، وهذه الحالة عكس الحالة الأولى تماماً، ومن أمثلتها الهبة بالنسبة للواهب، حيث يفقد بتصرفه المال الموهوب دون عائد يثرى ذمته من هذا التصرف، ولهذا كان تصرفه هذا ضاراً ضرراً محضاً.

(٣) التصرفات الدائرة بين النفع والضرر:

وهي تلك التصرفات التي يختلط فيها الإثراء بافتقار، حيث لا يخلص فيها أحدهما، فهي لا تنطوي على افتقار خالص، ولا على إثراء خالص، وذلك كالبيع والإيجار، حيث يترتب كل من هذين العقدين في ذمة أطرافه التزامات متبادلة، بحيث يبذل المال في البيع، أو المنفعة في الإجارة بمقابل، ومن ثم كان من خصائصهما أنهما من العقود التبادلية التي تقابل الحقوق التداولية وفقاً لمنهج هذه الدراسة.

واتجاه الفقه المعاصر يذهب إلى أن هذا النوع من التصرفات ينشطر إلى فرعين هما: أعمال التصرف وأعمال الإدارة^(١).

(أ) أما أعمال التصرف:

(١) راجع في تفصيل ذلك: رسالة دكتوراه من حقوق عين شمس ١٩٨٣م بعنوان: أعمال التصرف وأعمال الإدارة في القانون الخاص، للدكتور محمد السعيد رشدى، ص ١٩١ وما بعدها، دار النهضة العربية.

فهي التي يترتب عليها تغيير المركز المالي للشخص بصفة نهائية أو إلزامه بالنسبة للمستقبل، بما من شأنه أن يغير في مقدار العناصر المكونة للذمة المالية ومثل هذه الأعمال أعمال على درجة كبيرة من الأهمية والتأثير على حياة الأفراد ومراكزهم الحقوقية، ومن ثم يطلب الشرع لها أهلية كاملة تعرف بأهلية التصرف المقابلة لأهلية الإدارة^(١).

(ب) وأما أعمال الإدارة:

فهي تلك التي يقصد من ورائها استثمار العناصر المادية المكونة للذمة المالية استغلالاً عادياً، دون أن يترتب عليها التزام في المستقبل، ودون تعديل أو تغيير في العناصر المكونة للذمة، فهي في الأصل لا يترتب عليها خروج حق من ذمة المتصرف أو إنشاء حق عيني على شيء مملوك له، وإنما يقصد منها المحافظة على حقوق الشخص واستثمارها، كالحصول على غلة الشيء مع بقاءه في ذمته. هذه هي أنواع التصرفات المختلفة، ولنا أن نتساءل عن مدى صلاحية أى نوع من أنواع الأهلية لممارسة هذه الأنواع من التصرفات، لا سيما وإنها تتدرج في قوتها من حيث القدرة على ممارسة التصرف بدءاً من الولادة وحتى وصول الإنسان إلى سن البلوغ الكامل للأهلية القانونية وهو إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

(١) د. محمد السعيد رشدي، نظرية الحق، ص ١١٣ ومابعدھا.

إن الإجابة عن هذا التساؤل لن تكون صحيحة إلا إذا استبان قدرة كل مرحلة من مراحل الأهلية على ممارسة كل تلك التصرفات أو بعضها وذلك كما يلي:

أولاً: تصرفات الصبي غير المميز:

ومعلوم أن الصبي غير المميز هو الذي يبلغ السابعة، ومن ثم تنعدم لديه أهلية الأداء فلا يقدر على ممارسة أى نوع من أنواع تلك التصرفات، سواء منها ما كان نافعاً أم ضاراً أم دائراً بين النفع والضرر، وقد نصت المادة (١١٠ مدني) على أنه: "ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة".

بيد أنه إذا كانت الأهلية معدومة في حقه، فإن له ذمة تثبت له كإنسان، وبمقتضاها يمكن أن يكتسب الحقوق التي لا تستلزم تصرفاً من قبله.

ثانياً: تصرفات الصبي المميز:

وهو الذي بلغ السابعة من عمره، ولم يصل بعد إلى سن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، وتصرفات هذا الصبي قد تولت بتنظيمها المادة (١١١ مدني) بقولها:

- (١) إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.
- (٢) أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالإبطال، إذا جاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون.

ويبدو من هذا النص:

أنه يفرق في تصرفات الصبي المميز بين التصرفات النافعة، وهي صحيحة في حقه، والتصرفات الضارة، وهذه تتشأ باطلة، وأما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فتكون صحيحة منتجة لآثارها إلى أن يتقرر مصيرها أما بالإجازة أو بالإبطال، والإجازة تصدر من الصبي بعد بلوغه سن الرشد، أو من وليه إذا كان التصرف محضاً ضد الإبطال، وإذا بطل اعتبر كأن لم يكن، ويبطل الحق في التمسك بالإبطال بمضى ثلاث سنوات من يوم اكتمال الأهلية (١).

واستثناء من الأحكام السابقة:

يكون القاصر كامل الأهلية في حالتين:

الأولى: الصبي المأذون له بالإدارة:

إذا بلغ الصبي ثمانى عشرة سنة جاز له بعد إذن الولي أو المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، وقد أقر المشرع المصري للصبي الذي بلغ هذه السنة أهلية خاصة تؤهله لإدارة أمواله بعد بلوغ سن الرشد، لعله قد استمد هذا الحكم من التشريع الإسلامي، عملاً بقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (٢).

وقد نصت المادة (١١٢ مدني) على أنه: "إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشر من عمره، وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها

(١) ويجوز للورثة أن يتمسكوا بحق الإبطال بعد موت المتصرف، راجع: حكم النقض المدني

في ١٩٦٨/٢/٢٧ م المجموعة س ١٦، ص ١٦١.

(٢) سورة النساء - من الآية ٦.

أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون".

ويكون هذا الإذن من الولي بإشهار لدى الموثق وله أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهار آخر (مادة ٥٤ من قانون الولاية على المال) وذلك مع مراعاة حكم المادة (١٢٠٧ مرافعات)^(١)، كما يجوز منه هذا الإذن من المحكمة بعد سماع أقوال الموصي، وإذا رفضت الإذن فلا يجوز تجديده قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي.

وقد قضت المادة (٥٦ من قانون الولاية على المال) بأنه: "للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفي ويستوفي من الديون المترتبة على هذه الأعمال، ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأراضي الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة، ولا يفي الديون الأخرى، ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذي آخر إلا بإذن خاص من المحكمة، أو من الوصي فيما يملكه من ذلك، ولا يجوز للقاصر أن يتصرف في صافي دخله إلا بالقدر اللازم لسداد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانوناً".

نطاق الإذن بالإدارة:

ومفاد نص المادة (٥٦ المشار إليه) والمواد (٥٧، ٥٨ من قانون الولاية على المال) أنه لا يجوز للقاصر تأجير الأراضي الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة إلا بإذن خاص من المحكمة أو

(١) والتي تقضى بأن يشهر التصرف في سجل معد لذلك ضماناً لاستقرار المعاملات.

من الولي أو الوصي، وفي الحالات التي يحدد القانون للإيجار فيها مدة أكثر من سنة لا يجوز للقاصر ان يمارس حق التأجير في هذه الحالات، وكذلك أمر فيما يتعلق بقاعدة الامتداد القانوني لإيجار الأماكن حيث لا يجوز للقاصر أن يؤجر في تلك الحالة، فإذا أجبر يكون تصرفه باطلاً، ولا يستفيد به المستأجر ولا من يمتد إليه الإيجار من أقاربه.

ولا يجوز للقاصر المأذون له بالتصرف في صافي دخله إلا في حدود ما يلزم لنفقاته من تلزمه نفقتهم قانوناً ولا يجوز له أن يوفى الديون الأخرى، غير تلك التي تنشأ عن إدارة أمواله، حتى ولو كانت هذه الديون ثابتة بحكم واجب النفاذ إلا بإذن خاص من المحكمة، أو من الوصي في حدود اختصاصه، وفي غير ذكن يكون للقاصر المأذون له في إدارة أمواله أهلية مباشرة جميع أعمال الإدارة بالنسبة للأموال التي أذن له في تسليمها، في الحدود المشار إليها^(١).

الثانية: القاصر المأذون له في التجارة:

لما كانت التجارة تتطوى على مخاطر مالية ربما لا يقدر الصبي على إدراك مداها، وتستتبع مع خطورتها مسؤوليات جسيمة قد تؤدي بالصبي إلى الإفلاس الذي يحدث هزات متوالية بين أصحاب الديون

(١) د. محمد على عمران: الوجيز في شرح عقد البيع والتأمين، ج١، ص٣٨، دار النهضة العربية.

الذين ينتظرون وفاء غيرهم ليسددوا ما عليهم، والإفلاس يهز كل تلك المتواليات المترابطة، ومن ثم لا يكفي فيها الإذن بالإدارة فنصت المادة (٥٧ من قانون الولاية على المال) على أنه: "لا يجوز للقاصر سواء أكان مشمولاً بالولاية أم بالوصاية أن يتاجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنته المحكمة في ذلك إذناً مطلقاً أو مقيداً".

ويدل هذا النص على: أن الإذن بالتجارة قد يكون مطلقاً وقد يكون مقيداً، وفي حال الإطلاق يكون المأذون له أهلاً للقيام بجميع أنواع التجارة دون تقييد، وفي الحالة الثانية يكون مقيداً بنوع معين من التجارة، ومتى أذن للقاصر بالتجارة، فإنه يكون أهلاً لمباشرة العمال التجارية التي أذن له بمباشرتها وما يلزم لمباشرة تجارته من بيع وشراء، وقرض واقتراض، وذلك خروجاً على الأصل العام الذي يجعل التصرفات الدائرة بين النفع والضرر على الصبي المميز غير جائزة، كما أن له أن يقاضى ويتقاضى ويصالح ويحتكم، ويسرى التقادم في مواجهته، ويحرم من قواعد الغبن المقررة في بيع عقار ناقص الأهلية، كما يمكن أن يكتسب صفة التاجر، إذا احترف الأعمال التجارية، ويمكن بالتالي شهر إفلاسه^(١).

ثالثاً: تصرفات البالغ الرشيد:

(١) راجع في تفصيل ذلك: الولاية على المال للأستاذ حمد كمال، ص ١٦٠ وما بعدها، دار المعارف سنة ١٩٦٦م.

وإذا بلغ الشخص سن الرشد وهي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة، صار كامل الأهلية، وبمقتضى ذلك يكون له ممارسة جميع أنواع التصرفات، وتقع منه صحيحة، سواء أكانت نافعة نفعاً محضاً، أو ضارة ضرراً محضاً، أم دائرة النفع والضرر ومن ثم تقع هيئته ووصيته ووقفه صحيحاً، ولكن الوصية يجب أن تتقيد بحدود الثلث. ويشترط لثبوت الأهلية الكاملة ببلوغ هذه السن أن يكون الشخص متمتعاً بكامل قواه العقلية ولم يحجر عليه لسبب ن أسباب الحجر (مادة ٤٤ مدني).

وقد نصت المادة (١٨ من قانون الولاية على المال): "على أن الولاية تنتهي ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ميلادية ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية فمتى بلغ الصغير هذه السن رشيداً زالت عنه الولاية بحكم القانون، أما إذا أنس الولي في الصغير عارضاً من العوارض التي تحول دون كمال الأهلية عند بلوغ السن المقررة في القانون وأنه سيبلغ غير رشيد، فله أن يطلب لاستمرارها إلى ما بعد هذه السن، وللمحكمة أن تقضى بذلك إذا استوثقت من قيام العارض أو شاطرت الولي رأيه في عدم إيناس الرشد^(١).

(١) د. عبد المنعم البدرأوى: مبادئ القانون، ص ٣٩٦، مكتبة وهبة ١٩٧٢م.

المبحث الثانى

الشخص الافتراضي أو المعنوي

لا يقتصر وجود الشخصية القانونية على الإنسان وحده إذ أنه ليس - من هذا المفهوم - هو الكائن الاجتماعي الوحيد في المجتمع، حيث يوجد إلى جانيه كائنات اجتماعية تكتسب الشخصية القانونية على سبيل الافتراض، وتسمى بالشخص المعنوي أو الاعتباري، وهذا الشخص المعنوي يحقق أغراضاً وأعمالاً كثيراً ما يفوق تحقيقها واستمرارها قدرة وحياة الشخص الطبيعي، وقد اعترف القانون لتلك الكائنات بالشخصية القانونية حيث توجد نتيجة تكتل بعض الأشخاص أو رصد بعض الأموال لتحقيق غرض معين يكتسب كياناً مستقلاً، عن كيان الأشخاص الذين يسهمون في نشاطه، أو الذين ينتفعون من هذا النشاط، فالدولة مثلاً تعتبر شخصاً قانونياً متميزاً ومستقلاً عن شخصيات المكونين لها أو الذين ينضمون لها أو ينتفعون من نشاطها، وقل مثل ذلك في المؤسسات والشركات، وغيرها^(١).

فالسبب الذي دعا المشرع لإضفاء الشخصية القانونية للشخص الاعتباري، إحساسه بضعف الإنسان وقلة موارده، وقصر عمره عن تحقيق الأعمال المرتجاة من الشخص الطبيعي والتي تتطلب مالاً وفيراً، وجهداً كبيراً ووقتاً طويلاً، ومن ثم يجد الإنسان نفسه مضطراً لضم نشاطه إلى نشاط غيره من آحاد الناس، ليتكون من مجموع تلك

(١) د. منصور مصطفى منصور: نظرية الحق ١٩٦٢، ص ٢٠٦.

الأنشطة، قوة لا يتطرق إليها الفناء بسرعة، وتقدر على القيام بأعباء ثقال من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية^(١)، وغيرهما.

مفهوم الشخص المعنوي:

وبناء على ذلك: يمكن تعريف الشخص الاعتباري أو المعنوي بأنه: "مجموعة من الأشخاص أو الأموال تنشأ لتحقيق غرض معين، ويمنحها القانون الشخصية القانونية التي تمكنها من تحقيق أغراضها"^(٢).

ومن هذا التعريف يتبين لنا أن خصائص الشخص الاعتباري تتمثل فيما يلي:

(١) أن الشخص الاعتباري عبارة عن مجموعة من الأشخاص أو الأموال، قد تتكون جماعة التحقيق غرض معين، ويعترف لها القانون بالشخصية، وتكون له شخصية مستقلة عن شخصية المكونين لها، وقد تخصص مجموعة من الأموال لغرض معين من أغراض البر، أو المنفعة العامة، كالمستشفيات والملاجئ والمعاهد العلمية، وغيرها من المؤسسات.

(٢) كما أن الشخص الاعتباري يقوم لتحقيق غرض معين مستقل عن الأهداف الخاصة للأشخاص المكونين له، وباختلاف هذا الهدف تختلف أنواع الشخص المعنوي، فإذا كان هدف الشخص المعنوي

(١) د. محمد لبيب شنب، المرجع السابق، د. أنور سلطان، المرجع السابق.

(٢) د. منصور مصطفى منصور، ض ٢٠٧.

عاماً، كان من أشخاص القانون العام وإن كان خاصاً، كان من أشخاص القانون الخاص.

(٣) أن الشخص الاعتباري لا يمنح من الشخصية القانونية إلا بقدر ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ثم يجب أن يتحدد نشاطه القانوني بالحدود التي أنشئ من أجلها، فلا يجوز لمستشفى أن تؤجر بعض غرفها كفندق، ولا يجوز لجمعية أن تدخل في مضاربات مالية^(١).

خطة الدراسة:

ودراسة جوانب حياة الشخص الاعتباري تقتضي إلقاء الضوء على وجوده بداءً ونهايةً، وسوف نبين ذلك في مبحث أول، كما يقتضي بيان هويته اسماً وحالة وموطناً، وسوف نبين ذلك في مبحث ثان، أما المبحث الثالث فنخصصه لأهلية الشخص المعنوي ثم نبين في نهاية هذا الموضوع أنواعه.

(١) د. جلال العدوي، ص ١٧٢، وراجع: د. عبد الناصر العطار، ص ٢٦٤.

المطلب الأول

وجود الشخص المعنوي

وجود الشخص المعنوي يتوقف على الاعتراف له بالشخصية القانونية، وهذا الاعتراف يمثل بالنسبة للشخص المعنوي شهادة الميلاد، ويظل قائماً حتى يتوافر سبب من الأسباب المؤدية إلى انقضائه، أو حتى تتم تصفيته.

أولاً: بدء الشخصية الاعتبارية باعتراف القانون:

لا تثبت الشخصية الاعتبارية لجماعة أو هيئة معينة إلا بموافقة القانون، فأى جماعة لا يوافق القانون على تمتعها بالشخصية الاعتبارية لا يمكن أن تتوافر لها هذا الشخصية بحال من الأحوال، وموافقة القانون على وجود الشخص الاعتباري قد تكون على هيئة اعتراف عام أو على هيئة اعراف خاص من خلال صدور قرار خاص بوجوده.

(أ) الاعتراف العام:

ويراد بالاعتراف العام، الاعتراف بالشخصية المعنوية لكل من تتوافر فيه شروط معينة، ينص عليها القانون، وبمجرد توافر هذه الشروط تثبت الشخصية المعنوية، بقوة القانون، وذلك كما هو شأن القانون المصري بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الخاصة والشركات فيما عدا الشركة المساهمة^(١).

(١) د. جلال العدوى، ص ١٧٣، وقد نصت المادة (٥٠٦ مدني) على اعتبار الشركة بمجرد تكوينها شخصياً اعتبارياً، كما نصت المادة (٥٢ مدني) على اعتبار الدولة والمدن والقرى والهيئات والطوائف الدينية والأوقاف، والشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات أشخاصاً اعتبارية.

وتختلف الشروط التي يتطلبها القانون للاعتراف بالشخص المعنوي باختلاف نوعه، وخاص فيما يتعلق بشهر نظام الشخص المعنوي، حيث يعتبر بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الخاصة شرط وجوده، بينما هو بالنسبة للشركات الخاصة شرط للاحتجاج بالشخصية المعنوية قبل الغير.

(ب) الاعتراف الخاص:

والاعتراف الخاص، يتوقف على صدور قرار خاص بإنشاء شخص معنوي بالذات، وذلك كما هو الشأن بالنسبة لشركات المساهمة والهيئات والمؤسسات العامة، حيث يتوقف انشاؤها على قرار من رئيس الجمهورية، وبمجرد إنشائها تكتسب الشخصية المعنوية حيث لا يلزم أن ينص قرار إنشائها على ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة لإنشاء شركات المساهمة الخاصة، حيث يتوقف على صدور قرار من السلطة الإدارية، وقد نصت المادة (٥٢/٦ مدني) على أن: "كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية يفتضى نص في القانون"^(١).

(١) وقد قضت محكمة النقض الدنى بتاريخ ١٩٧٨/٣/٢٩م في الطعن رقم ٦٢٨ لسنة ٤٤٤ق بأن ما تقيده المادتان (٥٣/٥٢ مدني) من أن مناط ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية، إنما هو باعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها، بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص لقيام الشخصية المعنوية كل هيئة أو طائفة دينية، وهو اعتراف مباشر وخاص.

ثانياً: انتهاء الشخصية الاعتبارية:

والشخص المعنوي ينقضى بأسباب متعددة، فهو ينقضى بإنقضاء الأجل المحدد له إذا وجد هذا التحديد في سند إنشائه، وقد ينقضى إذا تحقق الغرض من إنشائه وانتهى أو إذا ثبت استحالة تنفيذ هذا الغرض، كما قد ينقضى الشخص المعنوي بالحل، وهذا الحل قد يكون اختيارياً يتم بإرادة المكونين له واتفاقهم، كالاتفاق على حل الجمعية أو الشركة، وقد يكون إجبارياً أى بقرار من الإدارة أو بحكم قضائي.

ومتى انتهت شخصية الشخص المعنوي، صفيت ذمته، أى سدد ديونه من أمواله ووزع المتبقى من المال، وفقاً لما هو مقرر في سند إنشائه، إلا أن ينص القانون على قواعد معينة في هذا الخصوص^(١).

المطلب الثاني

هوية الشخص المعنوي

وتحدد هوية الشخص المعنوي من خلال تمييز ذاته باسم يتخذه، وحالته وموطنه، ونبين هذه الأمور الثلاثة:

أولاً: اسم الشخص المعنوي:

(١) ومثال ذلك ما تقضى به المادة (٤٥ من القانون المشار إليه)، راجع: د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٤٢٨.

لكل شخص معنوى اسم يتميز له عن غيره من سائر الأشخاص الاعتبارية التى قد تختلط به، ويجب أن يختار المؤسسون الاسم عند إنشاء الشخص المعنوي أو ينص عليه في السند المنشئ، وقد يكون اسم الشخص الاعتباري اسماً تجارياً، وفي هذه الحالة يجوز التصرف فيه باعتباره أحد عناصر المحل التجاري.

وتشمل حماية القانون اسم الشخص الاعتباري، فلا يجوز الاتداء عليه، وإذا وقع عليه هذا الاعتداء، يكون له الحق في التعويض عن الضرر الذي يصيبه^(١).

ثانياً: موطن الشخص الاعتباري:

لكل شخص اعتبارى موطن مستقل ومتميز عن موطن كل عضو من أعضائه، وقد نصت المادة (٥٣ مدني) على أنه: "للشخص الاعتباري موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته"، غير أنه إذا كان للشخص الاعتباري عدة فروع، فإن موطنه يعتبر هو المكان الذي يوجد فيه الفرع، فيما يتصل بالأعمال المتعلقة بهذا الفرع^(٢)، وقد نصت المادة (٥٢ مدني) على أن: "الشركات التى يكون مركزها الرئيسى في الخارج، ولها نشاط في مصر يعتبر مركز

(١) د. جلال العدوى، ص ١٧٦ وما بعدها.

(٢) د. شمس الدين الوكيل، ص ١١٥.

إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية^(١).

ثالثاً: حالة الشخص الاعتباري:

من المعلوم - بداهة - أن حالة الشخص تتحدد بالعلاقة التي تربطه بأفراد الأسرة، والمركز الذي يشغله فيها (الحالة المدنية أو العائلية)، وبالمركز الذي يشغله في الدولة (الحالة السياسية). ومن الطبيعي ألا يكون للشخص المعنوي حالة مدنية لاستحالة ان تكون له أسرة، ومن ثم تقتصر الحالة على الحالة السياسية. فللشخص الاعتباري جنسية تربطه بدولة ما، وله بمقتضى تلك الرابطة جنسية، ومن المهم معرفة جنسية الشخص المعنوي لتحديد القانون الذي يحكمه، وتستند الدول عادة في فرض جنسيتها على الأشخاص الاعتبارية إلى عنصر التأسيس فتثبت للشخص المعنوي جنسية البلد الذي تأسس فيه وطبقاً لقانونه^(٢).

وقد نص القانون المصري على أن النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يبرى عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلى (مادة ٢/١١ مدني)، وتضيف تلك المادة: ولكن إذا كانت هذه الأشخاص يتركز نشاطها الرئيس في مصر، فإن

(١) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٤٣٠ وما بعدها.

(٢) هو ما يقابل عنصر الميلاد على إقليم الدولة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

القانون المصري هو الذي يحكمها رغم وجود مركز إدرتها في الخارج^(١).

المطلب الثالث

أهلية الشخص المعنوي وأنواعه

وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نبين في أولهما: أحكام الأهلية المتعلقة بالشخص المعنوي، وفي ثانيهما: أنواعه.

الفرع الأول

أهلية الشخص المعنوي

من المعروف أن مناط أهلية الأداء يتمثل في الإرادة والتمييز والشخص المعنوي لا يتوافر لديه هذا التمييز بحكم كونه خلفاً افتراضياً، ومن ثم يتصور أن يباشر التصرفات القانونية إلا بواسطة من يمثلونه من أشخاص طبيعيين يقومون بالنيابة عنه ولحسابه بكل هذه التصرفات^(٢)، وقد يكون هذا النائب شخصاً واحداً كالمدير العام، أو مجموعة من الأشخاص كمجلس الإدارة، أو مجلس الأمناء.

والأشخاص الطبيعيون الذين يعملون باسم الشخص المعنوي لا مثل علاقاتهم به صلة نيابة تقليدية بالمفهوم الفقهي المعروف وإن كان مركزهم لا يمنع من اعتبارهم نواباً قانونيين للشخص الاعتباري^(٣)،

(١) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٤٣١.

(٢) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٤٣٢.

(٣) د. جلال العدوى، السابق، ص ١٨٠.

لأنهم أعضائه الذي يعمل بواسطتهم، فإن إرادتهم هي إرادة الشخص المعنوي، ولهذا يسمون: أعضاء الشخص المعنوي.

وصفة العضو التي تثبت لممثل الشخص المعنوي، لا تنشأ من عمل قانوني، كالوكالة أو الولاية، وإنما تثبت من ببيان الشخص المعنوي نفسه، فالعضو ليس شيئاً منفصلاً عن الشخص الاعتباري، بل هو جزء منه يستخدمونه في مباشرة الأعمال القانونية والأعمال المادية، التي تتفق مع تخصيصه، والداخلية في حدود ما يتمتع به من شخصية.

ويختلف العضو عن العمال والموظفين، في أن الأول يعتبر جزءاً متمماً للشخص المعنوي، وأما العمال والموظفون، فإنهم يؤدون الأعمال التي يكلفون بها من العضو لحساب الشخص المعنوي، وما يصدر من العضو يلزم الشخص المعنوي بالضرورة، أما التابع من العمال والموظفين، فلا يستطيع إلزام الشركة بتصرفه إلا إذا كان قد فوض من قبيل الشخص المعنوي أو أحد أعضائه، وإذا صدر خطأ من أعضاء الشخص المعنوي يصيب الغير بضرر، كان الشخص المعنوي هو المسئول عنه بصفة شخصية مباشرة لأن الفعل صدر منه هو^(١).

المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري:

(١) راجع في هذا المعنى: حكم النقض المدني بتاريخ ١١/٣/١٩٤٨م، مجموعة عمر، ج٥، ص ٥٦٥.

يرى معظم الشراح أن الشخص الاعتباري لا يسأل جنائياً عما يقع من ممثليه أثناء قيامهم بعملهم لحسابه، لأن المسؤولية الجنائية تستلزم الإرادة لدى المسئول والشخص الاعتباري لا إرادة له، فيرتد أثر الفعل المجرم إلى أعضائه، خاصة وأن من العقوبات ما لا يمكن توقيعه على الشخص الاعتباري كالحبس والسجن مثلاً^(١).

ومع ذلك فهناك رأى يبالغ في وجود الشخص المعنوي ويعتبره وجوداً حقيقياً، يتميز به عن وجود المكونين له، ومن ثم فإنه لا مانع عندهم من القول بمساءلته جنائياً، ويتحدد العقاب بما يلائمه من العقوبات المناسبة كالغرامة، ويمكن إنشاء عقوبات خاصة به كالحل والرحمان من المزايا أو بعض الحقوق.

وهذا الخلاف الفقهي لا يمكن أن يؤثر في القانون الوضعي فمن المقرر أن المسؤولية في القانون الجنائي لا تقوم إلا بنص ومن ثم يجب الاقتصار في مساءلة الشخص الاعتباري على الحالات الخاصة التي ورد فيها نص، ويسأل عن الجريمة من يرتكبها من عماله وممثليه، وإن كان من الجائز أن تمتد الآثار المالية للعقوبة إلى الشخص المعنوي على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، كالحكم بهدم بناء خارج عن خط التنظيم أو إغلاق محل، أو المصادرة^(٢).

ذمة الشخص المعنوي:

(١) د. السعيد مصطفى السعيد: شرح قانون العقوبات (القسم العام)، ص ٣٤٨ وما بعدها.

(٢) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٤٣٥.

وطالما تثبت الشخصية القانونية للشخص الاعتباري، فإن ذلك يستتبع بالضرورة أن تكون له ذمة مالية، وهي تتمثل في مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات في الحاضر والمستقبل مما له قيمة مالية، وإذا ثبت للشخص المعنوي ذمة مالية بمجرد اكتسابه للشخصية القانونية.

وهذه الذمة المالية منفصلة ومتميزة عن ذمة الأفراد المكونين للشخص الاعتباري، ومن ثم فلا يكون لدائني هؤلاء الأفراج حق الرجوع على أموال الشخص الاعتباري، ولا يكون لدائني الشخص الاعتباري - كقاعدة عامة - الرجوع على أموال الأفراد المكونين له، وتلك ميزة كبرى، لأن ذلك الانفصال بين ذمة الشخص المعنوي وذمة أعضائه، من شأنه أن يهيئ له الاستقلال اللازم للسير في سبيل تحقيق ما أنشئ من أجله، ولهذا جاز مقاضاة الشخص المعنوي، كما جاز له أن يقاضى من يعتدون عليه، دون حاجة إلى مقاضاة كل عضو من أعضائه (مادة ٥٣/٣ج).

الفرع الثاني

أنواع الشخص المعنوي

أورد القانون المدني المصري في المادة (٢٥) تعداداً للأشخاص الاعتبارية، وحصرها في:
(١) الدولة وكذلك المديريات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

(٢) الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

(٣) الأوقاف.

(٤) الشركات التجارية والمدنية.

(٥) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون التى ستأتى فيما بعد.

(٦) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

ويبدو من هذا النص أنه يشمل: الأشخاص الاعتبارية العامة، والأشخاص الاعتبارية الخاصة، والأشخاص الاعتبارية العامة التى وردت في النص هي:

(١) الدولة والمحافظات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون.

(٢) الإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى منحها

القانون شخصية اعتبارية، وهذه الأشخاص تخضع في تنظيمها

وبيان أغراضها لقواعد القانون العام بفرعيه الدستورى والإدارى.

ويلحق بهذه المجموعة الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف

لها الدولة بشخصية اعتبارية، فهذه تعتبر أيضاً من أشخاص القانون العام^(١).

الأشخاص المعنوية في القانون الخاص:

(١) د. عبد الودود يحيى، ص ٢٩٣ وما بعدها.

وإذا استبعدنا من نطاق المادة (٥٢ مدني) الأشخاص الاعتبارية التي تدخل في نطاق القانون العام يتبين لنا أن الأشخاص الاعتبارية التي تدخل في نطاق القانون الخاص هي: الأوقاف والشركات المدنية والتجارية، والجمعيات والمؤسسات. وقد جرى الفقه عادة إلى تقسيمها إلى جماعات الأشخاص وتتكون من الشركات والجمعيات، ومجموعات الأموال، وتشمل المؤسسات والأوقاف.

الفصل الأول

جماعات الأشخاص

وجماعات الأشخاص تشمل ما رأينا الشركات والجمعيات.

أولاً: الشركات:

الشركات جمع شركة، وهي اتفاق يلتزم بموجبه شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع مالى عن طريق تقديم حصة من مال أو عمل، وذلك بقصد اقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، وعقد الشركة يجب أن يكون مكتوباً وهذا العقد يترتب عليه في الغالب من الحالات نشوء شخص معنوى هو شخص الشركة إلى جانب الأشخاص المكونين لها.

ويبدو من هذا التعريف أن للشركة ثلاثة عناصر:

أولها: ان يوجد شخصان فأكثر، ومع ذلك فإن القانون قد يستلزم بالنسبة لبعض الشركات حداً أدنى لا يقل عنه عدد الشركاء، كما هو

الشأن بالنسبة لشركات المساهمة في مصر، حيث يلزم ألا يقل عدد المؤسسين فيها عن سبعة^(١).

ثانيها: أن يتعهد كل شريك بتقديم نصيب يسمى حصة لتكوين الشركة، وهذه الحصص قد تكون مبلغاً من النقود أو حصصاً عينيه، عقارات كانت أو منقولات، وقد تكون مجرد عمل يقدمه الشريك، ويتكون رأس مال الشركة من احصص النقدية والعينية فقط.

ثالثها: أن يكون الغرض من إنشاء الشركة هو تحقيق الأرباح، وهذا ما يميز الشركة عن الجمعية، كما يجب أن يساهم الشركاء جميعاً في الرباح والخسائر.

الشخصية المعنوية للشركة:

والشركة تعتبر شخصاً معنوياً مستقلاً عن الأشخاص المكونين لها، وتثبت الشخصية المعنوية للشركات جميعاً، سواء كانت شركات مدنية أم تجارية، عدا شركات الأشخاص التي لا تقتصر مسؤولية المكونين لها على ديون الشركة، وإنما يتعدى إلى ذمم الأفراد، وذلك مثل شركة التضامن، وشركة التوصية حيث يكون الشركاء فيها مسؤولين عن التزامات الشركة مسؤولية غير محددة برأسمال الشركة، وإنما تتعدى إلى سائر أموالهم الخاصة، وبالتالي فليس هناك فصل

(١) د. عبد الودود يحيى، ص ٢٩٤.

بين ذمة الشركة، وذمة الشركاء^(١)، وذلك مثل شركة المحاصة التي تتميز بأنها شركة خفية مستترة، ليس لها وجود ظاهر بالنسبة إلى الغير، ووجودها مقتصر على الشركاء فيها، وقد نصت المادة (٦٠ تجاري) على أن الشركات المحاصة تختص بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية، ومن المقرر فقهاً وقضاً أن ذلك ليس هو الوصف المميز لها، وإنما ميزها عن غيرها من الشركات كونها شركة مستترة لا عناوين لها، ولا وجود لها أمام الغير، والعمال التي يقوم بها أحد الشركاء فيها تكون باسمه خاصة، ويكون وحده المسئول عنها في مواجهة من تعامل معه، حيث كانت تسمى بالشركة المجهولة، لهذا لم يذكرها المشرع ضمن الشركات التجارية في المادة (١٩ تجاري) التي عدت أنواع الشركات^(٢).

أنواع الشركات:

والشركات نوعان: شركات تجارية، وشركات مدنية.

(١) راجع: د. عبد المنعم البداروي، ص ٧٠٩.

(١) راجع في تفصيل هذا الموضوع: استاذنا الدكتور: ثروت عبد الرحيم، المرجع السابق،

ص ٣٧٩ هامش (١)، (٢) والمراجع والأحكام القضائية المشار إليها فيه.

والشركات المدنية هي التي لا تقوم بأعمال تجارية، وذلك مثل الشركات التي تقوم بشراء الأراضي وبيعها بعد تقسيمها وإصلاحها حيث لا يعتبر القانون المضاربة على العقارات أعمالاً تجارية^(١).

أما الشركات التجارية، فهي التي تقوم بأعمال تجارية كعمليات الشراء لأجل البيع أو عمليات البنوك، أو النقل أو الصناعة وتتخذ الشركات أشكالاً متعددة، وهي تنقسم بصفة عامة بحسب الرابطة التي تربط بين الشركاء إلى قسمين رئيسيين: شركات أشخاص وشركات أموال، وشركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي المتمثل في الثقة المتبادلة بين الشركاء وهذه تنقسم إلى شركة تضامن، وشركة توصية بسيطة، أما شركات الأموال فهي تقوم على الاعتبار المالي، أي مجموع أموال على هيئة حصص لا يكون أشخاص الشركاء فيها محل اعتبار مثل شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم^(٢).

ويأخذ حكم الشركات في استحقاق الشخصية المعنوية والمشروعات العامة التي تقوم بها الدولة، وتتخذ شكل مؤسسات عامة تجارية، أو شكل شركات مساهمة عامة تمتلك الدولة جميع أسهمها، كما أن الدولة قد تشترك في رؤوس الأموال الخاصة وذلك في حالة ما يسمى بشركات الاقتصاد المختلط^(٣).

ثانياً: الجمعيات

(١) د. توفيق فرج ومحمد يحيى مطر، ص ٣١٣.

(٢) د. منصور مصطفى منصور، ص ٢٢٣ وما بعدها.

(٣) د. توفيق فرج ومحمد يحيى مطر، ص ٣١٣ وما بعدها.

ومفهوم الجمعية يطلق على كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، وهذه تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، أو أى منهما معاً لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، ولغرض غير الحصول على ربح مادي^(١).

ومن خلال هذا التعريف يبدو أن للجمعيات خصائص هي:
أولاً: أنها تتكون من جماعة من الأشخاص.

ثانياً: أنها ذات تنظيم مستمر، ولا يلزم أن يكون مؤبداً، فقد يكون لمدة معينة، كما قد يكون لمدة غير معينة.

ثالثاً: يجب أن يكون للجمعية غرض، ويتحدد هذا الغرض بعدم الحصول على ربح مادي، وأن يكون مشروعاً ولا يهتم بعد مشروعية عرض الشركة، أن تكون جمعية خيرية أو علمية أو ثقافية أو اجتماعية أو رياضية، كالنوادى المختلفة، أو مهنية للدفاع عن مصالح أبناء المهنة الواحدة مثل نقابة العمال، ونقابة المحاماه، ونقابة المهن الطبية^(٢).

بدء الشخصية الاعتبارية للجمعية:

وشخصية الجمعية تبدأ إذا توافرت الشروط التى يستلزمها القانون في هذا الصدد ويستلزم القانون أن يوضع نظام مكتوب موقع

(١) مادة (١) من القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢م.

(٢) المرجع السابق، ص ٣١٤، وفي مصر ينظم الجمعيات القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢،

الذي حل محل القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤.

عليه من المؤسسين، ويجب أن يشمل هذا النظام بيانات معينة نصت عليه المواد ٢، ٣، ٧ من قانون الجمعيات في مصر.

وإذا ما تكونت الجمعية ووجد لها نظام مكتوب مستوف للشروط والبيانات اللازمة، فإنها لا تكتسب الشخصية المعنوية، إلا إذا أشهر نظامها، وفقاً لأحكام القانون، ويكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل المعد لذلك أو مرور ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل من ممثل جمعة المؤسسين دون إتمام القيد، فإذا مضت الستون يوماً دون إتمامه اعتبر القيد واقعاً بحكم القانون، وبمجرد القيد تكتسب الشخصية المعنوية، وينشر ملخص القيد في الوقائع المصرية بغير مقابل خلال ستين يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية^(١).

انتهاء شخصية الجمعية:

وتنتهي شخصية الجمعية بالحل الاختياري أو الجبري:

(١) والحل الاختياري يكون بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفي.

(١) مادة (٩) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩م بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، نُشر بالجريدة الرسمية في ١٩ أغسطس ٢٠١٩م، حلّ محل القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ الذي كان قد أُثيرت حوله انتقادات واسعة، وضع قواعد أكثر مرونة لتأسيس الجمعيات الأهلية، وإجراءات التسجيل، والتمويل، وعلاقة الجمعيات بالجهات الإدارية؛ د. منصور مصطفى منصور، ص ٢٢٧.

(٢) وأما الحل الإجبارى فيكون بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد أخذ رأى الاتحاد العام المتخصص إذا ثبت عجز الجمعية عن تحقيق أغراضها، أو تصرفت في أموالها على غير الوجه المحدد لها طبقاً لأغراضها أو إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين، أو إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو خالفت النظام العام، ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الحل أمام محكمة القضاء الإدارى التى يجب عليها أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال.

وإذا در قرار حل الجمعية، يحظر على أعضائها ومديريها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها، ويحظر على أى شخص أن يشترك في مواصلة نشاط الجمعية أو التصرف في أموالها كما يحظر على كل شخص الاشتراك في نشاط أية جمعية تم حلها بعد نشر قرار حلها في الجريدة الرسمية.

الغصن الثانى

مجموعات الأموال

ويميز هذا النوع من الأشخاص الاعتبارية: أنه يتكون من مجموعة من الأموال، فلا يلزم لنشوءه وجود عدد من الأشخاص، والقانون يعترف بالشخصية الاعتبارية لنوعين من مجموعات الأموال هما: المؤسسات الخاصة والوقف.

أولاً: المؤسسات الخاصة:

تنص المادة (٥٦) من قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩م) على أنه: "تتشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال مدة معينة، أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي)، فالعمل هنا ذو صبغة إنسانية، أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية، أو لأى غرض من أغراض البر أو الرعاية الاجتماعية أو النفع العام، التى لا يقصد منها برح مادي".

وبناء على هذا التعريف يجب أن يتوافر ركنان لقيام المؤسسة:

الأول: تخصيص مجموعة من الأموال، وبهذا تختلف المؤسسات الخاصة عن الجمعية التى هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص.

الثانى: أن يكون الغرض الذى رصد المال لتحقيقه ذا صفة إنسانية، أو علمية، أو دينية أو فنية أو رياضية، أو أن يكون من أعمال النفع العام وأعمال البر التى لا يكون الهدف منها تحقيق ربح مادي^(١).

تكوين المؤسسة:

وقد استلزم القانون المصرى لنشأة المؤسسة، وجود سند رسمى، أو وصية، ويجب أن يشتمل السند على بيانات معينة ينص عليها القانون.

(١) د. عبد الودود يحيى، ص ٣٠٥.

والى جانب تلك البيانات نص القانون على أنه يجب أن يشتمل السند أو الوصية على البيانات الأخرى التى يصدر بتعيينها قرار من الجهة الإدارية.

ويعتبر إنشاء المؤسسة من أعمال التبرع، فهو بمثابة هبة، أو وصية بالنسبة إلى دائئى المنشئ أو ورثته، ولهذا إذا أصابهم ضرر من إنشائها يجوز لهم مباشرة الدعاوى التى يقررها القانون في مثل تلك الحالة بالنسبة للخبات والوصايا^(١).

انتهاء شخصية المؤسسة:

وتنتهى شخصية المؤسسة بالحل الإجباري بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية لنفس الأسباب الواردة لحل الجمعيات (مادة ٦٢)، وقد نصت المادة (٥٥) على أنه: "يرى على المؤسسات بأنواعها من حيث.. حلها ما يسرى على الجمعيات في هذا الشأن من أحكام".

وغنى عن البيان أنه لا يتصور حل المؤسسة اختياريًا، لأنها ليست جماعة من الأشخاص وإنما هي مجموعة من الأموال^(٢).

ثانيًا: الوقف:

والوقف نظام إسلامي يخضع في توصيفه وأحكامه للشريعة الإسلامية، ويعرف الوقف بأنه: "حبس العين على حكم ملك الله - تعالى - والتصدق بالمنفعة"^(٣).

(١) د. توفيق فرج ومحمد يحيى مطر، ص ٣١٦.

(٢) د. عبد الودود يحيى، ص ٣٠٧.

(٣) فتح القدير، ج ٥، ص ٣٧.

ولما كان الوقف يتضمن حبس العين على حكم ملك الله - تعالى-، فإنه يخرج بها عن أن تكون مملوكة لأحد كما يجعل ريعها موجهاً إلى جهات البر في الحال أو المال، ولهذا كان له شبه بالمؤسسات الخاصة، من ناحية أنه مجموعة من المال، ترصد لأعمال الخير، وكان له شخصية معنوية مثله كممثل المؤسسات الخاصة، ومع ذلك فقد نصت المادة (من قانون الجمعيات) على أن: "الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون لا تسري على ما انشئ منها بطريق الوقف"، وسبب ذلك أن الوقف له قانون خاص ينظمه هذا القانون رقم (٤٨ لسنة ١٩٤٦)، كما نصت المادة (٣/٥٢ مدني) على أن الأوقاف من الأشخاص الاعتبارية.

أنواع الوقف:

(١) والوقف قد يكون خيراً:

وذلك إذا خصص ريعه من البداية إلى جهة من جهات الخير كالفقراء والملاجئ والمستشفيات وطلاب العلم.

(٢) وقد يكون الوقف أهلياً (الذري):

إذا استحق ريعه للواقف نفسه أو لغيره من الأشخاص المعينين في سند إنشائه، ثم بعد ذلك لجهة من جهات الخير^(١).

(١) عبد الودود يحيى، ص ٣٠٨.

وقد تم إلغاء هذا النوع من الوقف بموجب القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢م. ويعد إلغاء الوقف الأهلي جزءاً من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ بهدف الحد من تجزئة الملكية وحصر الثروة .

أما هذا النوع من الوقف فالفقه الإسلامي يجيزه من حيث الأصل، لكن المشرع المصري رأى منعه لمقتضيات المصلحة العامة.

إنشاء الوقف:

وينشأ الوقف بمقتضى إشهار رسمي أمام المحكمة، ومتى نشأ فإنه يتمتع بالشخصية الاعتبارية بحكم القانون (مادة ٣/٥٢ مدني)، أما في فقه الشريعة الإسلامية فقد اختلفت أقوال الباحثين حول مدى الاعتراف بالشخصية الاعتبارية فيه فأنكرها كثيرون^(١)، وإن كنا نرى جواز افتراض وجود الشخصية الاعتبارية للوقف على أساس أن له ذمة، صحيح هذه الذمة ليست منوطة بمن يعقل الخطاب، وإنما في تلك الحالة يمكن أن تحل ذمة الناظر محل ذمة الوقف، ويكون مسئولاً عنه وجوباً على أساس أنه فرض كفائي استحال إلى فرض عين بالتعيين والتوظيف لنظارة الوقف، وبالتالي يكون لذمة الناظر نوعان من النشاط: نشاط شخصي يتعلق بحقوق وواجبات الشخص الخاصة أو الذاتية، نشاط وظيفي يتعلق بحقوق وواجبات الوقف، وتنشأ أسبابها في ذمة الناظر على أساس مسئوليته عنه، خاصة وأن القول بوجود

(١) عبد الحي حجازي، ص ١٩٢.

الشخصية الاعتبارية مجرد افتراض لتصحيح الأحكام المتعلقة بالوقف وهو في نظرنا افتراض صحيح لا تأباه الأحكام الشرعية مثله كمثّل الذمة تماماً.

وذلك هو الذي سارت عليه الحاكم، فقد درجت على القول بأن الوقف يعتبر شخصاً اعتبارياً، حتى يتسنى لها أن تفسر اعتباراً ناظر الوقف نائباً عن جهة الوقف عن المستحقين، ولهذا فإن الوقف تكون له ذمة تسأل عن ديونه، ولا يسأل عنها المستحقون^(١).

انتهاء الوقف:

يمكن أن ينتهي الوقف بانتهاء المدة المعينة له في سند إنشائه، أو بإنقراض الموقوف عليهم، كما ينتهي الوقف - أيضاً - إذا تخربت أعيان الوقف كلها أو بعضها ولم يمكن تعمیرها أو إبدالها، وقد نصت المواد (١٦ - ١٨ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٥٨) على أسباب انتهاء الوقف، وإذا انتهى فإنه يعود ملكاً للواقف إن كان حياً، وإلا فلمستحقه وقت الحكم بانتهائه^(٢).

(١) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٧٣٢.

(٢) د. هبة الزحيلي، المرجع السابق، ص ٢١٦ وما بعدها، وذلك هو الحكم الشرعي الراجح.

الفصل الثانى

محل الحق ومصادره وإثباته

وفيه ثلاث مباحث نخصص أولها: لبيان محل الحق، ونخصص ثانيها: لبيان مصادر الحق، وثالثها: لإثبات الحق.

المبحث الأول

محل الحق

والمراد بمحل الحق: الموضوع الذي يرد عليه الحق، وهو بالنسبة للحق الشخصي يتمثل في عمل يقوم على المدين، أو امتناع عن عمل، وبالنسبة للحق العيني يتمثل في شيء من الأشياء المادية يباشر عليه صاحل الحق سلطة معينة تضيق أو تتسع بحسب مضمون الحق، وبهذا يمكن إرجاع محل الحق إلى نوعين هما: الأعمال، والأشياء، ونخصص لكل نوع منهما مطلباً.

المطلب الأول

الأعمال

الأعمال جمع عمل، والعمل معناه: يتمثل في نشاط يبذله الشخص بجسمه أو بعقله، وقد سبق أن رأينا أن محل الحق الشخصي هو دائماً عمل يقوم به المدين، وذلك بخلاف الحق العيني الذي يرد على شيء من الأشياء.

والعمل محل الحق الشخصي قد يكون عملاً إيجابياً كبناء منزل تعهد مقاول بإقامته، كما قد يكون عملاً سلبياً كالامتناع عن المنافسة، أو الامتناع عن البناء في مكان معين، والأعمال التي يمكن أن تكون محلاً للحقوق الشخصية لا يمكن حصرها لأنها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة، فالإرادة حرة في أن تنشئ ما تشاء من الروابط القانونية التي ترتب عليها حقوق شخصية^(١)، ولا يحد من سلطان الإرادة في هذا إلا أن يكون العمل محل الحق الشخصي ممكناً، ومعيناً أو قابلاً للتعيين، ومشروعاً، وهذه تمثل شروط محل الحق الشخصي، ويحسن الإشارة إليها بالتفصيل المناسب:

أولاً: أن يكون العمل محل الحق الشخصي ممكناً، أى لا يكون مستحيلاً في ذاته، وقد نصت على ذلك المادة (١٣٢ مدني) بقولها: "إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً، والاستحالة التي تمنع من قيام الالتزام هي الاستحالة المطلقة التي تقوم بالنسبة

(١) د. عبد الودود يحيى، ص ٣٢٤.

لجميع الأشخاص، حيث تجعل محل الالتزام في تلك الحالة معدوماً، وذلك مثل أن يتعهد محام برفع استئناف انقضى موعده، أو أن يتعهد طبيب بعلاج مريض استبان أنه قد مات.

وأما الاستحالة النسبية، فهي التي تقوم بالنسبة لبعض الأشخاص دون البعض، مثل أن يتعهد من لا يعرف الطب بعلاج شخص، في هذه الحالة لا تمنع الاستحالة من قيام الالتزام، لأن العمل وإن كان مستحيلاً بالنسبة للمتعاقد، إلا أنه ليس مستحيلاً بالنسبة لغيره ممن يقدرّون على العلاج، ومن ثم يكون تعويض الدائن عن الضرر الذي يحدث بسبب عدم التنفيذ.

والنسبة لما إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني، كما يحدث في عقد البيع، فإن الشيء الذي يرد عليه الحق العيني يجب أن يكون موجوداً أو قابلاً للوجود، وإلا فإن الحق لن ينشأ، كما لو تعهد شخص بنقل ملكية سفينة قد غرقت قبل العقد.

ويكفي أن يكون محل الحق قابلاً للوجود، وإن لم يكن موجوداً، كبيع التاجر كمية مما سينتجه مصنع^(١)، وإن كان بيع المعدوم محرماً في الشريعة الإسلامية لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا تبع ما ليس عندك"، ولأن ما ليس عند الإنسان يعتبر من قبيل الغرر الفاحش غالباً، وهو حرام.

(١) د. عبد الودود يحيى، ص ٣٢٥.

ثانياً: كما يشترط أن يكون العمل محل العقد الشخصي معيناً أو قابلاً للتعيين، فإذا تعهد شخص بإقامة بناء، فإنه يجب أن يكون العمل الذي سيقوم به معيناً عن طريق تحديد هذا البناء ببيان أوصافه، أو على الأقل يجب أن يكون العمل قابلاً للتعيين، كما لو ذكر أن البناء المطلوب إقامته مدرسة أو مستشفى مثلاً.

وإذا كان الشيء معيناً بالذات كالسيارة أو قطعة أرض فيجب أن تعين السيارة بذكر أوصافها المختلفة كماركتها ولونها، وسنة إنتاجها، وإذا كان الشيء قطعة أرض فيجب أن يبين مساحتها وحدودها، موقعها.

وإذا كان الشيء معيناً بالنوع فيجب أن يذكر نوعه ومقداره ودرجة جودته، وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الجودة فمعنى ذلك أنهما قد قبلتا أن يكون الشيء من صنف متوسط.

ثالثاً: كما يشترط أن يكون العمل محل الحق الشخصي مشروعاً، ويعبر العمل مشروعاً إذا كان لا يخالف النظام العام أو الآداب ويتعارض مع مصلحة الجماعة، وذلك كتعهد شخص بعدم ارتكاب جريمة مقابل مبلغ من المال، أو تعهده بإرتكابها لقاء أجر أو التعهد بإقامة علاقة جنسية غير مشروعة لقاء مبلغ من المال^(١).

(١) د. عبد الودود يحيى، ص ٣٢٦.

المطلب الثانى

الأشياء (محل الحق العيني)

الأشياء جمع شيء، والشئ هو ما يجوز أن يكون محلاً للحق العيني، ويقع خلط شائع بين المال والشئ، والواقع أن المال هو كل حق مالى، سواء أكان حقاً شخصياً أم حقاً عينياً^(١)، فالمال أعم الشئ، وربما كان من دواعى هذا الخلط هو تلك العلاقة القائمة بين الشئ والمال، وهي علاقة البعض بالكل، وربما كان إطلاق المال على الشئ من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، وهو من التعبيرات الواردة بلاغياً.

ولكننا في مجال الاصطلاح القانوني؛ يجب أن نلتزم دقة التعبير والشئ من هذا المفهوم المحدد، يعرف بأنه: "ما يصلح أن يكون محلاً للحق العيني"^(٢).

تقسيمات الأشياء:

وقد جرى شرح القانون منذ القدم على تقسيمات الأشياء وتصنيفها إلى عدة تقسيمات منها تقسيمها إلى: عامة وخاصة، قابلة للاستهلاك وغير قابلة له، مثليه وقيمية، ثابتة ومنقولة، ولكن قبل بين

(١) والمال في الشريعة من الميل، وهو ما يميل إليه الطبع، واصطلاحاً ما يملك من كل شيء ويشمل المال الشئ والمنفعة، والفقهاء متفقون على مالية الأشياء، أما المنافع فجمهور الفقهاء ومتأخروا الحنفية يرون ماليتها، راجع في هذا المعنى: حاشية ابن عابدين على الدر المختار، ج٤، ص٢١٧.

(٢) د. عبد المنعم البدر، ص٧٣٨.

تلك التقسيمات يجب التنبيه إلى أن هناك شرطاً عاماً يجب أن تتوفر في الأشياء لتكون محلاً للحق العيني، وهو أن يكون الشيء داخلياً في التعامل، ونبين ذلك:

الأشياء الداخلة في التعامل والخارجة عنه:

والأصل أن كل شيء يصح التعامل فيه يصلح لأن يكون محلاً للحقوق المالية، وقد نصت على ذلك المادة (١/٨١ مدني) بقولها: "كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية، ومن هذا النص يبدو أن هناك أشياء تخرج بطبيعتها عن التعامل، وتتمثل في الأشياء المشتركة التي ينتفع بها كافة كأشعة الشمس والماء والهواء، وأساس عدم قابلية تلك الأشياء للتعامل أنها تتأبى عن الاستئثار بها في مجموعها، ومع ذلك فإنه إذا استأثر أحد بكمية من هذه الأشياء، فإنها تصبح مملوكة له ملكية خاصة، تكون محلاً للتعامل، كالماء المعبأ، والهواء المضغوط. وهناك أشياء قابلة للتعامل بطبيعتها، ولكن القانون حكم

بخروج تلك الأشياء من دائرة التعامل وذلك لأسباب منها:

(١) أن هذه الأشياء قد رصدت للمنفعة العامة، والتعامل فيها ينافي هذا التخصيص، قد نص القانون على أنه لا يجوز التصرف في الأشياء العامة أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم (مادة ٥٧ مدني).

(٢) أو لأن المنع من التعامل في تلك الأشياء مبني على اعتبارات تتعلق بالنظام العام كما في المواد المخدرة، التي

يتعلق المنع فيها باعتبارات تتعلق بالصالح العام للمجتمع، وكذلك النقود المزيفة، وهذه تقابل الأشياء غير المتقومة في الفقه الإسلامي لأن تقوم معناه بإباحة الشارع للتعامل في المال^(١).

عرض تقسيمات الأشياء:

أولاً: الأشياء الثابتة (العقارية) والأشياء المنقولة:

من أهم تقسيمات الأشياء وأقدمها، هو تقسيمها إلى عقارات ومنقولات:

(١) الأشياء العقارية:

والعقارات جمع عقار، والمراد به كل شيء ثابت بطبيعته وحيزه، ولا يمكن نقله من مكانه إلى مكان آخر دون تلف يلحق به، وقد نصت المادة (٨٢ مدني) على أن: "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من مكانه دون تلف، فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من الأشياء فهو منقول، ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رسداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله، والنص يفيد أن هناك نوعين من العقارات هي: العقارات بطبيعتها، والعقارات بالتخصيص.

(أ) العقار بطبيعته:

(١) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٧٤٠.

العقار بطبيعته، يتمثل في كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، وهذا التعريف ينطبق على الأراضي، وعلى كل ما يتصل بها من بنیان أو أشجار مادام لا يمكن نقله مك مكانه دون تلف، تيسوي في هذا أن تكون هذه المباني قد أقيمت لتبقى بصفة دائمة أم أقيمت بصفة مؤقتة كأبنية المعارض، كما تيسوي أن يكون من أقام المباني مالكا للأرض أم مستأجراً لها.

ولا يعتبر عقاراً الأكشاك التي يمكن حلها وإقامتها في مكان آخر دون تلف يلحقها ولا النباتات المزروعة في أوعية معدة للنقل. ويعتبر عقاراً بطبيعته كل ما يتصل بالبناء من أشياء كالأبواب والشبابيك والمصاعد وصنابير المياه وأدوات الكهرباء وغيرها، مع أن هذه الأشياء يمكن فصلها من البناء دون تلف، ووصف العقار يلحقها طالما هي مثبتة في البناء، فإذا انفصلت عنه صارت من المنقولات.

(ب) العقارات بالتخصيص:

ووفقاً لما تقضى به المادة (٨٢ مدني في فقرتها الثانية): "يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رسداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله".

ويتبين من هذا النص: أن العقار بالتخصيص إنما هو منقول بحسب الأصل، ولكن الذي يخلع عليه صفة العقار، هو رسده لخدمة العقار أو استغلاله، وذلك كالمواشي والآلات التي تخصص لخدمة الأرض، ومفروشات لفنادق وآلات المصانع.

لكن حتى يعتبر المنقول عقاراً بالتخصيص يجب توافر شرطين:

أولهما: اتحاد مالك العقار المنقول:

فيجب أن يكون العقار والمنقول مملوكين لشخص واحد، ومن ثم لا تعتبر عقارات بالتخصيص الآلات الزراعية المملوكة للمستأجر وحكمه ذلك أن المشرع قد تغياً باعتبار بعض المنقولات عقارات بالتخصيص، أن تلحق هذه المنقولات بالعقار عند التنفيذ على العقار أو التصرف فيه، وهذا القصد لا يتحقق إلا إذا كان مالك العقار هو مالك المنقول المخصص لخدمته أو استغلاله^(١).

ثانيهما: ان يكون المنقول مرصوداً لخدمة العقار أو استغلاله:

كما يجب أن يكون المنقول مخصصاً لخدمة العقار أو استغلاله من خلال رصده لذلك، وذلك كالألات الزراعية وغيرها مما سبقت الإشارة إليه، ويضاف إلى ذلك السيارات المعدة لنقل منتجات المصنع، ولا يشترط أن يكون تخصيص المنقول لخدمة العقار ضرورياً، بل يكفي أن يكون في التخصيص فائدة للعقار ويصح أن يكون الرصد مؤقتاً لا دائماً^(٢).

الأحكام المتعلقة بالعقار بالتخصيص:

وقد قصد المشرع من خلال اعتبار بعض المنقولات عقاراً بالتخصيص، ضمان الاستغلال الأحسن للعقار، ومن ثم فإنه لا يجوز الحجز على تلك المنقولات منفصلة عن العقار الذي الحققت به، ولو لم

(١) د. عبد الودود يحيى، ص ٣١٥.

(٢) د. منصور مصطفى منصور، حيث يضيف شرطاً ثالثاً هو أن يكون التخصيص بواسطة المالك نفسه.

يذكر ذلك في تنبيه نزع الملكية، وكذلك يتبع العقار بالتخصيص العقار الأصلي عند التصرف فيه بالبيع أو عند رهنه، وقد نصت المادة (١٠٣٦ مدني) على أنه: "يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً، ويشمل بوجه خاص العقارات بالتخصيص".

واعتبار المنقول عقاراً بالتخصيص مجرد أمر حكمي مقرر لمصلحة مالك العقار، وهو لا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإنه يجوز لمالك العقار الأصلي أن يتنازل عن الحماية التي قررها له القانون، ويترك دائنه يحجز على المنقول منفصلاً عن العقار المضاف إليه، كما يستطيع المالك أن يزيل عن المنقول صفة العقار بإنهاء رصده على خدمة العقار الأصلي.

وإذا لم يصبح العقار والمنقول مملوكين لشخص واحد، فإن المنقول لا يبقى عقاراً بالتخصيص، كما لو باع المالك المنقول المخصص لخدمة العقار، أو باع العقار دون المنقول المخصص لخدمته، فإن المنقول الملحق به يتحول إلى طبيعته الأصلية، ولا يبقى عقاراً بالتخصص.

(٢) المنقولات:

والمنقولات جمع نقول، والمنقول هو: كل ما يمكن نقله من مكانه دون تلف كالسيارات والمواشي، وأثاث المنزل، وهذه تسمى منقولات بطبيعتها، ولكن يوجد نوع آخر من المنقولات، هي المنقولات بحسب المال، وهي في الواقع أشياء ثابتة، ولكنها تعامل باعتبار ما ستؤول إليه.

(أ) المنقولات بطبيعتها:

وهي كل شيء مكن نقله من مكانه دون تلف، وبشرط ألا يكون قد اكتسب صفة العقار بالتخصيص، وتيسوي في ذلك الأشياء المادية، كالكتب والسيارات والملابس وأثاث المنزل، والأشياء المعنوية، كالاسم التجاري وأفكار المؤلفين والمخترعين، ذلك أن المادة (٨٢ مدني) بعد أن عرفت العقار، أضافت: "وكل ما عدا ذلك فهو منقول"، وكما هو واضح، فإن النص يشمل الأشياء المادية، والأشياء المعنوية.

(ب) المنقول بحسب المآل:

وهذا النوع من المنقولات - بحسب أصله - أشياء عقارية ثابتة ومتصلة بالأرض، وتعتبر لهذا عقارات بطبيعتها، ولكن القانون نظر إليها نظرة مستقبلية تأخذ في اعتبارها ما ستؤول إليه تلك الأشياء مستقبلاً، حيث ستصبح منقولات عما قريب مثل المباني المعدة للهدم، والأشجار المراد قطعها، والثمار والمحصولات قبل حصادها فتلك كلها أشياء عقارية حالياً، وستصبح منقولات مآلاً.

أثر اعتبار العقار منقولاً بحسب المآل:

ويترتب على اعتبار العقار منقولاً بحسب المآل، أنه إذا بيعت تلك المنقولات فإنها تخضع لأحكام بيع المنقول، ولو حدث نزاع بشأنها ينعقد الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه، وليس للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار، وتنقل الملكية فيها من البائع للمشتري دون تسجيل العقد.

واعتبار الشيء منقولاً بحسب المآل يخضع لاتفاق الطرفين على ذلك، فلا يجوز للدائن أن يوقع الحجز على البناء مستقبلاً عن الأرض باعتبار أنه سيكون أنقاضاً، لأن النظر إلى الأشياء باعتبار مآلها يخضع لاتفاق الطرفين، واستثناء من ذلك، يجوز الحجز على الثمار المتصلة والمزروعات القائمة قبل نضجها، وذلك بشرط ألا يكون الحجر قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوماً (مادة ٣٥٤ مرافعات)، ومفاد هذا النص اعتبار هذه الأشياء منقولات رغم اتصالها بالأرض اتصال قرار، فأجاز الحجز عليها رغم أنها متصلة بالأرض^(١)، وعموماً فإن كل أحكام المنقول هي التي تنطبق على الشيء الذي اعتبر منقولاً بحسب المآل^(٢).

شروط اعتبار الشيء منقولاً بحسب المآل:

وحتى تترتب تلك الآثار يجب أن يتوافر شرطان لاعتبار الشيء منقولاً بحسب المآل.

أولهما: أن تتجه إرادة المالك بالفعل إلى فصل الشيء عن الأرض، ومن ثم يجب أن يكون مصيره محتوماً بالانفصال عن الأرض، كما في حالة المباني المعدة للهدم، والأشجار المعدة للقطع.

ثانيهما: أن يكون هذا الانفصال وشيك الوقوع، قريب الحصول، ولا يكفي أن يكون الانفصال أمراً محتملاً، ولعل ذلك هو

(١) د. عبد الودود يحيى، ص ٣١٨.

(٢) د. عبد المنعم البدر، ص ٧٧٣.

السبب الذي حدا بالمشروع أن يجيز الحجز على الثمار والمحصولات والمزروعات حجز منقول.

وقد يلجأ بعض الأفراد إلى تعجل الاتفاق على اعتبار العقار منقولاً تحايلاً على اشتراط التسجيل في بيع العقار بقصد التهرب من رسومه، ولهذا يجب النظر إلى القصد الحقيقي، ولا يمكن أن يقال: إن ذوي الشأن، قد اتجهوا إلى بيع العقار كمنقول إلا إذا قصدوا أن يتم فصله في وقت قريب^(١).

آثار تقسيم الأشياء إلى عقار ومنقل:

وتظهر آثار التفرقة بين هذين النوعين من الأشياء وهما: العقار والمنقول، من ناحية أن القانون لا يعطيها حكماً سواء، إما لاختلافهما من حيث القيمة، وإما لتغيرهما من حيث الاستقرار وعدمه. أولاً: أما اختلاف العقار والمنقول من حيث الاستقرار وعدمه:

فإن ذلك يترتب عليها ما يلي:

(١) نظراً لاستقرار العقار يمكن شهر التصرفات الحاصلة بشأنه، ومن ثم أوجب القانون شهر التصرفات، فوجدت مصلحة الشهر العقاري، حيث يستطيع من خلالها كل شخص أن يعرف حال العقارات، من حيث الحقوق والتكاليف المقررة عليها، وكان سائغاً أن يعلق القانون نقل الملكية فيه على تسجيل التصرف الناقل للملكية.

(١) المرجع نفسه، ص ٧٧٢.

ولما كانت المنقولات غير مستقرة على الأرض، كان من المتعذر إنشاء نظام لشهر التصرفات الحاصلة فيها، فلم يكن بد من الاعتداد بالمبدأ القائل: إن الحيازة في المنقول سند الحائز، وترتب على ذلك أنا مالك العقار لا يستطيع استرداده من الحائز حسن النية، حيث يحول دون غرضه المبدأ السابق، في حين يستطيع مالك العقار أن يسترده من واضع اليد ولو كان هذا الأخير حسن النية^(١).

(٢) أن جواز تملك المبيع بالشفعة أساسه دفع ضرر الجوار، وضرر الجوار لا يتحقق إلا في العقارات لاستقرارها، ولنفس المعنى كانت الشفعة لا تجوز إلا في العقارات.

(٣) كذلك ترفع الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقارى أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار، أما بالنسبة للمنقولات، فإن الدعاوى المتعلقة بها ترفع أمام محكمة موطن المدعي عليه.

ثانياً: أما اختلاف العقار والمنقول من حيث القيمة:

فمرد ذلك إلى الاعتقاد الذي كان سائداً، بأن الشيء المنقول شيء تافه، وكان النظر إلى العقار على أنه الشيء ذو القيمة المالية العالية، التى تدخل في مجال الائتمان، ويرد عليها التأمينات العينية لقوتها المالية في نظر الناس، وقد تغيرت هذه النظرة في الوقت الحالى، بعد أن زادت قيمة المنقولات زيادة هائلة كأثر للتقدم العلمى

(١) د. عبد الودود يحيى، ص ٢٠٣.

والتكنولوجي، حيث أصبحت الآلة الصغيرة التي لا تزيد عن حجم كف اليد تفوق قيمتها أضعاف المرات ثمن العقار، ناهيك عما نراه من منقولات ذات قيم مالية عالية، كالمطائرات والسفن، والآلات الحربية والأسلحة، وأدوات التجسس وأجهزة الاتصالات والتصنت وغيرها، مما حدا بالفقه أن يغير تلك النظرة إلى العقار، وليكون للمنقول حظه في الاعتبار الذي يجعله في مركز قيمي لا يقل عنه لا سيما فيما يتعلق بمجال الائتمان، ولما كان ورود التأمين العيني على المنقولات مما يتعارض مع مبدأ الحيافة في المنقول سند الحائز، فقد ابتكر الفقهاء طرقاً وأساليب للخروج من هذا التعارض، وإعطاء نوع من الحماية لمالك المنقول إذا تداولته الأيدي، من خلال وجود نظام للتسجيل يختص بالمنقول، وقد بدأ ذلك في فرنسا منذ الثلاثينات، بتسجيل انتقال ملكية السيارات، وتطور حتى أصبح يشمل معظم أنواع المنقولات ذات القيمة العالية مما جعل التمايز الذي كان موجوداً بين العقار والمنقول يكاد يكون متلاشياً^(١)، علماً بأن بعض المنقولات لها طرق شهر خاصة كالمطائرات والسفن والسيارات^(٢)، ومن المؤكد أن تقسيم الفقه الإسلامي للحقوق المالية إلى عين ودين، مما يعالج هذا القصور باتفاق وتكامل يدل على سبق محمود في هذا المجال، وهو الذي انتهى إليه الفقه المعاصر في فرنسا بعد جهد كبير.

(١) في هذا المعنى: رسالتنا للدكتوراه، أولوية استيفاء الديون، المشار إليها، ص ٢٥٧ وما بعدها.

(٢) د. عبد الحي حجازي، ص ٢٠٤.

ومع ذلك فما زلنا نلمس بعض الفوارق بين العقار والمنقول بسبب اختلاف القيمة، من خلال بعض النصوص التشريعية التي تظهر ذلك مثل:

(١) اختلاف إجراءات التنفيذ في العقار عنها في المنقولات، حيث إنها في العقار معقدة وتحتاج إلى زمن طويل مما يدل على أن العقار مايزال أكثر أهمية في نظر الشارع.

(٢) أن دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن الفاحش (الذي يزيد على خمس الثمن) لا ترفع إلا إذا كان المبيع عقاراً مملوكاً لشخص لا تتوافر فيه الأهلية (مادة ١٤٥/١ مدني).

(٣) لا يعتبر من الأعمال التجارية إلا الأعمال المتعلقة بمنقولات، أما الأعمال المتعلقة بالعقارات فتعتبر أعمالاً مدنية، وبذلك تخضع لأحكام القانون المدني، وهي أحكام بطيئة وشديدة^(١).

ثانياً: الأشياء المثلية والأشياء القيمة:

الأشياء المثلية، هي التي يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس، أو الكيل أو الوزن، (مادة ٨٥ مدني)، وقد عرفها فقهاء الشريعة الإسلامية، بأنها: الأشياء التي لا تتفاوت أحادها تفاوتاً يعتد به، وتسمى أيضاً بالأشياء المعينة بنوعها، حيث يكفي في تعيينها ذكر نوعها وعدد

(١) د. عبد الحي حجازي، ص ٢٠٤.

وحداتها وذلك كالبرتقال بالعدد، وكالمنسوجات بالمقاس، وكالزيون بالوزن، وكالحبوب بالكيل.

أما الأشياء القيمية، أو الأشياء المعينة بالذات، فهي الأشياء التي لا يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء، وذلك لتفاوت آحادها تفاوتاً يعتد به، وذلك كالعقارات وبيع حصان معين، وسيارة معينة. أثر التفرقة بين المثلّى والقيمي:

وتظهر آثار التفرقة بين المثلّى والقيمي في عدة أحكام:

(١) من حيث الهلاك:

إذا هلك الشيء المثلّى لا تبرأ ذمة المدين به، وعليه أن يقدم مثله، ولهذا يقال: إن المثلّيات لا تهلك، فلو التزم شخص بتسليم عشرة أرادب قمح هندي، وهلك عندده قبل تسليمها، فإنه يلتزم بتقديم غيرها من نفس النوع أو الصنف، أما لو التزم بتسليم شيء قيمي كحصان - مثلاً - وهلك، فإن ذمة الشخص تبرأ لاستحالة التنفيذ، وعند الضمان يقدر بقيمته.

(٢) من حيث الوفاء:

في المنقول المعين بالذات (القيمي) تنتقل الملكية بمجرد التعاقد، أما في حالة المثلّى، فإن الملكية لا تنتقل بمجرد التعاقد، وإنما بالإفراز.

(٣) من حيث الوفاء:

في حالة الأشياء القيمية لا يتم الوفاء إلا بذات الشيء ولا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ولو كان مساوياً له في القيمة، أما المثلّى

فإن ذمة المدين تبرأ إذا قدم أى شيء من نفس النوع بالمقدار المحدد بالعقد.

(٤) من حيث المقاصة:

لا تقع المقاصة إلا بين دينين، موضوع كل منهما شيء مثلى، بشرط الاتحاد في النوع والجودة، فإذا كان الشخص مديناً بنقود أو بشيء مثلى، كان له حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن من نقود مثليات من ذات النوع والجودة^(١).

ثالثاً: الأشياء القابلة للاستهلاك وغير القابلة للاستهلاك:

والأشياء من حيث صلاحيتها للاستعمال تنقسم إلى أشياء قابلة للاستهلاك وأشياء غير قابلة للاستهلاك وأشياء غير قابلة للاستهلاك، والأولى: هي التى لا ينتفع بها إلا باستخدامها، أو هي التى ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها، أو إنفاقها فيجتمع فيها عنصر الاستعمال والتصرف من غير انفصام بينهما (مادة ١/٨٤ مدني) والاستهلاك قد يكون مادياً، وقد يكون قانونياً.

ومن أمثلة الأشياء التى تستهلك استهلاكاً مادياً بمجرد استعمالها الأنواع المختلفة للطعام والوقود، وأما الاستهلاك القانوني فمثاله نقل كلية الشيء، ومثاله إنفاق النقود، وبيع البضائع المعروضة

(١) د. توفيق فرج ومحمد يحيى مطر، ص ٣٢٣ وما بعدها.

في المتاجر، حيث تعتبر من الأشياء القابلة للاستهلاك (مادة ٨٤ مدني).

وأما الثانية، وهي الأشياء غير القابلة للاستهلاك، فإنها تستعمل ويتكرر استعمالها دون أن تستهلك، وذلك كالمنازل والكتب والملابس، ولا عبرة بما يؤدي إليه استعمالها مع الزمن من نقص في متانتها أو الاستهلاك التدريجي لها والعبرة في اعتبار الشيء قابلاً أو غير قابل للاستهلاك هي طبيعته، ولكن الاتفاق قد يغير من تلك الطبيعة.

أثر تقسيم الأشياء إلى قابلة للاستهلاك وغير قابلة له:
وترتب على تقسيم الأشياء إلى قابلة للاستهلاك أو غير قابلة له آثار هي:

(١) الأشياء القابلة للاستهلاك، ترد عليها عقود معينة كالبيع والهبة ولا يرد عليها الإيجار ولا العارية، بخلاف الأشياء غير القابلة للاستهلاك، فإنها ترد عليها.

(٢) كذلك حق الانتفاع وحق السكنى، وهي حقوق عينية مقررة على مال الغير، ولا يتصور أن يكون محلها إلا شيئاً لا يهلك بمجرد الاستعمال^(١).

(١) د. عبد الودود يحيى، ص ٣٢١.

رابعاً: الأشياء العامة والأشياء الخاصة:

والأشياء الخاصة: هي الأشياء التي يملكها أو يجوز أن يملكها الأشخاص، وأما الأشياء العامة: فهي التي لا يجوز لأحد أن يستأثر بمنفعتها، لأنها مخصصة لمنفعة الجميع، وقد ثار جدل حول طبيعة حق الدولة والأشخاص المعنوية العامة على هذه الأشياء، ويبدو مما يفيد نص المادة (٨٧ مدني) أنه حق ملكية مقيد بتخصيص هذه الأشياء لمنفعة العامة.

وقد جاء في نص تلك المادة أنه: "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بمقتضى قانون أو قرار من الوزير المختص". ويستبين من هذا النص أنه لكي يعتبر الشيء عاماً يجب أن تتوافر شرطان:

أولهما: أن يكون الشيء مملوكاً للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

ثانيهما: أن يكون الشيء مخصصاً لمنفعة عامة، تيسوي في ذلك أن يكون الشيء عقاراً كالشوارع والترع والسكك الحديدية ومباني دواوين الحكومة والمستشفيات التي تتولاها الدولة، أو منقولاً، كالأثار الموجودة في المتحف، والأدوات الموجودة في المدارس والجامعات والمستشفيات، ويكون تخصيص الشيء للمنفعة العامة، إما بقانون

أو مرسوم، وقد يكون بالفعل كما لو شقت الدولة مصرفاً أو شارعاً أو قامت ببناء كوبري في أرض مملوكة لها^(١).

وتختلف هذه الأشياء عن غيرها من الأشياء التي تكون مملوكة للدولة ملكية خاصة كالأراضي الزراعية أو ما يؤول إلى الدولة من أشياء عند وفاة صاحبها دون وارث.

آثار التفرقة بين الأشياء العامة والأشياء الخاصة:

وهناك آثار للتفرقة بين الأشياء العامة، والأشياء الخاصة

تتمثل فيما يلي:

(١) فالشيء العام لا يجوز التصرف فيه، وإن وقع هذا التصرف كان باطلاً بطلاناً مطلقاً، والتصرف الممنوع هو الذي يتنافى مع تخصيص الشيء للمنفعة العامة، كبيعه أو إنشاء حق ارتفاق عليه يعطل أو يعوق استعماله في الغرض المخصص له، فإذا لم يكن كذلك يجوز التصرف فيه، مثل أن تقوم الدولة بالترخيص بالصيد في الأنهار والبحيرات العامة، ومثل قيام البلديات بالترخيص لشغل جزء من الطريق العام، ومادام لا يعطل المرور فيه، كما أن للدولة أن تؤجر بعض مبانيها كتأجير المقاصف في دور المصالح الحكومية، والتصرف في ثمار الأشياء العامة كثمار الأشجار المغروسة في الحدائق العامة، ولا يجوز الحجز على الأموال العامة.

(١) د. عبد الودود يحيى، ص ٣٢٣.

(٢) والشيء العام لا يمكن تملكه بالتقادم، فمادام الشيء مخصصاً للنفع العام ولم ينته تخصيصه بقانون أو بقرار أو بالفعل، فإن حيازة فرد له لا يمكن أن تؤدي إلى كسب الشيء بالتقادم، مهما مضى من مدة على هذه الحيازة^(١).

المبحث الثانى

مصادر الحق

يستند الحق في التشريع الوضعى إلى القانون، فكل حق مرده إليه، لأنه هو الذي ينظمه ويحميه والحق لا يقوم إلا مستنداً إلى القانون، فالقانون هو مصدر كل الحقوق، ولئن كان القانون كذلك إلا أنه لا يعدو ان يكون المصدر البعيد لكل الحقوق، بمعنى أنه مصدر يرتب وجود الحق على سبب، وهذا السبب هو ما يمثل المصدر القريب للحق، والذي يعد بمثابة العلة التى يتوقف عليها وجوده، فالقانون قد يعتد بوقائع معينة فيرتب على تحققها وجود الحق، وهذه الوقائع قد تكون غير مكتسبة للإنسان، بمعنى أنها قد تكون عارة عن وقائع مادية تترتب عليها آثار قانونية، حتى ولو لم تتجه إرادة الإنسان إلى حصولها، وقد يرتب القانون الآثار على مجرد اتجاه إرادة الشخص إلى إحداثها.

وفي كل تلك الحالات تعتبر الواقعة التى يرتب عليها القانون وجود الحق، سواء أكانت واقعة طبيعية أم من فعل الإنسان بإرادته

(١) د. عبد المنعم البدرأوى، ص ٧٤٣.

أو بغير إرادته، تمثل وقائع قانونية بالمعنى العام لهذه العبارة، ولئن كانت الواقعة القانونية أثراً، فإن الفقه قد اصطلح على تسمية الأحداث التي ليست من عمل الإنسان، والأعمال المادية التي من عمل الإنسان بالوقائع القانونية، أما التصرفات الإرادية التي يقوم بها الإنسان فتسمى الأعمال أو التصرفات القانونية، وبذلك يكاد الفقه يجمع على أن مصادر الحق يمكن إرجاعها إلى مصدرين رئيسيين هما: الواقعة القانونية، والتصرف القانوني.

وفي نظرنا أن مصادر الحق يمكن إرجاعها إلى مصادر إرادية ومصادر غير إرادية، والأخيرة هي تلك التي درج الفقه على تسميتها بالواقعة القانونية، بينما آثر أن يطلق مسمى التصرف القانوني على المصادر الإرادية، مقدراً أهمية التفرقة بينهما، والتي تتمثل في اختصاص التصرفات القانونية ببعض القواعد التي تنفرد بها دون الواقعة القانونية، فقوام الأولى على الإرادة، ومن ثم فإنها تنفرد بكل القواعد التي تنظم قدرتها على ترتيب الآثار القانونية فيها، كما أن هناك تفرقة بينهما من حيث الإثبات ونحن - من منطلق الحرص على تسمية المعانى من خلال أسبابها القريبة، وأوصافها الصحيحة - سوف نقسم هذه المصادر إلى قسمين: مصادر غير إرادية، ومصادر إرادية، ونبين المراد بكل منهما في مطلب على حدة.

المطلب الأول

المصادر غير الإرادية للحق

(الواقعة القانونية)

والمصادر غير الإرادية للحق تتمثل في وقائع يترتب عليها القانون أثراً دون أن يكون لإرادة صاحبها دخل في حصولها، وهي ما تعرف في الفقه بالواقعة القانونية التي قد تكون من فعل غير الإنسان (واقعة طبيعية) وقد تكون من عمل الإنسان، ويراد به هنا العمل المادى كالفعل الضار، وليس العمل الإرادى، وإن كان كل منهما من عمل الإنسان، ونشير إلى هذين النوعين من الوقائع القانونية.

أولاً: الواقعة الطبيعية

هي الواقعة التي تحدث دون أن يكون للإنسان دخل في حصولها، وكثيراً ما تكون سبباً في ترتيب حق أو انقضاءه، وذلك كمرور الزمن، والميلاد والوفاة، وغيرها، فمرور الزمن يكسب الشخص حقاً يقدر به على التملك بالتقادم، كما يجعل القاصر بالغاً يكون له حق مباشرة اتصرفات القانونية، والميلاد حدث يترتب عليه حقوق كثيرة للمولود، منها ما يتعلق بشخصه كحقه في سلامة جسده وعدم الاعتداء عليه حياته، وحقه في الحرية وحقوقه الأخرى الناشئة عن واقعة الميلاد، والوفاة واقعة طبيعية من فعل الله - عز وجل - يترتب عليها انتقال المال من المتوفى إلى ورثته لهم حق تملك المال بالميراث.

ومن الوقائع الطبيعية: الفيضانات والزلازل والبراكين والحروب، هذه يترتب عليها إعفاء المدين من التزامه، إذا اتخذت شكل القوى القاهرة، ومن ثم لا يقتصر دور الوقائع الطبيعية على إنشاء نوع واحد من أنواع الحقوق، ولكنها تقوم بهذا الدور بالنسبة لجميع الحقوق عينية كانت أم شخصية، وذلك كالوفاة تكسب الورثة ملكية التركة والاستيلاء على مال لا مالك له من الدولة، والاتصاق، والشفعة والحيازة^(١).

ثانياً: الوقائع المتسبة للإنسان:

وهذا النوع من الواقعة القانونية وإن كان مكتسباً للإنسان وناشئاً عن فعله، إلا أنه غير مراد له، ومع ذلك يرتب القانون على هذا الفعل أثراً بناء على ما تقضى به القواعد المقررة من إسناد الحكم لأولى الناس به، والعبرة في تلك الوقائع بالحصول الفعلى أو المادى سواء قصدت نتائجها أم لم تقصد، وهذه الوقائع قد تكون مصدراً للحقوق العينية أو للحقوق الشخصية بدرجة سواء.

وقد اختص القانون واقعيتين ماديتين باعتبارهما من المصادر الهامة لحق الدائنين أو الالتزام، وهما الفعل النافع والفعل الضار، وإلى جانب هاتين الواقعتين توجد وقائع أخرى يرتب القانون عليها نشوء الالتزام.

(١) د. نعمان جمعة، ص ٥٦٦ مابعدھا.

(١) بالنسبة للفعل النافع:

أو الإثراء بلا سبب، فإن فيه شخصاً يثرى على حساب شخص آخر دون سبب قانوني، ولهذا فإن القانون يرتب لمن افتقر حقاً يستطيع بمقتضاه أن يرجع على من أثرى على حسابه، وفقاً لما تقضى به اامادة (١٧٩ مدني)، وقد اهتم المشرع المصري في هذا الصدد بواقعتين نافعتين ووضع لهما أحكاماً مفصلة كأثرين لمبدا الإثراء على حساب الغير، وهما دفع غير المستحق والفضالة.

(أ) ودفع غير المستحق، يقوم في كل حالة يتسلم فيها شخص معين شيئاً على أنه مستحقه، ولكنه ليس كذلك في حقيقة الأمر، وقد نص القانون على أن كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده.

وأما الفضالة، فإنها تتمثل في تفضل شخص بالقيام بشأن عاجل لمصلحة الغير في غيابه أو بدون علمه، كترميم منزل آيل للسقوط غير موجود صاحبه، ففي هذه الحالة يلتزم صاحب العمل بتعويض الفضولي وهو الذي قام بالشأن العاجل، عما أنفقه من مال وما تكبده من خسارة في قيامه بهذا العمل^(١).

(٢) وبالنسبة للفعل الضار:

فإن القانون يرتب عليه آثاره سواء تم عن قصد أو بدونه، أى تم بإهمال ورعونة وعدم تحوط، وغالباً ما يكون الفعل الضار عن غير

(١) د. نعمان جمعة، ص ٥٦٥ وما بعدها.

قصد، ومع ذلك فإنه في كل أحواله ينشئ في ذمة من وقع منه التزاماً بتعويض الضرر، والفعل الضار يعرف بالمسؤولية التقصيرية التي تقوم على أركان ثلاثة: هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإذا ما توافرت تلك الأركان يصدق على الفعل وصف الفعل الضار، فمن يتلف مالا لغيره عمداً أو خطأ يوقع به ضرراً، ويترتب على ذلك التزامه بالتعويض وفي تلك الحالة ينشأ للمضرور حق يصير له دائناً بمبلغ التعويض، تيسوي أن يكون الضرر مادياً أو أدبياً^(١) (مادة ١٦٣ مدني).

(٣) وبالنسبة للقانون:

فإن القانون قد يمثل - بداية - واقعة ترتب في ذمة الشخص التزاماً دون أن يريده، ومثال ذلك حق الحصول على النفقة من بعض الأقارب، كالأب والزوجة، فالقربة هنا واقعة تنشئ الحق في النفقة سواء كانت قرابة نسب أو مصاهرة إذا توافرت شروط وجوب النفقة، ومثلها واقعة الجوار، فهي ترتب للجار بعض الحقوق، كالحق في وضع الحدود للأموال المتجاورة، وحق صاحب الأرض المحبوسة في المرور بأرض جاره للوصول إلى أرضه مقابل تعويض عادل.

(١) د. محمد لبيب شنب، ص ٢٣٢.

المطلب الثانى

المصادر الإرادية للحق

(التصرف القانوني)

والتصرف القانوني يتمثل في اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانونى معين، هو إنشاء حق أو نقله أو تعديله أو انقضائه وذلك كالبيع والإيجار والوصية، ويتميز التصرف القانوني عن الواقعة القانونية، بأن الأثر الذي يترتب عليه إنما يأتى كثمرة لاتجاه الإرادة إليه، فمثلاً في عقد الإجارة تتجه إرادة المؤجر إلى تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجر معلومة، كما تتجه إرادة المستأجر إلى تحصيل تلك المنفعة لقاء أجر، وهذه الآثار إنما حدثت نتيجة لاتجاه إرادة المتعاقدين إليها.

والتصرف القانوني قد يتم بتوافق إرادتين، كما في البيع والإيجار وقد يتم بإرادة واحدة كما في الوصية والوقف، حيث يترتب الأثر القانوني على الإرادة وحدها.

وعلى خلاف الواقعة القانونية، وضعت نظرية عامة للتصرف القانوني تبين الشروط اللازمة لتوافرها في الإرادة لكي تحدث أثرها القانوني، وتعين الأثر الذي يترتب على الإرادة مستوفية الشروط.

ولما كانت الإرادة هي قوام التصرف القانوني، حيث إنها تنشئة وتحدد أثره، فإنها تتمتع بسلطان كبير في إنشاء الحقوق ونقلها وتغييرها وإنقضائها ولكن الإرادة لا تقدر على هذه الأعمال إلا إذا

كانت صادرة عن ذي أهلية خالية مما يعيبها، وبشرط أن يكون الدافع على إبرام التصرف مشروعاً وأن ترد على محل مشروع كذلك.

وهذا يقتضي الكلام أولاً: عن مبدأ سلطان الإرادة والقيود التي ترد عليه، وثانياً: عن الشروط التي يلزم توافرها حتى يكون التعبير عن الإرادة منتجاً لآثاره.

ومن ناحية أخرى فإن الأفراد أحرار في تحديد الآثار التي تترتب على التصرف القانوني^(١).

القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة:

على أن مبدأ سلطان الإرادة ليس على إطلاقه، ولكن هذا الإطلاق يحده قيدان:

أولهما: القواعد القانونية الآمرة:

وفي نطاق تلك القواعد الآمرة ينكمش مبدأ سلطان الإرادة يتلاشى حتى لا يكون له أثر، وقد زادت القواعد الآمرة في وقتنا الحالي على أثر تدخل الدولة في تنظيم العلاقات بين الأفراد، والنزوع نحو المذهب الاشتراكي (الغابر)، أو التأثير بالفكر الجمعي في وقتنا وكان لهذا التدخل أثره في كثير من المسائل كتحديد الأجور والأسعار، وتقرير الامتداد القانوني لعقد الإيجار الذي خففت حالاته في آخر تعديلاته حتى صارت اليوم قصراً على الزوج والزوجة والوالدين

(١) د. توفيق فرج ومحمد يحيى مطر، ص ٣٤٤.

والأولاد، ولا يتجاوز قرابة الدرجة الأولى نسباً فقط، وفي كثير من القيود التي ترد في نطاق العقود^(١).

ثانيهما: مبدأ الشكلية:

ويتمثل مبدأ الشكلية في أن القانون قد يشترط شكلاً معيناً لقيام التصرف في بعض الأحيان، وفي هذه الحالة لا يكفي أن ينقذ العقد بالإرادة، وإنما لابد من إفراغ تلك الإرادة في شكل معين، بحيث يعتبر ذلك الشكل ركناً في التصرف لا يتم إلا به، بالإضافة إلى قيام الإرادة مستوفية لشروطها، والغالب في الشكل الذي يستلزمه القانون هو الكتابة التي قد تكون رسمية، كما هو الشأن في هبة العقار (مادة ٤٨٠ مدني) وقد تكون عرفية، كما هو الشأن بالنسبة لعقد الشركة المدنية (مادة ٥٠٧ مدني)، وقد لا يكون الشكل هو الكتابة ولكن تسليم الشيء محل التصرف، كما هو الشأن في هبة المنقول فلا تنعقد الهبة إلا بتسليم الموهوب المنقول^(٢).

الفرق بين الشكل والإثبات:

وإذا كانت الشكلية شرطاً لانعقاد العقد، بمعنى أنه إذا لم يفرغ العقد في الشكل الذي يوجبه القانون لا يترتب عليه أثر، ويكون باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يغني عن الشكل القانوني إقرار المتعاقدين بصدور العقد أو تنازلهما عن الشكل، وهذه الحالة تختلف عن استلزام الكتابة للإثبات، بحيث لو تخلفت الأخيرة يقوم التصرف بخلاف ما إذا كانت

(١) د. عبد المنعم البدر، ص ٧٨٧.

(٢) د. توفيق فرج ويحيى مطر، ص ٣٤٥.

لازمة لانهقاده؁ وكل ما هناك أنه قد يصعب إيباته لعدم وجود الدليل؁ ولكن ليس معنى عدم وجود الدليل؁ أن التصرف يعتبر غير موجود؁ فإنه موجود ويمكن إثباته بطرق أخرى غير الكتابة - إذا تخلفت - وذلك عن طريق الإقرار أو اليمين؁ أو غير ذلك من وسائل الإثبات.

الشروط الواجب توافرها في الإرادة:

وحتى تكون الإرادة قادرة على إحداث الأثر القانوني فإنه يجب أن تتوافر شروط تتعلق بوجودها؁ وشروط تتعلق بصحتها.

(١) شروط وجود الإرادة:

فيشترط أن تكون هناك إرادة موجودة؁ ووجود الإرادة يقتضي التعبير عنها في العالم الخارجي؁ فلا بد أولاً: من وجود إرادة يعتد بها القانون؁ ومن ثم فإنه إذا لم يعترف القانون للشخص بإرادة يعتد بها؁ فإن هذا الشخص لا يستطيع أن يجرى أى تصرف من أى نوع؁ لأنه من المقرر أن انعدام التصرف وذلك كما في حالة الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه.

ولابد ثانياً: من التعبير عن الإرادة؁ فإذا ظلت الإرادة حبيسة في نفس صاحبها؁ فلن يترتب على احتباسها أثر؁ فيجب أن يعبر عنها في العالم الخارجي؁ والتعبير عن الإرادة قد يكون صريحاً أى يتم بألفاظ وعبارات صريحة ومباشرة تكشف بوضوح عن قصد من صدرت منه على اتجاه إرادته؁ وقد يكون ضمناً يدل على المقصود بطريق

غير مباشر، **ولابد ثالثاً:** أن يكون اتجاه الإرادة إلى تحقيق غرض مشروع، والغرض من المشروع هو الذي لا يخالف النظام العام أو الآداب، ومن ثم فإنه إذا حدثت مخالفة الإرادة لهما، فإن القانون لا يعتد بها في إنشاء التصرف القانوني^(١).

شروط صحة الإرادة:

ويجب لصحة التصرف القانوني أن تكون الإرادة حرة سليمة خالية من العيوب، فإذا كانت الإرادة مشوبة بعيب من العيوب، كان التصرف قابلاً للإبطال لمصلحة من عيبت إرادته، وعيوب الإرادة هي الغلط، والتدليس والإكراه والاستغلال.

(أ) الغلط:

وهو يقوم في ذهن المتصرف فيصور له أمراً على غير حقيقته بحيث لو كان يعلم الحقيقة لما تصرف، ويشترط أن يكون الغلط جوهرياً، بأن يكون قد بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع المتعاقد معه عن إبرام لو لم يقع هذا الغلط (مادة ١/٢١ مدني) كما يشترط أن يكون المتعاقدان مشتركين في الغلط، بأن يكون المتعاقد الآخر واقعاً فيه أو عالماً به^(٢).

(١) د. عبد الودود يحيى، ص ٣٣٧.

(٢) د. عبد الودود يحيى، ص ٣٣٨.

(ب) التدليس:

وهو عبارة عن غلط يقع فيه الشخص نتيجة استعمال حيل تولد عنها اعتقاد غير صحيح دفعه إلى التصرف، وهو يعيب الإرادة إذا كان هو الدافع لها، ويزيد التدليس عن الغلط في انه مصحوب بطرق احتيالية ويكون من السهل إثباته، لأن الطرق الاحتيالية تمثل وقائع مادية ظاهرة، بينما الغلط أمر نفسي يصعب إقامة الدليل عليه، ويجب حتى يكون التدليس عيباً في الإرادة أن تكون الحيل المصاحبة له قد استعملت للوصول لغرض غير مشروع كما يجب أن تكون قد بلغت حداً من الجسامة بحيث لو كان الشخص يعلم بها لما تصرف، وأن يكون للطرف الآخر صلة بها.

(ج) الإكراه:

والإكراه عيب في الإرادة يتمثل في ضغط غير مشروع يقع على إرادة الشخص فيجمله على التصرف، والإكراه قد يعد إرادة، كأن يمسك شخص بيد آخر ويحركها للتوقيع على محرر، وفي هذه الحالة تنعدم الإرادة.

أما الإكراه الذي يعتبر عيباً في الإرادة، فهو الذي لم يبلغ هذه الدرجة، ولكنه يجعل المرء بين أمرين، غما أن يختار وقوع ما هدد به، أو يبرم التصرف القانوني الذي طلب منه فإذا اختار إبرام التصرف في ظل تلك الظروف تكون إرادته معيبة، ففيه قدر من التخيير بين أمرين أحلاهما مر.

والإكراه قد يكون مادياً كالضرب، وقد يكون معنوياً كالتهديد بإحراق منزل أو إفشاء سر، أو التعدي على عرض، ويجب أن يكون الغرض من الإكراه غير مشروع، وأن يكون قد ولد في نفس المتصرف رهبة دفعته إلى التصرف، وأن تكون ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، ومعيار التقدير هنا معيار شخصي، يراعى فيه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية^(١).

(د) الاستغلال:

وهو غبن يصيب المتصرف نتيجة انتهاز التعاقد الآخر فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً، بحيث لم يكن ليصدر منه هذا التصرف على هذا الوجه لولا استغلال المتعاقد الآخر له، فيشترط حتى يكون الاستغلال عيباً في الإرادة: أن يقع غبن يتمثل في عدم التعادل بين قيمة ما أخذه المتصرف وقيمة ما أعطاه، وأن يتم التصرف في حال الطيش البين والهوى الجامح من المتصرف، وأن يكون الطرف الآخر على علم بهذا ويستغله، كما لو لمس الزوج رغبة زوجته في الطلاق منه لتتزوج بآخر، واستغل موقفها هذا واشترى منها عقاراً بغبن فاحش، وكما لو استغلت زوجة شابة زوجها العجوز المتيم بها في شراء شيء منه بغبن فاحش ويكون التصرف قابلاً للإبطال في تلك الحالات.

(١) المرجع السابق، ص ٣٣٩، وراجع: د. جميل الشرقاوى، ص ٤١٤ وما بعدها.

أقسام التصرف القانوني:

والتصرف القانوني ينقسم إلى عدة أقسام منها:

أولاً: التصرف المنشئ، والتصرف الناقل، والتصرف الكاشف:

(١) أما التصرف المنشئ: فهو الذي يكسب الإنسان حقاً لم يكن موجوداً من قبل، كالزواج، يكسب الشخص حقوقاً لم تكن موجودة من قبل.

(٢) وأما التصرف الناقل: فهو الذي ينقل حقاً كان موجوداً من قبل إلى شخص آخر، وذلك مثل البيع فإنه ينقل الملكية من البائع للمشتري.

(٣) وأم التصرف الكاشف: فهو الذي لا ينشئ حقاً، ولا ينقله ولكنه يكشف عن حق قائم بحالته التي هو عليها، كمن يقر بدين عليه، حيث يتضمن ذلك كشفاً عن حق قديم^(١).

ثانياً: تصرف معاوضة، وتصرف تبرع:

وفي تصرف المعاوضة، يأخذ المتصرف مقابلاً لما يعطى، وذلك كالبيع، حيث يبذل البائع السلعة مقابل ثمن، أما التبرع، فلا يأخذ المتصرف فيه مقابلاً لما بذل، وذلك كالهبة، حيث يبذل الواهب الشيء الموهوب، دون مقابل.

(١) د. أحمد سلامة: المدخل لدراسة القانون ١٩٦٩، ص ٣٤٦ وما بعدها.

ثالثاً: تصرف رضائي، وتصرف شكلي:

والأول: يوجد وينتج أثره بمجرد التراضي عليه، أياً كان الشكل الذي يتخذه هذا الرضا، وذلك مثل البيع والإيجار والقرض، حيث يتم العقد فيها بمجرد توافق الإيجار مع القبول، وأما الثاني: فهو الذي يتطلب إفراغ ذلك الرضا في شكل معين إذا لم يتوافر لا ينعقد العقد، مثل الهبة (مادة ٤٨٨ مدني) وعقد الرهن الرسمي (مادة ١٠٣١ مدني) والشركة (مادة ٥٠٧ مدني)^(١).

رابعاً: تصرف في حال الحياة، وتصرف مضاف إلى ما بعد الموت:
والتصرف الأول: هو الذي ينتج أثره في حياة المتصرف، كالبيع والهبة، وأما الثاني: فإنه يضاف إلى ما بعد الموت، فلا ينتج أثره إلا بعد وفاة المتصرف، وذلك كالوصية، فإن ملكية الشيء الموصى به لا تنتقل إلا بعد وفاة الموصى.

خامساً: تصرفات الحفظ، وتصرفات أعمال الإدارة:

والأولى: هي الأعمال الضرورية التي تتم بقصد حماية الذمة المالية للشخص أو حماية مال معين من أمواله انتقاء لخطر داهم، وذلك كقطع التقادم والجرد، وقيد الرهن، وأعمال الحفظ عاجلة وضرورية وغير خطره لأنها لا تخرج المال من ملك صاحبه، وملكا كانت عاجلة فإن المشرع قد سمح بالتوسع فيها، فأجاز لناقص الأهلية

(١) د. محمد لبيب شنب، ص ٢٣٦ وما بعدها.

أن يقوم بها لحماية أمواله، كما أوجبها على من يرعى أمواله كالوكيل أو الوصى، كما أنها لا تمس أصل الحق.

وأعمال الإدارة: هي التي يقصد منها استغلال أو استثمار العناصر المادية المكونة للذمة المالية استغلالاً عادياً، دون أن يترتب عليه إلزام الذمة في المستقبل، ودون أن تغير من التخصيص الاقتصادي للعناصر المكونة لها، فهي لا يترتب عليها خروج حق من ذمته المتصرف، أو إنشاء حق عيني على شيء مملوك له، وإنما يقصد بها المحافظة على حقوق الشخص واستثمارها من خلال الحصول على غلاتها مع بقائها في ذمة صاحبها وذلك كالحصاد والتأجير^(١)، وشراء الأدوات والأجهزة اللازمة لاستغلالها.

وغنى البيان أن الواقعة القانونية والتصرف القانوني - يعتبران من مصادر الحقوق الشخصية والحقوق العينية في قانوننا المدني.

المبحث الثالث

إثبات الحق

والمقصود بإثبات الحق هو: إقامة الدليل على وجوده وتظهر الحاجة إلى إثبات الحق عندما يكون محل نزاع، ففي هذه الحالة يتعين على من يدعى حقاً أن يلجأ إلى القضاء لإثباته، فإذا نجح في إثبات حقه استطاع أن يتمتع بثمار هذا الحق، وإذا فشل كان حقه والعدم

(١) د. محمد السعيد رشدي: الرسالة السابقة، ص ١٩١ وما بعدها.

سواء، فالحق بدون دليل لا قيمة له عند المنازعة فيه، ومن هنا تظهر أهمية إثبات الحق.

وإثبات الحق بإثبات مصدره، فمن يدعى أن له مبلغاً عند شخص، كان عليه أن يثبت مصدر هذا المبلغ، وهل هو عقد قرض أو بيع مثلاً أو تعوض عن عمل نافع أو ضار^(١).

على من يقع عبء إثبات الحق:

وعبء إثبات الحق حدث بشأنه خلاف فقهي كبير ظهر آثاره في عدو مذاهب منها: مذهب الإثبات الحر أو المطلق، وهو ينادى بأن كل من يدعى حقاً عليه إثبات حقه بالسيلة التي يراها مقنعة للقاضي بوجوده، وللقاضي في ظل هذا النظام أن يتحرى عن صحة ما يدعيه الخصوم، بأية طريقة يراها.

وهناك مذهب الإثبات المقيد؛ أو القانوني، وهو ينادى بتحديد طرق الإثبات وأدلتها وقيمة كل دليل، بحيث لا يجوز للخصوم ولا للقاضي إثبات الحق بغير الأدلة المنصوص عليها قانوناً وفي حدود ما وضعه القانون من تقدير لقيمة كل دليل^(٢).

وهناك المذهب الوسط؛ أو المختلط، وهو يجمع بين المذهبين السابقين، فيحدد بعض طرق الإثبات وأدلتها، ويسمح للقاضي بتقدير

(١) د. عبد الناصر، ص ٤٢٤٩.

(٢) د. عبد الناصر العطار: المكان نفسه، وراجع: مجموعة الأعمال التحضيرية، ج ٣، ص ٣٤٩.

قيمة بعض الأدلة، وبهذا المذهب الأخير أخذ المشرع المصري - في قانون لإثبات الأخير^(١) - وبعض قواعد قانون المرافعات.

ويقضى هذا القانون بأ عبء الإثبات يقع على من يدعى خلاف الظاهر، فمن يدعى خل الظاهر عليه إثبات ما يدعيه حيث نصت المادة الأولى منه على أنه: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، إذ الأصل أن كل شخص برئ من الديون، ومن يدعى أن عليه ديناً له، يدعى خلاف الظاهر فعليه أن يثبت حقه.

وقد يقيم القانون قرينة لصالح من يدعى خلاف الظاهر، بحيث إذا توافرت فإن عبء الإثبات ينتقل إلى هذا الشخص الآخر.

أدلة الإثبات وطريقته:

وأدلة الإثبات وفقاً لما ورد في القانون هي الكتابة وشهادة الشهود، والقرائن القضائية، والإقرار واليمين، والمعاينة والخبرة، وهذه الأدلة تنقسم إلى:

(١) أدلة مطلقة، وهذه تصلح لإثبات جميع مصادر الحقوق، وهي الكتابة وما يقوم مقامها، وهو الإقرار واليمين.

(٢) وأدلة مقيدة، أى أدلة تثبت بها بعض مصادر الحق، وبشروط معينة، وهي شهادة الشهود أو البينة، والقرائن القضائية والمعاينة والخبرة، كما بين المشرع طق الاحتجاج بكل دليل من هذه الأدلة، ونعطي فكرة عامة عنها وطرق الإثبات بها.

(١) رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م الذي عمل به اعتباراً من أول ديسمبر ١٩٦٨م.

أولاً: الكتابة:

هي كل محرر مكتوب يثبت صدور التصرف^(١)، وهي من أهم وسائل الإثبات حيث توفر للخصوم من الضمانات ما لا يوجد في غيرها خاصة فيما يتعلق بالوضوح، وعدم التحريف، حيث تفرغ الكتابة في ورقة تسمى: "محرراً" وهذا المحرر يعتبر دليلاً كتابياً والمحركات نوعان: محررات رسمية ومحركات عرفية.

(١) المحررات الرسمية:

هي التي تثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته (مادة ١٠/١ إثبات) فيشترط في المحرر الرسمي ثلاثة شروط:

الأول: انيقوم بتحريره موظف عام، كموظف الشهر العقاري أو شخص مكلف بخدمة عامة كالمأذون.

الثاني: أن يحرره وفقاً للأوضاع القانونية، وأن يكون بخط واضح خال من الكشط والتحشير.

الثالث: وأن يكون تحرير المحرر مما يدخل في اختصاص الموظف العام.

والمحرر الرسمي حين يستوفى تلك الشروط يكون حجة على الكافة في حدود ما هو مثبت فيه من أمور قام بها من حرره في نطاق سلطته واختصاصه، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ولا يجوز

(١) د. أحمد سلامة، ص ١٦٦.

الطعن في بيانات المحرر الرسمى إلا بالتزوير وبالطرق المقررة قانوناً للطعن والتزوير، وإذا اختل شرط من تلك الشروط يكون لهذا المحرر قيمة العرفى في الإثبات، متى كان أصحاب الشأن قد وقعوه بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

(٢) المحررات العرفية:

وهي كل ورقة موقع عليها من شخص ولم يحررها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في شأن من شئون سلطته واختصاصه، والمحرر العرفى يعتبر حجة على من وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وقد أجاز المشرع للمحكمة أن تأمر بتحقيق الخطوط بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، كما أجاز الطعن بالتزوير وفق قواعد معينة.

ويلاحظ أن التأشير على سند يفيد براءة المدين يعتبر حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته، وكذلك الأمر إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاج مه براءة ذمة المدين، وكان ذلك في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين^(١).

ولا يحتج بما ورد في المحرر العرفى على غير أطراف هذا المحرر إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت. (أ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.

(١) د. عبد الناصر العطار، ص ٢٥١.

(ب) أو من يوم أن يثبت مضمون المحرر في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

(ج) أو من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.

(د) أو من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بضمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أخذ من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعله في جسمه.

(هـ) أو من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه، ففي جميع هذه الأحوال يمكن القطع بأن المحرر كتب في تاريخ وقوع هذه الأمور.

ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق الحكم السابق على المخالصات (مادة ١٥ إثبات).

وتعتبر دفاتر التجار محررات عرفية وهي حجة على أصحابها فإذا كانت منتظمة وجب على من يحتج بها أن يأخذ ما ورد فيها كله دون أن يستبعد منها ما يناقض دعواه، ولا تكون هذه الدفاتر حجة على غير التجار، إلا أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضى أنيوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين فيما يجوز إثباته بالبينة (مادة ١٧ إثبات).

ثانياً: الإقرار:

والإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أمام القاضي وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة فلا يُعد إقراراً بهذا المعنى اعتراف الخصم أمام الشهود.

والإقرار حجة قاصرة على المقر، غير انه لا يقبل التجزئة،
فإنما أن يؤخذ كله أو يترك كله، فلو أقر شخص بأنه مدين لآخر بمبلغ
وغي منه جزءاً، فلا يمكن استبعاد إقراره بالوفاء، لكن إذا تعلق الإقرار
بوقائع متعددة، وكان وجود واحدة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع
الأخرى جاز تجزئة الإقرار، فلو أقر الشخص بأنه مدين لآخر،
وأضاف أن هذا الدين قد انقضى بالمقاصة، جاز تجزئة الإقرار بأن
يعتبر الدين ثابتاً في ذمة المقر، ويقع عليه عبء إثبات هذه
المقاصة^(١).

ثالثاً: اليمين:

وهي إشهد الله - تعالى - أمام القضاء على صدق ما يقوله
الحالف ويجوز لمن يعوزه طريق آخر للإثبات أن يوجه خصمه
اليمين، فإذا حلف الخصم الذي وجهت إليه اليمين رفضت دعوى
المدعي، وإذا نكل حكم للمدعي، ويجوز لمن وجه إليه اليمين أن يردها
على من وجهها إليه، أى يطلب منه أن يحلف هو، وحالتئذ يتغير
الوضع فيصبح من وجه اليمين أولاً هو المكلف بالحلف، فإن حلف
كسب الدعوى وأن نكل خسر الدعوى وليس له أن يرد اليمين مرة
ثانية^(٢).

(١) د. عبد الناصر العطار، ص ٢٥٢.

(٢) د. منصور مصطفى منصور، المكان نفسه.

وهكذا يستبين أنه يترتب على توجيه هذه اليمين في جميع الأحوال إنهاء النزاع إما لمصلحة من وجهها، أو لمصلحة من وجهت إليه ولهذا تسمى باليمين الحاسمة (مادة ١٨ إثبات).

وأما اليمين المتممة؛ فهي يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأى من الخصمين عندما يرى أن هذا الخصم قدم دليلاً غير كاف على دعواه ليتمم الدليل باليمين.

رابعاً: البيئة

ويقصد بالبيئة؛ شهادة الشهود، وهي دليل مقيد، فلا يستدل بها في جميع الأحوال، فيجوز الالتجاء إليها لإثبات الوقائع القانونية، أما بالنسبة للتصرفات القانونية فيستدل بها في بعض الأحوال، ولا يستدل بها في أحوال أخرى، لكن يلاحظ أنه حيث يجيز القانون الإثبات بشهادة الشهود يبحث القاضي عن الحقيقة في أقوالهم، ويكون له الحق في أن يأخذ بتلك الأقوال أو لا يأخذ، ولا أهمية لعدد الشهود فقد تكون أقوال شاهد واحد محل ثقة لدى القاضي أكثر من أقول عدة شهود آخرين.

وشهادة الشهود تصل لإثبات الوقائع الطبيعية كواقعة الجوار في الشفعة مثلاً، كمل تصلح لإثبات الأفعال المادية كالفعل الضار أو النافع، أما في التصرفات القانونية فتعتبر دليل إثبات مقيد فلا يحتاج بها إلا في حالات معينة منها المسائل التجارية لقيامها على السرعة، والائتمان، ومن ثم فلم يتطلب المشرع الكتابة لإثبات التصرفات القانونية المتعلقة بها، وإذا كانت قيمة التصرف المالية دون

الخمسمائة جنيه، ويجوز إثبات التصرف بشهادة الشهود مهما بلغت قيمته المالية إذا كان هناك نص أو اتفاق يقضى بذلك، أوقام مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي كالديون التي تتم بين الأب وأولاده والزوج وزوجته، والخاطب ووالد خطيبته، حيث يجوز إثباتها بشهادة الشهود مهما بلغت قيمة الالتزام لوجود مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، وكذلك يجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب لا يد له فيه، أو كان هناك مبدأ ثبوت بالكتابة، وهو أية ورقة بها كتابة صادرة من الخصم من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال.

وقد بين قانون الإثبات طريقة سماع شهادة الشهود واستجوابهم وجعل للقاضي سلطة تقدير هذه الشهادة وفق اقتناعه اشخصي بما يسمعه منها.

خامساً: القرائن:

القرينة هي ما يستنبط من أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول، وهي نوعان:

(١) قرينة قضائية:

ويتمثل فيما يستنبطه القاضي من أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ويجوز للخصم أن يرد القرينة القضائية بكافة طرق الإثبات.

(٢) قرينة قانونية:

وهي ما يستتبطه المشرع من أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول ينص عليه، والقرينة القانونية ليست دليلاً للإثبات، وإنما هي وسيلة لنقل عبء الإثبات من خصم إلى آخر، فهي تعنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، ومثال ذلك ما تقضى به المادة (٥٨٧ مدني) من أن الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، ومن ثم فإن تقديم المستأجر مخالصة بالإيجار عن شهر يوليو مثلاً يغنيه عن تقديم دليل على الوفاء بأجرة الشهر السابقة عليه، ويكون على المؤجر عندئذ عبء إثبات عكس المستفاد من هذه القرينة.

وقد أجاز قانون الإثبات للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع فيه، أو أن تتدب أحد قضائها لهذه المعاينة، ولها أن تعين خبيراً للاستعانة به في المعاينة.

وقد أجاز قانون الإثبات للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد من ثلاثة على أن تعين له المأمورية المطلوبة منه وتضرب له أجلاً لإيداع تقريره ومن المقرر قانوناً أن رأى الخبير استشاري لا يقيد المحكمة^(١).

شروط الواقعة القانونية محل الإثبات:

(١) د. عبد الناصر العطار، ص ٢٥٥.

وحتى تكون الواقعة القانونية محلاً للإثبات، فإنه يجب أن يتوافر فيها عدد من الشروط، وهي:

أولاً: يجب أن تكون الواقعة محل نزاع، وهذا أمر بدهي، فالواقعة ما دامت غير مجعدة من الخصم فإنها لا تحتاج إلى إثبات.

ثانياً: أن تكون الواقعة محددة، حتى يمكن إثباتها عملاً، فمن يدعى ملكية شيء يجب عليه أن يقيم الدليل على واقعة محددة كانت سبباً للملكية.

ثالثاً: أن تكون الواقعة متعلقة بالحق المطالب به، فإذا كانت الواقعة المراد إثباتها غير متصلة بموضوع النزاع فلا يجوز أن تكون محلاً للإثبات وهذا شرط بدهي، حتى لا يتشتت جهد القاضي ويضيع وقته فيما لا طائل من ورائه، وتكون الواقعة متعلقة بالحق المطالب به إذا كانت هي سبب إنشائه.

رابعاً: أن تكون الواقعة منتجة في الإثبات، بمعنى أن تكون مؤثرة في الفصل في الدعوى، من خلال مساهمتها في تكوين عقيدة للقاضي بوجود الحق المدعي به.

خامساً: ويجب أخيراً أن تكون الدعوى مما يجوز إثباته، بمعنى: أن يكون إثباتها ممكناً، فإن كان إثباتها مستحيلاً لاعتبارات عقلية، مثل إثبات رابطة البنوة بن شخص آخر ويصغره سناً، أو لاعتبارات قانونية، مثل إثبات صحة حكم قضائي حيث يتضمن هذا الإثبات إنكاراً لمبدأ حجية الأمر المقضى به أو إثبات دين قمار، ففي تلك الوقائع لا يجوز الإثبات.

المبادئ الرئيسية في الإثبات:

وللإثبات عدة مبادئ رئيسية يقوم عليها، ومن تلك المبادئ:

أولاً: من حق الخصم أن يقدم للقضاء كل ما تحت يده من أدلة يسمح بها القانون، فإذا لم يمنع القاضي من ذلك كان هذا إخلالاً بحقه في الإثبات، يستوجب الطعن في الحكم بالنقض.

ثانياً: من حق كل خصم أن يثبت عكس الدليل الذي قدمه خصمه وتطبيقاً لذلك فإن الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود، يعطى للخصم الآخر الحق في نفس تلك الواقعة بشهادة الشهود أيضاً.

ثالثاً: لا يجوز لأى خصم أن يصطنع دليلاً لنفسه، فلا يجوز أن يكون دليل المدعي مجرد أقواله أو ادعاءاته، أو ورقة صادرة منه، ويستثنى من ذلك دفاتر التجار فإنها حجة عليهم وقد تكون حجة لهم.

رابعاً: لا يجوز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه، فكما أنه لا يستفيد من دليل صنعه لنفسه، فإنه لا يضار أيضاً بتقديم دليل ضد نفسه، فلا يجوز للقاضي أن يجبر الخصم على إبراز سند يفيد خصمه، واستثناء يجوز للقاضي في أحوال معينة في المنازعات التجارية، وبعض المنازعات المدنية، أن يأمر المدعي بتقديم الدفاتر التجارية والإطلاع عليها لإثبات حقيقته به.

خامساً: أن الأدعاء في موطن النسب والدماء والجرائم، إتهام، فمن يدعى على شخص أنه والد لذلك الطفل، يكون ذلك إتهاماً له، ينقل عبء إثبات نفى تلك الواقعة عليه، وكذلك من يدعى على شخص

قتلاً، أو قذفاً، فإن ذلك الإدعاء يمثل إتهاماً ينقل عبء إثباته من المدعي عليه الذي يكون متهماً في تلك الوقائع.

ومن هذا القبيل إدعاء النيابة العامة على شخص ارتكاب جريمة، فإن الجهة المدعية لا تلزم بتقديم ما يثبت قيامه بذلك إعمالاً لمبدأ: "البينة على المدعي"، وإنما يلزم المتهم لنفي التهمة عنه أن يقيم هو الدليل على عدم صحتها، وهذا المبدأ مأخوذ من القواعد المقررة للإثبات في مجال الإتهام في الفقه الإسلامي، وهو مبدأ جديد لم يلتفت إليه كثير من الفقهاء، وإن كان حكمه مطبقاً فيما يصدر عنهم من التوصيف الفقهي للفروع المندرجة تحته.

وبذكر تلك المبادئ تنتهي هذه الدراسة الجديدة للحقوق التداولية والحقوق التبادلية، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كان لنهتدى لولا أن هدانا الله، والحمد لله رب العالمين.

أ.د. عبد الله النجار

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٥	تقديم
٩	خطة الدراسة
	الباب الأول
	التعريف بالحق وبيان تصنيفات الحقوق
١٥	الفصل الأول: تعريف الحق وتمييزه عما يخالط به
١٥	المبحث الأول: تعريف الحق في فقه القانون
٤٣	المبحث الثاني: تمييز الحق عما يختلط به في القانون
٥١	الفصل الثاني: تصنيف الحقوق والمعيار الذي تقوم عليه
٥٥	المبحث الأول: الحقوق التداولية
٥٨	المبحث الثاني: الحقوق التداولية
٥٨	المطلب الأول: الحقوق غير المالية
٦٥	المطلب الثاني: أنواع الحقوق المالية
٦٩	المطلب الثالث: الحقوق المختاطة (حقوق الملكية الفكرية)
٧٠	الفرع الأول: جوانب حقوق الملكية الفكرية

الموضوع	الصفحة
الفرع الثاني: حماية حقوق المؤلف	٧١
الباب الثاني عناصر فكرة الحق	
الفصل الأول: صاحب الحق	٨١
المبحث الأول: الشخص الطبيعي	٨٢
المطلب الأول: وجود الشخص الطبيعي	٨٢
الفرع الأول: الحكم بموت المفقود	٩٦
الفرع الثاني: حالة المفقود طوال مدة فقده	٩٩
المطلب الثاني: هوية الشخص الطبيعي	١٠٢
الفرع الأول: حق الشخص في تمييز ذاته الحق في الاسم	١٠٢
الفرع الثاني: حالة الشخص الطبيعي	١١٠
الفصل الأول: الحالة الدولية للشخص (الجنسية)	١١٠
الفصل الثاني: الحالة العائلية	١١٤
الفصل الثالث: الحالة الدينية	١٢٠
الفرع الثالث: موطن الشخص الطبيعي	١٢٢
المطلب الثالث: أهلية الشخص الطبيعي	١٣١
الفرع الأول: مراحل تدرج الأهلية	١٣٤

الموضوع	الصفحة
الفرع الثاني: عوارض الأهلية	١٣٦
الغصن الأول: عوارض فقد الأهلية	١٣٦
الغصن الثاني: عوارض نقص الأهلية	١٤٠
الفرع الثالث: موانع الأهلية	١٤٤
الفرع الرابع: أثر الأهلية في التصرفات	١٤٨
المبحث الثاني: الشخص الافتراضي أو المعنوي	١٥٧
المطلب الأول: وجود الشخص المعنوي	١٦٠
المطلب الثاني: هوية الشخص المعنوي	١٦٣
المطلب الثالث: أهلية الشخص المعنوي وأنواعه	١٦٦
الفرع الأول: أهلية الشخص المعنوي	١٦٦
الفرع الثاني: أنواع الشخص المعنوي	١٧٠
الغصن الأول: جماعات الأشخاص	١٧١
الغصن الثاني: مجموعات الأموال	١٧٨
الفصل الثاني: محل الحق ومصادره وإثباته	١٨٥
المبحث الأول: محل الحق	١٨٥
المطلب الأول: الأعمال	١٨٥
المطلب الثاني: الأشياء (محل الحق العيني)	١٨٩
المبحث الثاني: مصادر الحق	٢٠٧

الموضوع	الصفحة
المطلب الأول: المصادر غير الإرادية للحق (الواقعة القانونية)	٢٠٩
المطلب الثاني: المصادر الإرادية للحق (التصرف القانوني)	٢١٣
المبحث الثالث: إثبات الحق	٢٢٣
الفهرس	١٣٦